



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.004309/2016-73 (RJ2016/5733)

Data do julgamento: 03/12/2019

Diretora Relatora: Flávia Martins Perlingeiro

Acusados: Affonso Celso Pastore

André Bier Gerdau Johannpeter

André Pires de Oliveira Dias

Claudio Gerdau Johannpeter

Expedito Luz

Harley Lorentz Scardoelli

INDAC – Indústria, Administração e Comércio Ltda.

Metalúrgica Gerdau S.A.

Oscar de Paula Bernardes Neto

Richard Chagas Gerdau Johannpeter

Ementa: Irregularidades em operação de aquisição de participações minoritárias em empresas controladas pela Gerdau S.A. Infração aos arts. 116, parágrafo único, 154, c/c 245; 156 e 157, §4º, todos da Lei nº 6.404/76. Infração ao art. 3º, §5º, da Instrução CVM nº 358/02. Infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09. Absoluções e Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1. Por unanimidade:

1.1. Pela aplicação da penalidade de **multa pecuniária de R\$200.000,00** (duzentos mil reais) ao acusado **André Pires de Oliveira Dias**, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Gerdau, por infração ao disposto no art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, combinado com os artigos 14 da Instrução CVM nº 480/09 e 3º, §5º, da Instrução CVM nº

358/02;

1.2. Pela aplicação da penalidade de **multa pecuniária de R\$100.000,00** (cem mil reais) ao acusado **Harley Lorentz Scardoelli**, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Gerdau S.A., por infração ao disposto no art. 14 da Instrução CVM nº 480/09;

1.3. Pela **absolvição** dos acusados **André Bier Gerdau Johannpeter**, **Claudio Gerdau Johannpeter** e **Richard Chagas Gerdau Johannpeter**, na qualidade de membros do conselho de administração da Gerdau S.A., da acusação de infração ao art. 156 da Lei nº 6.404/76;

1.4. Pela **absolvição** dos acusados **André Bier Gerdau Johannpeter**, **Claudio Gerdau Johannpeter**, **Richard Chagas Gerdau Johannpeter**, **Oscar de Paula Bernardes**, **Affonso Celso Pastore** e **Exedito Luz Neto**, na qualidade de membros do conselho de administração da Gerdau S.A., da acusação de infração ao disposto no art. 245 da Lei nº 6.404/76;

1.5. Pela **absolvição** da **INDAC – Indústria, Alimentação e Comércio Ltda.** e da **Metalúrgica Gerdau S.A.** da acusação de infração ao disposto no art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76; e

2. Por maioria, pela absolvição de **André Bier Gerdau Johannpeter**, **Claudio Gerdau Johannpeter**, **Richard Chagas Gerdau Johannpeter**, **Oscar de Paula Bernardes**, **Affonso Celso Pastore** e **Exedito Luz Neto**, na qualidade de membros do conselho de administração da Gerdau S.A., da acusação de infração ao disposto no art. 154 da Lei nº 6.404/76;

Em sua manifestação de voto, o Diretor Carlos Rebello divergiu do voto da Relatora apenas com relação à condenação dos membros do conselho de administração por infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/76, votando por suas absolvições, por entender que os elementos constantes dos autos não permitiram que conclísse que, ao aprovarem a operação, os conselheiros atuaram para favorecer as acionistas controladoras, em detrimento do interesse da companhia.

O Diretor Henrique Machado, em sua manifestação de voto, destacou que, ao avaliar decisões negociais tomadas por administradores de companhias abertas, deve ser adotado o padrão de revisão da *business judgment rule*, segundo a qual, ante a inexistência de pressupostos que demonstrem má-fé, fraude, interesse, ou conflito do administrador, e diante da inexistência de qualquer falha procedimental no respectivo processo decisório, as decisões de um administrador devem, em princípio, ser consideradas regulares. Por essas razões, acompanhou o voto do Diretor Carlos Rebello de absolvição dos membros do conselho de administração da Gerdau, da acusação de infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/76.

O Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, acompanhou integralmente a fundamentação e as conclusões do voto da Relatora. Segundo o Presidente, as circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente o significativo descolamento do preço da operação e o seu reflexo para as controladoras, permitiram concluir que outros interesses, que não aqueles exclusivamente da companhia, prevaleceram no processo decisório do qual tomaram parte os membros do conselho de administração.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19.

Presentes os advogados *Nelson Eizirik*, representante da INDAC – Indústria, Administração e Comércio Ltda.; *Otávio Yazbek* representando os *acusados* Affonso Celso Pastore, Expedito Luz Neto, e Oscar de Paula Bernardes; e *Paulo Aragão*, representando os acusados André Bier Gerdau Johannpeter, André Pires de Oliveira Dias, Claudio Johannpeter, Harley Lorentz Scardoelli, Metalúrgica Gerdau S.A. e Richard Chagas Gerdau Johannpeter.

Presente a Procuradora Federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Flavia Sant'Anna Perlingeiro, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 06/01/2020, às 12:37, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 10/01/2020, às 11:47, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 16/01/2020, às 10:45, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 21/01/2020, às 16:19, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0911945** e o código CRC **62E68B92**.

This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0911945** and the "Código CRC" **62E68B92**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEI Nº 19957.004309/2016-73

Reg. Col. 0463/16

Acusados: André Pires de Oliveira Dias
Harley Lorentz Scardoelli
Claudio Gerdau Johannpeter
André Bier Gerdau Johannpeter
Richard Chagas Gerdau Johannpeter
Exedito Luz
Affonso Celso Pastore
Oscar de Paula Bernardes Neto
INDAC – Indústria Administração e Comércio Ltda.
Metalúrgica Gerdau S.A.

Assunto: Apurar eventuais irregularidades em operação de aquisição de participações minoritárias em empresas controladas pela Gerdau S.A., em suposto descumprimento do disposto nos arts. 116, parágrafo único, 154 c/c 245, 156 e 157, §4º, todos da Lei nº 6.404/1976, art. 3º, §5º, da Instrução CVM nº 358/2002, e art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar eventuais irregularidades em operação de aquisição, pela Gerdau S.A. (“Gerdau” ou “Companhia”), de participações minoritárias em empresas controladas pela Companhia (em conjunto, “Aquisições”), abrangendo ações ordinárias e preferenciais de emissão da Gerdau Açominas S.A., da Gerdau Aços Longos S.A., da Gerdau Aços Especiais S.A. e da Gerdau América Latina Participações S.A. (respectivamente, “Gerdau Açominas”, “Gerdau Aços Longos”, “Gerdau Aços Especiais” e “Gerdau América Latina”, e, em conjunto, “Controladas”), divulgada ao mercado por meio do Fato Relevante de 14.07.2015¹ (“Fato Relevante”), seguido de esclarecimentos prestados no Comunicado ao Mercado de 17.07.2015² (“Comunicado ao Mercado”).

¹ Doc. SEI 0125083, fls. 21-22.

² Doc. SEI 0125083, fls. 26.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2. A Acusação questiona especificamente a atuação dos membros do conselho de administração (“CA”) da Gerdau na aprovação de parte das Aquisições, que, a seu ver, teria sido realizada em condições prejudiciais à Companhia, e dos respectivos diretores de relações com investidores (“DRIs”), por supostas falhas no cumprimento do dever de informar. Adicionalmente, por considerar que a operação configurou, na verdade, uma transferência para a Gerdau de obrigação da controladora indireta da Companhia, a Indac – Indústria Administração e Comércio Ltda. (“INDAC”), garantida pela controladora direta da Gerdau, a Metalúrgica Gerdau S.A. (“Metalúrgica Gerdau”) e, em conjunto com a INDAC, “Controladoras”), a Acusação entendeu tratar-se de operação com partes relacionadas, questionando, também, a atuação das Controladoras.

3. Nesse contexto, foi apurada a responsabilidade de: (a) **André Pires de Oliveira Dias** (“André Pires”), na qualidade de DRI da Gerdau, por violação ao art. 157, §4º³, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), combinado com o art. 14⁴ da Instrução CVM nº 480, de 07.12. 2009, e ao art. 3º, §5º⁵, da Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002; (b) **Harley Lorentz Scardoelli** (“Harley Scardoelli”), na qualidade de DRI da Gerdau, por violação ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009; (c) **Claudio Gerdau Johannpeter** (“Claudio Gerdau”), **André Bier Gerdau Johannpeter** (“André Gerdau”) e **Richard Chagas Gerdau Johannpeter** (“Richard Gerdau”), na qualidade de membros do CA da Gerdau, por violação ao art. 154⁶ combinado com o art. 245⁷

³ Art. 157. (...) § 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.

² Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.

⁵ Art. 3º. Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, (...) e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação. (...) §5º A divulgação e a comunicação de ato ou fato relevante, inclusive da informação resumida referida no §8º, devem ser feitas de modo claro e preciso, em linguagem acessível ao público investidor.

⁶ Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. § 1º O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres. § 2º É vedado ao administrador: a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia; b) sem prévia autorização da assembléia-geral ou do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito; c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembléia-geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo. § 3º As importâncias recebidas com infração ao disposto na alínea c do § 2º pertencerão à companhia. § 4º O conselho de administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais.

⁷ Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

e ao art. 156⁸, todos da LSA; (d) **Exedito Luz, Affonso Celso Pastore** (“Affonso Pastore”) e **Oscar de Paula Bernardes Neto** (“Oscar Bernardes”), também na qualidade de membros do CA da Gerdau, por violação ao art. 154 combinado com o art. 245 da LSA; e (e) **INDAC e Metalúrgica Gerdau**, na qualidade de acionistas controladoras da Gerdau (“Controladoras”), por violação ao art. 116, parágrafo único⁹, da LSA.

4. Destaque-se que, dentre os conselheiros acusados, Oscar Bernardes e Affonso Pastore foram eleitos para o CA da Gerdau como conselheiros independentes (“Conselheiros Independentes”) e que Exedito Luz, ao que consta nos autos, também não tem vínculo com os controladores da Companhia (os Conselheiros Independentes e Exedito Luz referidos, conjuntamente, como “Conselheiros Sem Vínculo”). Já os conselheiros Claudio Gerdau, André Gerdau e Richard Gerdau têm vínculo com os controladores da Companhia, em virtude de serem membros da família Gerdau, que, em última instância, é controladora do grupo econômico do qual a Companhia faz parte (“Grupo Gerdau”), bem como por ocuparem cargos na administração da Gerdau e das Controladoras (“Conselheiros Com Vínculo” e, em conjunto com os Conselheiros Sem Vínculo, simplesmente “Conselheiros”).

5. Este PAS originou-se do Processo CVM nº RJ2015/8486, que teve por objeto analisar reclamação¹⁰ apresentada pela Tarpon Gestora de Recursos S.A., acionista minoritária da Metalúrgica Gerdau, na qual questionou a regularidade da operação conforme referida no Fato Relevante e no Comunicado ao Mercado¹¹ (“Reclamação”).

⁸ Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe a obrigação de declarar o seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse. § 1º Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros. § 2º O negócio contratado com infração do disposto no § 1º é anulável, e o administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido.

⁹ Art. 116. (...) Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.

¹⁰ Doc. SEI 0125083, (fls. 1-20).

¹¹ Alegou, em síntese, que: (i) a divulgação de informação acerca das Aquisições teve impacto negativo imediato e substancial nas cotações das ações de emissão da Gerdau e da Metalúrgica Gerdau; (ii) parte das Aquisições envolvia interesses das Controladoras, tratando-se de operação com partes relacionadas; (iii) o preço pago pela Companhia não seria economicamente justificável, tendo sido praticado em condições não equitativas, em favorcimento das Controladoras; e (iv) houve falha na divulgação das Aquisições ao mercado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II. FATOS

II.1 As Aquisições

6. Em 13.07.2015, o CA da Gerdau aprovou, por unanimidade, a aquisição de participações minoritárias nas Controladas, correspondendo, no agregado, a: (i) 8.801.915 ações ordinárias e 3.545 ações preferenciais de emissão da Açominas; (ii) 9.565.329 ações ordinárias e 3.853 ações preferenciais de emissão da Aços Longos; (iii) 8.801.915 ações ordinárias e 3.545 ações preferenciais de emissão da Aços Especiais; e (iv) 8.801.915 ações ordinárias e 3.545 ações preferenciais de emissão da Gerdau América Latina. Com isso, a Companhia passou a deter mais de 99% do capital total de cada uma das Controladas.

7. O valor global das Aquisições foi de R\$ 1.986.145.695,30, com pagamento da seguinte forma: (i) parcela à vista no valor de R\$ 339.180.000,00; (ii) cessão e transferência de 30.000.000 de ações preferenciais de emissão da Gerdau, pelo valor de R\$ 205.800.000,00; (iii) permuta de cota no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e Não-Padronizados Barzel (“FIDC” ou “Fundo”), cuja carteira detinha um único tipo de direito creditório de titularidade da Companhia decorrente de ações judiciais relativas a diferenças de correção monetária de verbas devidas pela Eletrobrás – Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e pela União (“Direitos Creditórios”), no valor de R\$ 802.329.988,83; e (iv) pagamentos parcelados previstos para 2016, 2017, 2019, 2021 e 2022 no valor total de R\$ 638.835.706,47.

8. A Gerdau divulgou a aprovação pelo CA das Aquisições por meio do Fato Relevante, com as informações agregadas referidas acima e sua justificativa estratégica: “*viabilizar a simplificação e unificar as participações societárias nas companhias operacionais fechadas do Brasil na Gerdau S.A., com vistas à possível transformação dessas companhias, no futuro, em subsidiárias integrais e/ou à sua incorporação; a consolidar o recebimento de dividendos; e a proporcionar a maior facilidade de acesso ao mercado de capitais*”¹².

9. Diante de questionamentos do mercado acerca do preço praticado e da comutatividade da Operação, o Fato Relevante foi complementado pelo Comunicado ao Mercado, o qual informou que a Companhia sempre teve interesse em concentrar a participação nas Controladas, embora não houvesse a obrigação de efetivar as Aquisições, e que não se tratou de operação com partes relacionadas, pois ambas as Aquisições foram negociadas com contrapartes distintas e independentes com relação à Companhia, respectivamente: o Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”) e a ArcelorMittal Netherlands BV (“Arcelor”). Por fim, acrescentou que as Aquisições decorreram de oportunidades de mercado, entendendo a Companhia terem sido praticados preços adequados,

¹² Doc. SEI 0125083, fls. 21.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

levando-se em consideração as avaliações econômicas realizadas, os instrumentos financeiros utilizados, os prazos de pagamento, a captura de valor por meio de um fluxo de caixa mais concentrado e a visão de longo prazo da Gerdau.

10. Conforme consta dos autos, na operação celebrada com a Arcelor, a Gerdau adquiriu: (i) 3.153.714 ações ordinárias e 3.545 ações preferenciais de emissão da Açominas; (ii) 3.153.714 ações ordinárias e 3.545 ações preferenciais de emissão da Aços Especiais; (iii) 3.427.244 ações ordinárias e 3.853 ações preferenciais de emissão da Aços Longos; e (iv) 3.153.714 ações ordinárias e 3.545 ações preferenciais de emissão da Gerdau América Latina (“Participações Arcelor”), para a qual foi convencionado o valor total de R\$ 294.980.000,00, sendo R\$ 89.180.000,00 à vista e o restante a ser pago com a transferência de 30.000.000 ações preferenciais da Gerdau, equivalentes a 1,74% de seu capital total (“Aquisição Arcelor”).

11. Já na operação celebrada com o Itaú, a Gerdau adquiriu: (i) 5.648.201 ações ordinárias de emissão da Açominas; (ii) 5.648.201 ações ordinárias de emissão da Aços Especiais; (iii) 6.138.085 ações ordinárias de emissão da Aços Longos; e (iv) 5.648.201 ações ordinárias de emissão da Gerdau América Latina (“Participações Itaú”). O valor total convencionado foi de R\$ 1.691.165.695,30, com pagamento pactuado da seguinte forma: (a) parcela à vista no valor de R\$ 250.000.000,00; (b) permuta de cota detida pela Gerdau no FIDC, cujos Direitos Creditórios somavam, à época, R\$ 802.329.988,83; e (c) pagamentos parcelados previstos para 2016, 2017, 2019, 2021 e 2022, no valor total de R\$ 638.835.706,47 (“Aquisição Itaú”).

II.2 Contextualização da controvérsia

12. O cerne da questão tratada neste PAS cinge-se, especificamente, à discussão sobre a regularidade da Aquisição Itaú, considerando o respectivo pano de fundo envolvendo interesses das Controladoras. Assim, para melhor compreensão do contexto, a SEP descreveu o histórico da operação que resultou na participação do Itaú como acionista minoritário das Controladas.

13. Em 06.05.2005, no contexto de uma operação estruturada de financiamento para aquisição de investimentos pela Gerdau no exterior, com aproveitamento fiscal de ágio¹³, o Itaú¹⁴ subscreveu e integralizou 325.062.172 ações ordinárias de emissão da Gerdau Participações S.A.¹⁵, no valor de R\$ 550.000.000,00¹⁶. Por força de reorganizações societárias ocorridas, ao longo dos anos, no Grupo Gerdau, tais ações foram convertidas nas Participações Itaú¹⁷.

¹³ Doc. SEI 0125083, fls. 180-181.

¹⁴ À época, denominado Itaú Unibanco S.A.

¹⁵ Subsidiária da Gerdau à época do negócio.

¹⁶ Conforme ata de AGE da Gerdau, realizada em 06.05.2005 (Doc. SEI 0125095, fls. 819-822).

¹⁷ Doc. SEI 0125083, fls. 196-197.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

14. Para que o Itaú dispusesse de um mecanismo de saída do negócio, se assim desejasse, as partes e a Metalúrgica Gerdau, na qualidade de coobrigada solidária, firmaram, em 06.05.2005, o primeiro Instrumento Particular de Opção de Venda de Ações, pelo qual foi outorgada ao Itaú opção de vender a participação adquirida para a INDAC¹⁸.

15. Inicialmente, a Opção de Venda tinha vigência até 31.05.2006, tendo sido subsequentemente renovada, a cada ano, por períodos sucessivos de um ano, até 2010¹⁹. Em 31.05.2010 (“Data Inicial”), a INDAC, a Metalúrgica Gerdau e o Itaú firmaram nova Opção de Venda (“Opção de Venda” ou “PUT”)²⁰, com duração de cinco anos, com vencimento em 29.05.2015 (“Data de Exercício”) e com preço de exercício (“Preço de Exercício”) no valor de R\$ 955.652.600,15, acrescido de remuneração equivalente à capitalização diária das taxas médias relativas a operações com Certificados de Depósito Interfinanceiro de prazo igual a um dia útil (“Taxa DI”), acrescida de 3,00% ao ano, a partir da Data Inicial até a Data de Exercício, deduzido do valor correspondente a 100% do montante total pago pelas Controladas ao Itaú a título de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio no período, devidamente corrigidos pela Taxa DI acrescida de 3,00% ao ano, entre a data do efetivo recebimento pelo Itaú e a Data de Exercício²¹.

16. Em 27.05.2015, 29.06.2015 e 08.07.2015, a Data de Exercício foi sucessivamente prorrogada, tendo sido finalmente fixada em 07.08.2015²², data em que perdeu o objeto, tendo em vista que, como consequência da Aquisição Itaú, a obrigação de compra da INDAC para com o Itaú pelo exercício da PUT deixou de existir, uma vez que as Participações Itaú foram integralmente alienadas pelo Itaú para a Gerdau.

III. ACUSAÇÃO

17. Ante os termos da Reclamação e com vistas ao esclarecimento dos fatos, a SEP apurou, primeiramente, que as duas operações, a despeito de terem por objeto a aquisição de participações nas mesmas sociedades (i.e. nas Controladas), guardavam entre si discrepâncias que, no seu entendimento, uma vez reveladas e comparadas, levaram ao questionamento da regularidade da Aquisição Itaú, em especial no que se refere ao preço pago pela Gerdau pelas Participações Itaú quando comparado ao preço pago pelas Participações Arcelor e às condições negociais avençadas.

18. Ao examinar, em separado, cada uma das operações, a SEP entendeu que não havia irregularidade a ser apurada com relação à Aquisição Arcelor, tendo sido utilizada apenas como

¹⁸ Doc. SEI 0125088, fls. 305-309.

¹⁹ Doc. SEI 0125088, fls. 311-334.

²⁰ Instrumento Particular de Opção de Venda de Ações e Outras Avenças N° 100810050000100 (fls. 342-349).

²¹ Doc. SEI 0125088, fls. 336-340.

²² Doc. SEI 0125088, fls. 361-370.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

parâmetro na análise da regularidade da Aquisição Itaú, uma vez que ambas as operações foram contemporâneas e tiveram por objeto a negociação de ativos de mesma espécie.

19. De acordo com a SEP, para fins de comparação, se o preço por ação das Controladas pago na Aquisição Arcelor também tivesse sido praticado pela Gerdau na Aquisição Itaú, chegar-se-ia à conclusão de que, proporcionalmente, a Gerdau pagou, pelas Participações Itaú, 3,2 vezes o preço que teria pago se as tivesse negociado nas mesmas condições contratadas com a Arcelor²³, o que indicaria um sobrepreço.

20. Embora não tenha deixado de reconhecer que são esperadas eventuais diferenças resultantes de processos negociais independentes envolvendo contrapartes distintas, ainda que relativas a participações nas mesmas companhias, no caso concreto, a SEP destacou que a operação tida entre a Companhia e a Arcelor, uma parte independente e conhecedora do negócio, deve servir como referência de valor justo dos ativos negociados.

21. Ademais, para a Acusação, o próprio laudo de avaliação contratado no âmbito das Aquisições revelava o sobrepreço pago pelas Participações Itaú. Utilizando-se de taxa de câmbio do Dólar Comercial PTAX, da data-base de 31.12.2014²⁴ (i.e., R\$ 2,65), para a conversão para reais dos valores expressos em dólar no laudo, a SEP apontou sobrepreço em faixa situada entre R\$ 640.000.000,00 e R\$ 870.000.000,00.

22. Não obstante as justificativas apresentadas pela Gerdau, no sentido de que as condições de pagamento aceitas pelo Itaú motivaram a aprovação do alegado sobrepreço²⁵, especialmente se considerada a proposta para a estruturação do FIDC – que seria mais vantajosa do que a segunda melhor proposta recebida pela Gerdau pelo ativo, a SEP argumentou que tal vantagem, embora existente, não chega à metade do menor parâmetro de sobrepreço identificado.

23. Na visão da Acusação, a Gerdau não apresentou, no âmbito das investigações, qualquer outro motivo capaz de justificar o preço praticado na Aquisição Itaú e a referência de valor da Companhia era, em verdade, a obrigação de suas Controladoras para com o Itaú em razão da PUT, cujos parâmetros para definição de preço fogem ao valor de mercado dos ativos, à época.

24. Nesse cenário, a Acusação contestou o fato afirmado pela Gerdau, no Comunicado ao Mercado, de que a Aquisição Itaú não teria configurado operação com partes relacionadas, pois, a seu ver, considerando-se o sobrepreço pago pelas Participações Itaú e a própria existência da PUT

²³ Para esse cálculo, a Acusação considerou os seguintes valores: (i) R\$22,99 por ação de emissão da Açominas; (ii) R\$45,74 por ação de emissão da Aços Longos; (iii) R\$7,50 por ação de emissão da Aços Especiais; e (iv) R\$13,23 por ação de emissão da Gerdau América Latina. Esses valores, multiplicados pela quantidade de ações de emissão de cada uma das Controladas adquiridas pela Gerdau na Aquisição Itaú, totalizariam R\$ 527.706.554,03.

²⁴ Doc. SEI 0125090, fls. 404.

²⁵ Doc. SEI 0125090, fls. 512.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

em valor equivalente àquele praticado na Aquisição Itaú, restou claro que se tratou, em verdade, de mera transferência de obrigação das Controladoras para a Gerdau, que arcou com o ônus de uma obrigação que não era sua.

25. Tais conclusões levaram em conta que: (i) na data de fechamento da Aquisição Itaú, o Itaú tinha contra a INDAC a PUT que recaía justamente sobre os mesmos ativos, as Participações Itaú; (ii) o Formulário de Referência, referente ao exercício findo em 2015, da Metalúrgica Gerdau, garantidora da obrigação da INDAC para com o Itaú, no caso do exercício da Opção de Venda, informava que o valor dessa obrigação totalizava uma garantia de R\$ 1.565.085.000,00, em 31.12.2014; (iii) os valores atualizados da Opção de Venda na data imediatamente anterior à aprovação pelo CA (13.07.2015) totalizavam R\$ 1.691.145.000,00; (iv) o Preço de Exercício, nos termos da PUT, era praticamente equivalente ao valor pago pela Gerdau ao Itaú; e (v) o CA da Gerdau deliberou sobre a Aquisição Itaú, não apenas sabendo da existência da PUT, mas considerando o respectivo valor envolvido, conforme demonstra material apreciado pelo CA²⁶.

26. A despeito de a Companhia afirmar que o preço era o exigido pelo Itaú para vender as Participações Itaú, já que podia vendê-las por tal preço para terceiros (i.e., a INDAC), a SEP pontuou não haver quaisquer elementos que indicassem a existência de um agente independente desejando pagar tal preço pelas Participações Itaú. Portanto, para a SEP, a Opção de Venda não era apenas um balizador de preço, mas o próprio racional da Aquisição Itaú.

27. Nesse sentido, a Acusação destacou que o próprio material submetido ao CA mostra que o Itaú vinha manifestando o interesse em realocar investimentos, o que teria sido, no entendimento da SEP, fator decisivo para início das tratativas.

28. Além disso, a Acusação ponderou que as Controladoras assumiram a obrigação de adquirir as Participações Itaú, tendo ficado expostas ao risco decorrente de eventuais diferenças de variação entre o preço de mercado dos ativos e o valor de referência da Opção de Venda, e que não havia qualquer motivo para acreditar que tal obrigação pudesse recair sobre a Gerdau.

29. Segundo a SEP, após diversas renovações, a PUT tornou-se extremamente favorável para o Itaú, descolando-se do preço de mercado dos ativos. Assim, a despeito das negativas das Controladoras, a SEP entendeu haver inequívoco e incontroverso benefício à INDAC e à Metalúrgica Gerdau na ocorrência da Aquisição Itaú, tendo em vista que, ao adquirir as Participações Itaú, a Gerdau as eximiu de obrigação no montante de R\$ 1,69 bilhões, correspondente ao exercício da Opção de Venda e respectiva garantia, às custas dos recursos da Companhia e, via de consequência, dos interesses dos demais acionistas da Gerdau.

²⁶ Doc. SEI 0125090, fls. 505-522.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

30. Assim, a SEP concluiu que a Aquisição Itaú se traduziu em mera transferência de obrigações entre a INDAC e a Gerdau, tudo com o conhecimento e consentimento do CA da Gerdau, que aprovou a operação ciente de todas as nuances envolvidas, em especial, a existência da PUT e o fato de que o preço inflado pago em relação ao preço dos ativos negociados com parte independente tinha correspondência direta com o Preço de Exercício da PUT.

31. No tocante à aprovação da Operação pelo CA da Gerdau, a Acusação considerou que os conselheiros atuaram com desvio de poder, em infração ao art. 154 da LSA, fazendo a Companhia arcar com um vultoso valor pela aquisição das Participações Itaú, impactado, de forma relevante, por contrato previamente existente entre o Itaú e as Controladoras, desonerando-as das respectivas obrigações contratualmente assumidas.

32. Ademais, para a SEP, os conselheiros Claudio Gerdau, André Gerdau e Richard Gerdau também atuaram em conflito de interesses, em infração ao art. 156 da LSA, já que os dois primeiros compartilhavam funções de administradores tanto na Gerdau quanto na INDAC, e o último figurou, em aditivos à Opção de Venda, na condição de procurador da INDAC. Como fundamento para tal irregularidade, a SEP considerou, ainda, o fato de a INDAC ser controlada, por meio de outras empresas, exclusivamente pela família dos Conselheiros com Vínculo, mais especificamente por seus pais, de quem são herdeiros diretos, o que a levou à conclusão de que foram diretamente beneficiados com a aprovação da Aquisição Itaú.

33. Embora a aprovação da Aquisição Itaú tenha se dado no âmbito do CA da Gerdau, a Acusação repisou que as Controladoras têm deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da Companhia e, por isso, estariam obrigadas a adotar providências compatíveis com a relevância e a gravidade dos fatos relacionados à Aquisição Itaú. Por não tê-lo feito, considerou que as Controladoras infringiram o disposto no art. 116, parágrafo único, da LSA.

34. A SEP registrou, ainda, que, na forma como divulgada, a informação sobre as Aquisições foi tratada pela Gerdau como sendo uma única operação, quando, na realidade, tratava-se de duas operações completamente distintas, envolvendo diferentes vendedores e condições contratuais diferenciadas, conforme relatado acima.

35. Para a SEP, a Aquisição Itaú foi informada de forma insuficiente e incompleta ao mercado, uma vez que, ao conferir tratamento conjunto às duas operações, a Companhia levou o mercado a avaliar, na média, Aquisições compostas por duas negociações independentes, relacionadas entre si unicamente por terem como objeto participações acionárias minoritárias nas mesmas companhias, impedindo que o investidor pudesse conhecer e avaliar as reais condições das Aquisições, inclusive os preços pagos pela Gerdau às respectivas contrapartes, que foram



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

significativamente diferenciados e, no que diz respeito à Aquisição Itaú, extremamente desfavoráveis para a Companhia.

36. Com isso, a SEP entendeu caracterizada a responsabilidade dos DRIs, André Pires, responsável pela divulgação do Fato Relevante, por violação ao disposto no art. 157, §4º, da LSA c/c o art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009 e o art. 3º, §5º, da Instrução CVM nº 358/2002, e Harley Scardoelli, responsável pela divulgação do Comunicado ao Mercado, por descumprimento ao disposto no art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009.

IV. RESPONSABILIDADES

37. Obtidos os esclarecimentos por parte dos administradores da Gerdau e das Controladoras e sopesando (i) o mandato dos administradores da Gerdau e o momento em que os atos foram praticados; (ii) a estrutura de controle da Companhia e a participação acionária, bem como os cargos ocupados pelos membros do CA da Gerdau nas Controladoras, a SEP, em 29.06.2016, apresentou Termo de Acusação²⁷ propondo a responsabilização de:

- (a) **André Pires**, na qualidade de ex-DRI da Gerdau, pelo descumprimento do **art. 157, §4º, da LSA, c/c o art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009 e o art. 3º, §5º, da Instrução CVM nº 358/2002**, por divulgar o Fato Relevante de 14.07.2015, apenas com informações globais de duas operações independentes, omitindo informações sobre cada uma delas e o fato de que as condições da Aquisição Itaú foram afetadas por contratos previamente existentes, firmados entre o Itaú e as Controladoras;
- (b) **Harley Scardoelli**, na qualidade de DRI da Gerdau, pelo descumprimento do **art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009**, por divulgar, no Comunicado ao Mercado do dia 17.07.2015, informações inconsistentes e incompletas, afirmando que as operações não se tratavam de “operações com acionista controlador ou partes relacionadas”, quando as condições da Aquisição Itaú foram impactadas de forma relevante por contratos previamente existentes, firmados entre o Itaú e as Controladoras, e que tal aquisição desonerou as Controladoras das obrigações decorrentes desses contratos;
- (c) **Claudio Gerdau**, na qualidade de Presidente do CA da Gerdau, pelo descumprimento do **art. 154 c/c o art. 245 e do art. 156, da LSA**, por aprovar a Aquisição Itaú nas condições acima mencionadas;
- (d) **André Gerdau e Richard Gerdau**, na qualidade de membros do CA da Gerdau, pelo descumprimento do **art. 154 c/c o art. 245 e do art. 156, da LSA**, por aprovar a Aquisição Itaú nas condições acima mencionadas;
- (e) **Exedito Luz, Affonso Pastore e Oscar Bernardes**, na qualidade de membros do CA da Gerdau, pelo descumprimento do **art. 154 c/c o art. 245 da LSA**, por aprovar a Aquisição Itaú nas condições acima mencionadas; e

²⁷ Doc. SEI 0125258.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(f) **INDAC e Metalúrgica Gerdau**, na qualidade de controladoras da Gerdau, pelo descumprimento do **art. 116, parágrafo único, da LSA**, por, tendo tomado conhecimento da proposta e da aprovação de realização de operação que iria beneficiá-las em detrimento da Gerdau e de seus acionistas, deixar de adotar providências compatíveis com a relevância e a gravidade dos fatos relacionados à realização do negócio.

V. MANIFESTAÇÃO DA PFE

38. Em 28.07.2016, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) proferiu parecer²⁸ no sentido de que a peça acusatória preencheu os requisitos constantes do art. 6º²⁹ e atendeu ao disposto art. 11 caput³⁰, todos da então vigente Deliberação CVM nº 538/2008³¹.

39. A PFE destacou, ainda, a possibilidade teórica de imputação conjugada de responsabilidade por atuação em desvio de poder e em situação de conflito de interesses, nos seguintes termos:

“Sobre a possibilidade de imputação conjugada de responsabilidades por atuação em desvio de poder e em situação de conflito de interesses, vale mencionar os processos administrativos sancionadores nºs RJ 2011/14269 e 02/2004. Neste último, a ex-Diretora Norma Jonssen Parente, no que foi acompanhada pelos demais, ao analisar a preliminar de *bis in idem* registrou que, *verbis*:

‘Em virtude da suposta utilização não autorizada de recursos das companhias, alguns indiciados foram responsabilizados por infração ao art. 154 e ao art. 156, ambos da Lei 6.404/76. 18. Há aí, a meu ver, um certo excesso. Não que seja impossível, em tese, a cumulação entre infrações a estes dispositivos. Figure-se, por exemplo, a hipótese em que um administrador utiliza recursos da companhia sem autorização para tanto – infração ao art. 154, §2º – e, ademais, o faz em condições não equitativas – infração ao art. 156, §1º. Neste caso, estar-se-ia diante de dois ilícitos, razão pela qual se poderia pensar em duas sanções. (...)’.”³²

²⁸ Doc. SEI 0140356.

²⁹ Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, (...).

³⁰ Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

³¹ Revogada pela Instrução CVM nº 607, de 17.06.2019.

³² Doc. SEI 0140356, fls. 4.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

40. Com isso, concluiu a PFE que, uma vez demonstrada a violação a bens jurídicos diversos e não sendo o caso de conflito aparente de normas, a demandar a aplicação dos princípios da especialidade ou da consunção, é possível, ao menos em tese, a conjugação das responsabilidades pela violação ao disposto nos arts. 154 e 156 da LSA.

VI. DAS DEFESAS

41. Em 16.08.2016, os Acusados foram devidamente intimados³³. Em 21.10.2016, apresentaram, tempestivamente, defesas conjuntas em dois blocos: (i) Claudio Gerdau, André Gerdau e Richard Gerdau, e os DRIs, André Pires e Harley Scardoelli³⁴; e (ii) Affonso Pastore, Expedito Luz e Oscar Bernardes³⁵. Na mesma data, apresentaram defesas individuais tempestivas a INDAC³⁶ e a Metalúrgica Gerdau³⁷ (todas, em conjunto, “Defesas”).

VI.2 DEFESA CONJUNTA DOS CONSELHEIROS COM VÍNCULO E DOS DRIS

42. De acordo com esses Acusados, como informado no Fato Relevante, o objetivo das Aquisições foi o de concentrar participação nas Controladas, o que já vinha sendo perseguido de longa data pela administração da Companhia. Na medida em que a Gerdau fosse titular de 100% das participações nas Controladas, diversas providências societárias e despesas relacionadas a sociedades com multiplicidade de acionistas passariam a ser dispensadas, proporcionando uma redução de custos, bem como seriam alcançadas a simplificação e a agilidade necessárias para a captação de recursos pela Gerdau, notadamente nos mercados de dívida internacionais³⁸, com resultados que beneficiariam a todos os acionistas da Companhia.

43. A concentração de participação nas Controladas também tornaria mais simples eventual incorporação em reorganização societária, o que estava em linha com o histórico da Companhia, que, no passado, já havia incorporado sociedade controlada buscando aumentar eficiências, reduzir custos e simplificar a estrutura societária.

³³ Docs. SEI 0147160-0147162 e 0147164-0147170.

³⁴ Doc. SEI 0184204.

³⁵ Doc. SEI 0184235.

³⁶ Doc. SEI 0179008.

³⁷ Doc. SEI 0184198.

³⁸ Segundo alegam, tal processo é facilitado quando todas as empresas, que geram fluxos de caixa da companhia e que são garantidoras em operações de captação de recursos no exterior, são subsidiárias integrais da emissora, pois, nesse caso, não é exigida a apresentação de demonstrações financeiras de todas as empresas envolvidas na operação, conforme exceções previstas na regra sobre *Financial statements of guarantors and issuers of guaranteed securities registered or being registered* da Securities and Exchange Commission – SEC.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

44. Asseveraram que, entre os anos de 2004 e 2005, o Grupo Gerdau passou por um processo de avaliação de opções para gerar mais valor para os acionistas da Companhia, o que foi, inclusive, objeto de análise pela consultoria Booz Allen Hamilton, cujo relatório final, de 07.07.2005 (“Relatório Booz Allen”), abordou a reorganização da Gerdau e investimentos internacionais.

45. Nessa linha, expuseram que, entre os anos de 2005 e 2009, a Gerdau adquiriu consistentemente participações minoritárias nas Controladas, por meio de várias operações, elevando sua participação próxima a 89% para aproximadamente 94% do capital social dessas sociedades, e que, em 2015, após as Aquisições, essa participação passou para 99% do capital social das Controladas.

46. No que tange à Aquisição Itaú, especificamente, sustentaram que essa não foi concebida com a finalidade de beneficiar as Controladoras, mas sim como uma forma de perseguir os objetivos elencados acima, no interesse da Companhia. Segundo tais Acusados, em que pese a leitura do Termo de Acusação possa levar à conclusão (a seu ver equivocada) de que a Gerdau teria pago mais de um bilhão de reais ao Itaú, com a finalidade de exonerar a INDAC das obrigações assumidas no âmbito da Opção de Venda, em verdade, a Aquisição Itaú corresponderia à reversão do aporte de capital feito pelo Itaú em controlada da Gerdau, a Gerdau Participações S.A. (“Gerdau Participações”), em 06.05.2005, com a finalidade de viabilizar a realização, pela Companhia, de um investimento no exterior³⁹ (“Aporte de Capital”).

47. Observaram que o Aporte de Capital teria beneficiado todos os acionistas da Gerdau Participações e a sua controladora, a Gerdau, mas, por outro lado, exceto na mesma medida em que beneficiou todos os demais acionistas da Companhia, o Aporte de Capital não teria acarretado nenhum benefício específico às Controladoras.

48. Em razão de reorganizações societárias ocorridas ao longo do tempo, tais Acusados destacaram que a participação adquirida pelo Itaú na Gerdau Participações passou a ser representada por ações das Controladas (as Participações Itaú). Assim, considerando que o valor aportado pelo Itaú na Gerdau Participações, em 06.05.2005, totalizava R\$ 550 milhões, o mesmo valor, corrigido até a data da Aquisição Itaú, corresponderia a aproximadamente R\$ 1.694 milhões. Consoante os Acusados, foi essa a análise feita pela administração da Companhia antes de tomar a decisão sobre a realização da Aquisição Itaú⁴⁰.

³⁹ A partir de tal capitalização, equivalente, pelo câmbio da época, a aproximadamente 220 milhões de dólares, foram viabilizadas aquisições de participações de 40,49% das ações de emissão da Sipar Gerdau Inversiones S.A., passando o Grupo Gerdau a ser titular de 83,77% de seu capital social, conforme divulgado em Comunicado ao Mercado em 16.09.2005, bem como de participações de 40% do capital social da Corporación Sidenor, S.A., conforme divulgado em Fato Relevante, de 15.11.2005 (Doc. SEI 0184204, fls.11, item 40).

⁴⁰ Conforme Doc. SEI 0125090, fls. 505 e 522.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

49. Para tais Acusados, a Aquisição Itaú representou algo equivalente ao desfazimento do Aporte de Capital, operação prévia contratada com a mesma parte independente, o Itaú, não havendo que se falar em envolvimento de parte relacionada. Tal conclusão seria ainda mais evidente se fosse considerado que a operação prévia pode ser entendida como algo próximo a um financiamento, como reconheceu a própria Acusação no Termo de Acusação.

50. No que tange à definição do preço pago nas Aquisições, os Acusados lembraram que as Participações Arcelor também estiveram sujeitas a uma opção de compra por parte do Banco Econômico, com vencimento em novembro de 2003, no valor de R\$ 86.220 mil, a qual não foi exercida pelo interventor do Banco Central do Brasil. Esse elemento fez parte da avaliação das Participações Arcelor pelos administradores da Companhia, de forma “*que, mesmo não estando a Gerdau obrigada a tratar de forma idêntica suas contrapartes, houve compatibilidade entre os pagamentos feitos tanto à Arcelor quanto ao Itaú (e ainda que, por outros fatores, o preço por ação, considerado na data [da Operação], tenha sido nominalmente diferente, na prática foi semelhante, quando consideradas as ponderações indispensáveis)*”⁴¹.

51. Com vistas a comprovar que a Aquisição Itaú foi comutativa, os Acusados traçaram um paralelo com o analisado no PAS CVM nº RJ2012/11199, julgado em 22.03.2016, em que o Colegiado decidiu que participação adquirida por acionista controlador em sua controlada e vendida a terceiros, depois de um período de oito meses, por valor superior em 38% ao preço de aquisição, não demonstrou a inobservância de padrões de mercado. Naquele caso, o preço praticado na venda do ativo correspondia ao preço pago pelo controlador, corrigido por mais de seis vezes o CDI da época, enquanto o preço pago pela Companhia pelas Participações Itaú correspondeu ao preço histórico pago pelo Itaú corrigido pelo CDI, além de a Aquisição Itaú não ter envolvido operação da Gerdau com controlador ou partes relacionadas.

52. Argumentaram que o valor pago pelas Participações Itaú foi compatível com o valor de mercado, considerando-se (i) outras operações com partes variadas, (ii) o valor apurado no laudo de avaliação preparado em 2015 pela Apsis Consultoria Empresarial Ltda., contratada para avaliar os ativos negociados no âmbito das Aquisições (“Laudos Apsis”), e (iii) a Aquisição Arcelor.

53. No que tange ao Laudo Apsis, os Acusados argumentaram que o gasto efetivo da Gerdau com a aquisição das Participações Itaú foi inferior ao valor máximo apurado em referido laudo, considerando que este tomou por base valores denominados em dólares norte-americanos. A seu ver, ao converter os valores apontados no Laudo Apsis para reais, a Acusação equivocou-se, pois utilizou a cotação do dólar em 31.12.2014, a data-base informada no referido laudo, e não em 10.07.2015, último dia útil anterior à aprovação das Aquisições, como foi feito nos sumários dos

⁴¹ Doc. SEI 0184204, fls. 13, item 49.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

laudos de 2016 preparados também pela Apsis para atender especificamente à Lei nº 12.973/2014, que trata dos requisitos necessários para o futuro aproveitamento fiscal do ágio pago na aquisição das participações societárias (“Laudos Apsis 12.973/2014”).

54. Para tais Acusados, esse equívoco levou a Acusação à conclusão de que o valor pago ao Itaú havia superado os valores então apurados por R\$ 634 milhões a R\$ 872 milhões, quando, na realidade, considerando a cotação do dólar a R\$ 3,19, em 10.07.2015, o valor máximo apurado no Laudo Apsis para as Participações Itaú seria de R\$ 1.272 milhões, valor este que foi, inclusive, utilizado nos Laudos Apsis 12.973/2014⁴².

55. Não obstante a questão da taxa de conversão cambial apontada acima, os Acusados argumentaram que a avaliação do preço pago na Aquisição Itaú também levou em consideração os efeitos fiscais dela decorrentes e a vantagem da proposta do Itaú para a estruturação do FIDC.

56. Com relação ao FIDC, apontaram que a própria Acusação reconheceu que a proposta do Itaú para a estruturação do fundo foi mais vantajosa, em R\$ 317 milhões, do que a proposta do Banco Safra (segunda melhor proposta para o ativo recebida pela Gerdau). Já com relação ao benefício fiscal, afirmaram que seria calculado sobre a diferença entre o preço pago (R\$ 1.691 milhões) e o valor patrimonial das Participações Itaú (R\$ 541 milhões), isto é, R\$ 1.150 milhões, estimando-se que, em termos de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, corresponderia a 34% de R\$ 1.150 milhões, ou seja, aproximadamente R\$ 390 milhões. Observaram, contudo, que esse valor não foi considerado no Laudo Apsis.

57. Dessa forma, com base nos valores indicados a seguir, tais Acusados concluíram que o preço pago ao Itaú era perfeitamente compatível com o Laudo Apsis, quando submetido às correções que seriam feitas por qualquer administrador diligente⁴³:

Laudo Apsis: Valor Máximo, com cotação do dólar em 10.07.2015	R\$ 1.272 milhões
Benefício FIDC-NP Barzel	R\$ 317 milhões
Benefício fiscal	R\$ 390 milhões
Total	R\$ 1.979 milhões

58. Destacaram que, mesmo se fosse deduzido da conta acima o custo fiscal do ganho obtido com o uso do FIDC, da ordem de R\$ 108 milhões, chegar-se-ia a um preço justo de R\$1.871 milhões, que ainda seria superior ao efetivamente pago pela Gerdau na Aquisição Itaú.

⁴² Doc. SEI 0184204, fls. 113-160, doc. 03.

⁴³ Doc. SEI 0184204, fls. 18, item 75.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

59. Segundo os Acusados, a administração da Gerdau considerou todos os referidos elementos, como teria feito em qualquer outra operação que analisasse, de modo que não poderia ser julgada a partir de uma visão parcial e incompleta das variáveis envolvidas no negócio.

60. Como argumento adicional, apontaram para a possibilidade de a Companhia vir a receber valores extras relativos ao FIDC, tendo em vista que o Contrato de Cessão, por meio do qual a Gerdau cedeu direitos creditórios ao fundo, prevê, na cláusula 3.2.a e no Anexo 3⁴⁴, um ajuste de preço em que a Gerdau receberia 80% da eventual diferença positiva entre: (i) o valor a ser efetivamente recebido pelo FIDC em cada ação judicial, quando da decisão final, inapelável e transitada em julgado; e (ii) o valor pago pelo FIDC em contrapartida à cessão dos respectivos direitos creditórios, atualizado conforme a fórmula indicada no contrato.

61. Com isso, tais Acusados concluíram que, considerando a diferença entre os valores atualizados e os valores pelos quais os direitos creditórios foram cedidos (*upside*), no valor de R\$ 411 milhões, a Gerdau poderia receber até R\$ 329 milhões adicionais⁴⁵. Ainda com relação ao preço pago pelas Participações Itaú, alegaram que a administração da Gerdau também considerou os valores gastos com as aquisições e permutas de participações nas Controladas desde 2005, e que estes valores, devidamente atualizados pela Taxa CDI até 30.06.2015, demonstram que o preço médio pago pela Companhia por ação em cada uma delas, entre os anos de 2005 e 2009, foi mais alto do que o preço pago na Aquisição Itaú. Esse dado, no entendimento dos Acusados, indicaria que um agente independente desejaria pagar o preço pago pelas Participações Itaú.

62. Finalmente, quanto à comparação feita pela Acusação dos preços pagos ao Itaú e à Arcelor, ponderaram que *“as negociações com partes diferentes estão sempre sujeitas a diversos fatores, por vezes difíceis de quantificar objetivamente, mas que sempre exercem influência significativa na transação”*⁴⁶.

63. Com efeito, os Acusados alegaram que parte do preço na Aquisição Arcelor foi pago mediante entrega de ações de emissão da Gerdau, e que não seria adequado considerar a respectiva cotação em um dia determinado para precificar a contraprestação paga pela Companhia, tendo em vista que a administração acreditava que o valor da Companhia era superior àquele apurado em 08.07.2015, data usada como referência. Asseveraram, inclusive, que as ações da Gerdau estavam em patamares historicamente baixos e, a partir de tal data, os ativos apresentaram significativa valorização, passando de R\$ 6,86 para R\$ 10,23 na data da apresentação da respectiva Defesa.

⁴⁴ Doc. SEI 0125090, fls. 538, 574-576.

⁴⁵ Doc. SEI 0184204, fls. 19, item 82.

⁴⁶ Doc. SEI 0184204, fls. 20, item 89.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

64. Assim, concluíram pela impossibilidade de se afirmar que o preço pago ao Itaú correspondeu a 3,2 vezes o preço pago à Arcelor, pois, em transações complexas, como as Aquisições, não é possível reduzir cada etapa a um cálculo exato para tornar perfeitamente equivalentes pagamentos feitos em condições substancialmente diferentes. Sustentaram que, em relação à Aquisição Itaú, há que se considerar as formas de pagamento avençadas e, em relação à Aquisição Arcelor, o real valor das ações da Gerdau envolvidas na operação.

65. Assim, tais Acusados, com base no que classificam como “ajustes elementares”, chegaram às seguintes conclusões quanto aos preços comparativos das duas operações⁴⁷:

VALOR PAGO AO ITAÚ AJUSTADO		VALOR PAGO À ARCELOR AJUSTADO	
Valor considerado pela Acusação (a)	R\$1.691 milhões	Valor considerado pela Acusação (ação = R\$6,86)	R\$294 milhões
Benefício FIDC (b)	(R\$317 milhões)	Valor em dinheiro (a)	R\$89 milhões
Benefício Fiscal (c)	(R\$390 milhões)	Ações (R\$ 15,90 ⁴⁸) (b)	R\$477 milhões
Total (a-b-c)	R\$ 984 milhões	Total (a+b)	R\$566 milhões

66. Com isso, para esses Acusados, o valor total das Aquisições, ajustado pelas formas de pagamento, seria de R\$ 1.550 milhões (R\$ 984 milhões + R\$ 566 milhões). Além disso, a seu ver, considerando-se a proporção entre ações compradas da Arcelor e do Itaú e o preço global pago, tem-se que, embora os números de ações sejam diferentes, a proporção seria a mesma⁴⁹:

ARCELOR	ITAÚ	PERCENTUAL ITAÚ
3.157.259	5.648.201	64,14%
3.157.259	5.648.201	64,14%
3.157.259	5.648.201	64,14%
3.431.097	6.138.085	64,14%

67. No seu entendimento, esta proporção indica que o custo proporcional das ações do Itaú situa-se na mesma faixa do custo das ações da Arcelor, pois, uma vez aplicada a proporção de 64,14% ao preço ajustado global de R\$ 1.550 milhões, chega-se ao montante de R\$ 992 milhões. Disso decorre que a diferença entre o preço ajustado atribuível ao Itaú (R\$ 992 milhões) e o preço

⁴⁷ Doc. SEI 0184204, fls. 22, item 101.

⁴⁸ Preço alvo indicado no Relatório da BB Investimentos, de 07.05.2015 (Doc. SEI 0184204, fls. 167-172).

⁴⁹ Doc. SEI 0184204, fls. 23, item 103.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

pago (R\$ 984 milhões) é pequeno e, mesmo que se considerasse os R\$ 108 milhões de tributação sobre o FIDC, o valor recebido pelo Itaú ainda corresponderia a cerca de 1,02x o valor teórico.

68. Tais Acusados argumentaram, ainda, que, ao cotejar-se o que seria o preço “Arcelor”⁵⁰ com o preço pago ao Itaú, chegar-se-ia a uma relação de aproximadamente 0,97x (ou aproximadamente 1,07, se considerado o imposto relativo ao FIDC) e não de 3,2x, como sustenta a Acusação. Além do que, deve ser considerado que os ativos recebidos pelo Itaú eram menos líquidos do que aqueles entregues à Arcelor, o que não foi refletido nos cálculos acima, assim como a possibilidade de a Gerdau vir a receber valores adicionais em eventuais ajustes dos Direitos Creditórios no âmbito do FIDC, conforme mencionado.

69. Tudo isso demonstra, sob a ótica desses Acusados, que os preços pagos ao Itaú e à Arcelor foram compatíveis e, mesmo que não tivessem sido, a diferença de preços não configuraria uma irregularidade, pois a Gerdau pode perfeitamente pagar um preço a um vendedor, se adequado, e um preço inferior a outro, já que a economia obtida nesta última aquisição reverterá em benefício a todos acionistas. Argumentaram que, como a Acusação reconheceu que diferenças de preços são esperadas, não pode usar a mesma diferença para embasar sua tese acusatória.

70. Tais Acusados passaram, então, a explicar por que a Aquisição Itaú não beneficiou a INDAC e a Metalúrgica Gerdau, alegando que, ao passo em que a obrigação prevista na Opção de Venda deixou de existir, a compra das ações do Itaú representava um negócio adequado e vantajoso para a Gerdau e, justamente por este motivo, o negócio foi aprovado pelo CA.

71. Na visão desses Acusados, apesar de a Acusação defender que a Gerdau só comprou as ações detidas pelo Itaú pelo preço ajustado porque era o preço pelo qual o Itaú estava disposto a vender tais ativos, isto, além de óbvio, não constitui prova ou indício de qualquer irregularidade.

72. No que tange à aplicabilidade do art. 245 da LSA à Aquisição Itaú, alegaram que a operação não envolveu sociedades coligadas, controladora ou controlada, tendo sido negociada entre a Gerdau e o Itaú, partes independentes entre si, o que torna inaplicável o referido dispositivo legal neste caso. E, o fato de a administração ter deliberado o negócio tendo ciência da existência da Opção de Venda, em sua opinião, em nada altera o acima exposto, pois a Gerdau não teria assumido qualquer ônus relacionado àquela operação, uma vez que apenas comprou de terceiros participações por estes detidas nas Controladas, como já havia feito ao longo dos anos.

⁵⁰ Isto é, o valor pago à Arcelor multiplicado por 1,79 (correspondente à participação do Itaú dividida pela da Arcelor), o que corresponderia a R\$ 1.013 milhões (R\$ 566 milhões x 1,79) (Doc. SEI 0184204, fls. 23, item 106).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

73. Quanto à imputação feita aos conselheiros de administração, de infração ao art. 154 da LSA, argumentaram que a Acusação se baseou apenas no fato de o preço pago pelas Participações Arcelor ter sido mais baixo do que aquele pago pelas Participações Itaú, em razão da existência da Opção de Venda, sem considerar todas as diferenças apontadas ao longo da respectiva Defesa. Como a própria Acusação admitiu, eventuais diferenças de preço resultantes de processos negociais diferentes são esperadas, tendo sido a Aquisição Itaú realizada a preço adequado e de forma consistente com a estratégia perseguida pela Gerdau, de modo que não há que se falar em violação do dever de lealdade dos administradores.

74. Já em relação à suposta situação de conflito de interesses em que se encontravam os Conselheiros com Vínculo, apontaram que a Acusação partiu de duas premissas essenciais – (i) tais conselheiros teriam os mesmos interesses das Controladoras e (ii) haveria conflito entre os interesses das Controladoras e os da Companhia – as quais estariam fundamentadas: (a) na relação familiar existente entre tais conselheiros e os controladores finais da Gerdau; (b) no fato de pertencerem à administração de sociedades controladoras; e (c) nas condições da Opção de Venda e o suposto benefício que as Controladoras teriam com a Aquisição Itaú.

75. Contudo, segundo esses Acusados, tais fundamentos não procedem, pois, em primeiro lugar, não é possível concluir pela existência de conflito de interesses apenas em razão da relação de parentesco, conforme o entendimento manifestado pelo Colegiado da CVM de que laços familiares não são suficientes para definir que uma pessoa representa o mesmo interesse do acionista controlador⁵¹.

76. Além disso, argumentaram que a CVM já reconheceu, no âmbito do PAS CVM nº RJ2007/3453, julgado em 04.03.2008, que não há que se falar em conflito em casos em que existe vínculo por subordinação legal (relação de trabalho), pois não se pode presumir que o administrador é a *longa manus* do controlador, nem mesmo quando aquele é seu empregado, tampouco que o administrador que também trabalha para o controlador está impedido de votar em deliberações nas quais o controlador tenha interesse, embora tais situações exijam uma supervisão mais rigorosa.

77. Sustentaram que os Conselheiros com Vínculo, sendo filhos adultos e independentes, não estão subordinados aos seus pais e, portanto, não poderiam ser a eles equiparados para fins de conflito de interesses, nem poderiam ser considerados como seus meros mandatários, com limitação de sua atuação como administradores da Gerdau, reduzindo-lhes sua capacidade civil.

⁵¹ v. Processo CVM nº 2000/0389, j. 07.05.2002.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

78. Destacaram, ainda, que todos os Conselheiros com Vínculo possuem elevada qualificação, tendo se formado em instituições de primeira linha no Brasil e no exterior, e vários anos de experiência profissional, e que, plenamente cientes dos deveres inerentes à administração de companhias abertas, perseguiram os interesses da Gerdau ao aprovarem a Aquisição Itaú.

79. Quanto à atuação dos Conselheiros com Vínculo na administração das Controladoras, o que foi considerado pela Acusação como outro elemento que demonstraria o suposto conflito, os Acusados destacaram que a CVM já se manifestou claramente no sentido de que não é porque o administrador também exerce suas funções em companhia controlada ou controladora que ele estará impedido de votar. Dessa forma, haveria ainda mais razão para se concluir pela inexistência de conflito de interesses no caso em tela, dado que o contrato foi negociado com terceiro (Itaú) e não com acionista controlador.

80. Para sustentar esse argumento, citaram precedentes do Colegiado da CVM⁵², em que se reconheceu que a limitação do administrador não deveria ser absoluta e o art. 156 da LSA deveria ser aplicado somente às hipóteses em que o interesse pessoal do administrador colidisse com o da companhia – o simples fato de uma operação ser celebrada entre controladora e controlada não comprova a ocorrência de conflito de interesses dos administradores em comum.

81. Dito isto, tais Acusados concluíram que, se a circunstância de o administrador da companhia de capital aberto ser também administrador da contraparte pode não acarretar conflito, então o fato de ele ser administrador do controlador, que sequer participou da operação no caso em tela, também não poderia acarretar conflito⁵³.

82. Por essas razões, entenderam ter restado claro que os Conselheiros com Vínculo não tinham o mesmo interesse que as Controladoras e que essa circunstância seria, por si só, suficiente para afastar a acusação de conflito de interesses, tornando irrelevante a discussão sobre a existência ou não de conflito entre os interesses das Controladoras e da Companhia.

83. Com efeito, sustentaram que o conflito de interesses existe quando um mesmo agente tem dois interesses a tutelar e a satisfação de um deles só pode se dar à custa do sacrifício do outro, o que não se aplica ao presente caso, pois os Conselheiros com Vínculo não são controladores nem representam os interesses dos controladores ou têm qualquer vínculo com o Itaú.

⁵² PAS CVM nº 25/03, j. 25.03.2008; PAS RJ 2007/3453, j. 04.03.2008.

⁵³ Neste sentido, citou o PAS CVM nº RJ2008/1815, julgado em 28.04.2009, no âmbito do qual o Colegiado deliberou pela inexistência de infração ao art. 156 da Lei nº 6.404/76, confirmando o entendimento do não impedimento absoluto do administrador, em razão de não existirem, no caso, indícios ou provas suficientes para comprovar que a atuação dos administradores se deu em situação de impedimento por conflito de interesses.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

84. Inobstante, os Acusados passaram, então, a demonstrar que não havia contraposição formal ou substancial de interesses entre as Controladoras e a Gerdau na Aquisição Itaú, rebatendo alegação da Acusação de que o administrador não pode votar sobre operação societária em que tenha interesse pessoal, independentemente da comprovação de efetivo prejuízo à companhia. Sustentaram que, nesse caso, não há conflito formal, pois esse se verifica quando a parte supostamente conflitada é a contraparte da companhia, e também não há conflito substancial, pois, quando muito, se cogita em eventual benefício indireto para a INDAC, que, por sua vez, representaria um benefício indireto para seus controladores, que são apenas parentes de alguns dos conselheiros.

85. Com efeito, reconhecendo que a Aquisição Itaú foi benéfica para a Gerdau e que sequer ocorreu nas mesmas condições que aquelas previstas para o exercício da PUT, aquelas duas premissas em que se fundamentaria o suposto benefício da INDAC revelam-se, no entendimento desses Acusados, equivocadas.

86. Sustentaram, ainda, que a LSA trata apenas de conflito material e este conflito juridicamente relevante só existe quando há, no mérito, a decisão contrária ao interesse da companhia, o que só pode ser examinado *a posteriori*, sendo que a mera contraposição de partes não pode ser caracterizada como conflito.

87. Segundo afirmaram os Acusados, não houve qualquer prejuízo à Gerdau, dado que a Aquisição Itaú foi realizada em bases equitativas para ambas as partes e foi aprovada pela totalidade dos membros do CA da Companhia, incluindo os Conselheiros Independentes, o que corroboraria o fato de que tal operação não contou com o envolvimento de partes relacionadas, nem houve benefício particular às Controladoras ou aos respectivos acionistas⁵⁴.

88. Adicionalmente, em que pese o seu entendimento de que os arts. 156 e 245 da LSA não foram descumpridos, argumentaram que, conforme decisões da CVM, os administradores responsabilizados por violação ao art. 156 da LSA não poderiam ser também responsabilizados por violação ao art. 245 da mesma lei, dado que, na hipótese de se entender pela existência de conflito, a imputação de descumprimento deste último artigo seria irrelevante⁵⁵.

⁵⁴ Nesse sentido, ressaltou que a própria CVM considera o juízo desses conselheiros como parâmetro para a aferição de legitimidade de operações que envolvem o acionista controlador, conforme voto proferido pelo ex-Diretor Pedro Marcílio, nos Processos RJ2006/7204 e RJ2006/7213, julgados em 17.10.2006.

⁵⁵ Nesse sentido, destacou-se o seguinte trecho do voto da Diretora Relatora Maria Helena Santana, no âmbito do PAS CVM nº RJ2005/0097, j. 15.03.2007: “38. Já no que diz respeito aos demais conselheiros, Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi e Antonio Fábio Beldi, penso que não cabe responsabilizá-los por esta infração, pois já os considere responsáveis pela infração ao art. 156 da lei. Estes administradores devem, a meu ver, ser punidos por terem votado quando estavam claramente impedidos de o fazer, o que impede que venham a ser novamente punidos por terem votado, ainda que em infração ao art. 245.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

89. Com relação à suposta violação do dever de informar, os Acusados arguíram, primeiramente, que as informações divulgadas no Fato Relevante, de 14.07.2015, haviam sido completas e adequadas à avaliação global das Aquisições pelos investidores, e que fazia sentido divulgar dois negócios distintos como uma única operação, já que faziam parte de uma única estratégia e tinham a mesma finalidade, qual seja, a simplificação de processos e da estrutura societária da Gerdau para aumentar sua competitividade.

90. Sustentaram que era indiferente para os investidores a identidade dos vendedores das participações adquiridas pela Gerdau ou a suposta existência de discrepância entre os preços praticados que, como entenderam ter demonstrado, é apenas aparente. Além disso, argumentaram que o fato de as Aquisições terem sido aprovadas pelo CA como uma única operação demonstra que essa foi a maneira como a administração da Gerdau as analisou.

91. Acrescentaram que a divulgação segregada por contraparte, além de indiferente, poderia ser prejudicial à Gerdau, reduzindo a margem de negociação que teria ao eventualmente tentar comprar ações emitidas pelas Controladas e detidas por outros vendedores em potencial.

92. Ademais, fizeram referência ao processo instaurado a partir de pedido de autorização para negociação com ações de própria emissão pela Gerdau, tendo em vista que uma das formas de pagamento avençadas na Aquisição Arcelor envolvia a cessão e transferência de 30 milhões de ações preferenciais de emissão da Companhia. Arguíram que, no âmbito do referido processo, o Colegiado da CVM determinou, em 22.03.2016 – mais de oito meses após as Aquisições –, a divulgação de informações adicionais exclusivamente relacionadas à Aquisição Arcelor, não tendo reconhecido a necessidade de divulgação dos detalhes da Aquisição Itaú.

93. No que tange à suposta omissão quanto ao contrato previamente existente entre as Controladoras e o Itaú, alegaram que tal relação contratual não teve qualquer influência sobre a realização do negócio, cujo preço teria sido o mesmo, ainda que a opção de venda existente fosse contra terceiro sem qualquer relação com a Gerdau, tendo sido a divulgação do Fato Relevante, de 14.07.2015, adequada à avaliação do mercado acerca das Aquisições.

94. Sem prejuízo dos argumentos apresentados, segundo a Defesa, o art. 157, §4º, da LSA não se aplicaria a este caso, pois em nenhum momento alegou-se que André Pires teria deixado de comunicar o Fato Relevante em questão ou que o teria feito intempestivamente. Da mesma forma, também não seria aplicável o art. 3º, §5º, da Instrução CVM nº 358/2002, pois, em momento algum, se afirmou que as informações divulgadas careciam de clareza, precisão ou linguagem acessível, tendo a Acusação sustentado apenas que foram omitidas outras informações que, a seu juízo, deveriam ter sido prestadas. Salientaram que o que se discute é uma divergência de concepções acerca da quantidade de informações que deveriam ser prestadas sobre as Aquisições.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

95. Com base nesses argumentos, concluíram que houve excesso acusatório, haja vista que os fundamentos da Acusação sustentam, em tese, tão somente a alegação de infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009, que impõe ao emissor o dever de divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro, embora afirmem que tal imputação também seria improcedente.

96. Os argumentos apresentados quanto à suposta inadequação do Comunicado ao Mercado, de 17.07.2015, seguiram a mesma linha. Alegaram que as informações apresentadas por meio do referido comunicado foram verdadeiras, completas, consistentes e não induziram os investidores a erro, tendo em vista que efetivamente não houve o envolvimento de parte relacionada na Aquisição Itaú e que o comunicado apenas prestou informações adicionais ao mercado com o objetivo de afastar interpretações indevidas e equivocadas. Neste particular, esclareceram que Harley Scardoelli tinha assumido o cargo de DRI imediatamente após a divulgação do Fato Relevante, de 14.07.2015, e viu-se diante de questionamentos que denotavam, no seu melhor juízo, a existência de possíveis interpretações equivocadas acerca do respectivo conteúdo, em razão do que, diligentemente, prestou informações adicionais via Comunicado ao Mercado, incluindo uma das informações que a própria Acusação entendeu serem necessárias.

97. Por fim, requereram o reconhecimento do direito de apresentar proposta de termo de compromisso, nos termos do art. 11, §§5º a 10, da Lei nº 6.385/1976 e do art. 7º da Deliberação CVM nº 390/2001, sem, contudo, terem apresentado proposta, assim como protestaram pela posterior produção de provas e juntada de documentos, sem, no entanto, terem efetivamente requerido qualquer produção de prova, posteriormente ao protocolo da respectiva Defesa.

VI.3 DEFESA CONJUNTA DOS CONSELHEIROS SEM VÍNCULO

98. Inicialmente, tais Acusados apresentaram argumentos quanto à adequação da sua atuação no processo de aprovação das Aquisições, afirmando que observaram um processo decisório razoável, informado e refletido para garantir a tomada de decisão no interesse da Companhia e que não tinham nenhum incentivo pessoal ou econômico para aprovar uma operação no interesse das Controladoras, o que foi reconhecido pela própria Acusação.

99. Sustentaram que precedeu à aprovação das Aquisições a análise de relatórios, apresentações, laudo de avaliação, dados contábeis e financeiros, entre outros documentos, assim como reuniões e conferências telefônicas, tendo tais Acusados tido acesso a uma série de alternativas negociais que contribuíram para a tomada de decisão, e que a verificação dessas providências é de fundamental importância para atestar o cumprimento dos deveres fiduciários dos administradores e a comutatividade do negócio.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

100. Nessa linha, apontaram para o racional construído no Parecer de Orientação nº 35, que, a seu ver, registra o compromisso e o entendimento da CVM de que, nem em transações com partes relacionadas, em que a expropriação de minoritários é mais iminente, a Autarquia está disposta a imiscuir-se diretamente no conteúdo da decisão negocial e aferir o cumprimento dos deveres fiduciários dos administradores com base no resultado final da operação.

101. Considerando que a decisão tomada pelos referidos Acusados na reunião do CA de 13.07.2015 tem natureza eminentemente negocial, defenderam que todos os parâmetros estabelecidos pela CVM para a análise de uma decisão sob o ângulo do *business judgment rule* foram cumpridos por eles, demonstrando que tal decisão não foi apenas desinteressada, mas também informada e refletida.

102. Nesse cenário e considerando que as imputações que lhes foram dirigidas representam, essencialmente, o questionamento de uma decisão negocial, os Acusados sustentaram que a CVM deveria manter certa deferência à sua decisão pela aprovação da Aquisição Itaú. Afirmaram, ainda, que a Operação foi realizada no melhor interesse da Gerdau observando motivações legítimas, consistentes com o comportamento da Gerdau em períodos anteriores e com a racionalidade econômica dos agentes de mercado envolvidos – razão pela qual entendem ser de todo descabida a tese acusatória segundo a qual a Aquisição Itaú pretendia favorecer as Controladoras.

103. Defenderam que, enquanto os demais acusados são questionados pela suposta violação aos arts. 116 e 156 da LSA, não paira sobre esses Acusados nenhuma imputação de violação à regra de conflito de interesses, ou seja, na prática, a Acusação não vislumbrou qualquer fundamento para considerar que agiram (ou tinham incentivos para agir) no interesse de outra pessoa que não a própria Companhia, não havendo razões para que a SEP concluísse que tais Acusados não agiram de maneira proba.

104. Apontam que a valorização experimentada pelas ações de emissão da Gerdau no período entre 08.07.2015, data usada para o cálculo do número de ações que seria dada em pagamento à Arcelor, e 20.10.2016, data da apresentação da respectiva Defesa, passando de R\$ 6,86 para R\$ 10,23, reforçaria a percepção de que a Aquisição Itaú atendeu aos interesses da Gerdau.

105. Além disso, tais Acusados afirmaram que não há, nos autos do PAS, nenhum elemento que permita concluir – como pressupõe a Acusação – que a INDAC não tinha os recursos necessários ou interesse na aquisição das Participações Itaú, pois a SEP sequer procurou averiguar a perspectiva da INDAC com relação às participações que, ao final, foram adquiridas pela Gerdau. Afirmaram, ainda, que ninguém nunca obrigou a INDAC a renovar a Opção de Venda sucessivamente, e que essas renovações representaram uma decisão consciente daquela companhia, que acreditava que a remuneração oferecida ao Itaú seria menor que o incremento de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

valor das Controladas no mesmo período. Não fosse essa convicção da INDAC e da Gerdau, a decisão da Companhia de contratar o financiamento em 2005 jamais teria tido sentido.

106. Acrescentaram que não há razões para se qualificar o preço pago ao Itaú como não comutativo, pois, além de estar em linha com os preços pagos pela Gerdau em transações anteriores envolvendo os mesmos ativos e realizadas com partes igualmente independentes, a Acusação se equivocou quanto ao cálculo do valor justo das Participações Itaú e ao cálculo do custo de aquisição das Participações Arcelor.

107. Nesse sentido, apresentaram argumentação bastante semelhante àquela apresentada pelos Conselheiros com Vínculo e os DRIs, alegando, em apertada síntese, que:

- (i) a Operação estava em linha com a estratégia consistentemente perseguida pela Companhia, como demonstra o histórico de aquisições e permutas realizadas pela Gerdau entre 2003 e 2014, tendo por objeto ações de emissão das Controladas, cujos preços praticados, à época, mostram-se similares àqueles pagos ao Itaú;
- (ii) a negociação com a Arcelor teve início em 2011, cinco anos antes da aprovação da Aquisição Arcelor, tendo sido retomada em dezembro de 2014, logo após o que a Companhia também passou a conversar com o Itaú, dado que ambos eram acionistas minoritários relevantes;
- (iii) a contemporaneidade das negociações havidas com o Itaú e com a Arcelor deixa evidente a legitimidade da Aquisição Itaú e que, portanto, essa não se deu de forma oportunista, com o simples propósito de livrar as Controladoras de uma obrigação preexistente;
- (iv) a consolidação de participação nas Controladas traz e trouxe benefícios à Gerdau, os quais já haviam sido apontados no Fato Relevante de 14.07.2015 e têm efeitos sobre a conveniência e oportunidade das Aquisições, bem como sobre os preços pagos pelas Participações Itaú e pelas Participações Arcelor em cada aquisição;
- (v) o preço pago na Aquisição Itaú, em especial, deve ser analisado considerando que: a) em eventual incorporação das Controladas, o ágio pago pela Gerdau poderá ser deduzido da base de cálculo do IRPJ e CSLL; b) a operação incrementou a parcela dos dividendos das Controladas a que a Gerdau faz jus, com consequências positivas sobre o seu fluxo de caixa; c) historicamente, a operação brasileira da Companhia possui uma margem EBITDA maior, de forma que o aumento da participação nas Controladas, sobretudo quando realizado em troca de participação na própria Gerdau, tende a se traduzir em um maior retorno para os acionistas; e d) as Aquisições têm o condão de agilizar e simplificar o acesso da Companhia aos mercados internacionais e de dívida;
- (vi) o cálculo do sobrepreço pela SEP utilizou premissa equivocada, pois valeu-se, na conversão do valor apurado nos Laudos Apsis em relação às Participações Itaú, da cotação do dólar de 31.12.2014, quando, na realidade, deveria ter usado a cotação do dia 10.07.2015;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(vii) a Acusação também não considerou as formas de pagamento contempladas na Aquisição Itaú, que envolvia, além de pagamento parcelado, a estruturação do FIDC pelo Itaú⁵⁶, cuja proposta apresentou vantagem competitiva da ordem de, aproximadamente, R\$ 320 milhões em relação à segunda melhor proposta recebida pela Companhia para tal ativo;

(viii) como as ações das Controladas têm baixa liquidez, uma simples comparação entre os termos e condições avançados com o Itaú e a Arcelor não autoriza uma conclusão definitiva sobre a comutatividade das transações, já que não existe uma medida única que permita determinar com precisão o “preço justo” dos ativos adquiridos – o fato de determinado agente estar disposto a alienar determinado ativo por um preço relativamente mais baixo não autoriza a conclusão de que outras operações por preço superior não foram comutativas e prejudicaram o adquirente;

(ix) a Aquisição Arcelor, em especial, envolveu particularidades que devem ser levadas em conta e que foram ignoradas pela Acusação, notadamente o fato de que parcela expressiva do preço pago à Arcelor envolveu a entrega de ações de emissão da Gerdau, de forma que os valores por ação das Controladas, determinados na Aquisição Arcelor, devem servir, no máximo, como referência para a Aquisição Itaú – inclusive porque, à época das Aquisições, as ações da Gerdau estavam em patamares historicamente baixos, não refletindo o real valor da Companhia, cujas ações experimentaram expressiva valorização desde então.

108. Em vista do exposto, tais Acusados sustentaram que não há que se falar em descumprimento dos artigos 154 e 245 da LSA, uma vez que a Aquisição Itaú foi integralmente estruturada visando os interesses da Gerdau e de todos os seus acionistas, de acordo com parâmetros e métricas legítimos, nos termos e condições impostos pelas condições de mercado e agentes envolvidos, conforme demonstraram detalhadamente em sua Defesa.

109. Por fim, esses Acusados registraram a sua intenção de apresentar proposta de termo de compromisso, nos termos do art. 11, §§5º a 10, da Lei nº 6.385/1976 e da Deliberação CVM nº 390/2001. Contudo, não chegaram a efetivamente apresentar proposta.

VI.4 DEFESA DA INDAC

110. Refutando o suposto descumprimento do art. 116, parágrafo único, da LSA, a INDAC reiterou que, desde 2005, a Gerdau já vinha implementando reestruturação organizacional e societária para simplificar a estrutura do Grupo Gerdau e, assim, melhor atender aos seus interesses operacionais e estratégicos.

⁵⁶ Por meio do Itaú BBA S.A.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

111. Explicou que o objetivo dessa simplificação estrutural foi o de reduzir os custos, consolidar o recebimento de dividendos por seus acionistas, aumentar a eficiência operacional do Grupo Gerdau e simplificar as eventuais incorporações das Controladas pela Companhia, obtendo, ainda, maior agilidade no acesso aos mercados de dívida internacionais, principalmente com relação à emissão de títulos de dívida (*bonds*), inclusive por meio da obtenção do *status* de *shelf-filer*⁵⁷ junto à *Securities and Exchange Commission* nos Estados Unidos.

112. De modo a reforçar tal estratégia, a INDAC ressaltou que, entre os anos de 2005 e 2009, a Gerdau adquiriu participações nas Controladas de diversos alienantes, seja por meio de permutas, as quais totalizaram aproximadamente R\$ 269.999.000,00, seja por meio de aquisições com pagamento em espécie, essas últimas totalizando aproximadamente R\$ 1.738.736.000,00, e que nessas o preço médio pago por ação foi de R\$ 214,82, em linha com a média paga nas Aquisições.

113. Sustentou que a Aquisição Itaú foi realizada no interesse da Gerdau, consoante (i) a sua intenção de deter a totalidade do capital das Controladas; e (ii) a avaliação do CA da Gerdau, a quem competia verificar a conveniência e a oportunidade da Aquisição Itaú.

114. Segundo a INDAC, as Aquisições decorreram de oportunidades de negócio identificadas pela Gerdau, conforme divulgado no Comunicado ao Mercado de 17.07.2015, tendo sido observados os parâmetros de preço considerados adequados pela administração da Gerdau e as avaliações econômicas de longo prazo.

115. Defendeu que a definição do preço nesse caso constitui matéria de mérito da decisão empresarial e que o fato de haver acionistas que discordem da decisão não implica que a análise realizada pelos administradores tenha sido equivocada ou irregular.

116. Ponderou que: (i) os ativos negociados são ilíquidos e pouco dispersos; (ii) as Controladas são sociedades anônimas fechadas; e (iii) a Gerdau, àquela época, já era detentora de participação expressiva em cada uma das Controladas, sendo as ações restantes detidas por acionistas minoritários, dos quais os dois maiores eram justamente o Itaú e a Arcelor.

117. Dessa forma, a INDAC refutou a afirmação da Acusação de que o valor das Participações Itaú seguiu o critério que regia a Opção de Venda e não o “preço de mercado” de tais ativos, pois inexistia um mercado em que as Participações Itaú pudessem ser adquiridas na mesma quantidade

⁵⁷ De acordo com a INDAC, essa iniciativa reflete outra iniciativa da Companhia, que logrou obtenção do *status* de *shelf-filer* para emissões de seus *American Depositary Receipts* no mercado americano em 2010, o que tem possibilitado à Gerdau acessar este mercado em condições mais vantajosas desde 2011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

negociada. No entendimento da INDAC, não há que se falar em “preço de mercado”, o que impossibilita a comparação dos preços praticados nas negociações com diferentes contrapartes⁵⁸.

118. Passou, então, a discorrer sobre o histórico da aquisição das Participações Itaú pelo Itaú e sobre a razão de ser da Opção de Venda, apresentando dados e argumentos semelhantes àqueles trazidos nas Defesas relatadas acima, concluindo, em síntese, que:

- (i) considerando a existência da Opção de Venda, o Itaú não alienaria suas participações nas Controladas a terceiros por valor inferior ao que lhe era assegurado contratualmente, e tal cenário não seria diferente, qualquer que fosse a contraparte;
- (ii) a negociação com o Itaú era inevitável, já que era o maior acionista minoritário individual das Controladas e havia o interesse da Gerdau em futuramente transformar essas sociedades em subsidiárias integrais, e, considerando a estratégia perseguida pela Companhia, cabia a esta buscar as melhores condições de negociação para aquisição das Participações Itaú;
- (iii) a Acusação usou a cotação do dólar na data-base informada nos Laudos Apsis para converter os valores mínimos e máximos nele consubstanciados para reais, quando, na realidade, deveria ter considerado a cotação do dólar no último dia anterior à data de aprovação das Aquisições, de forma que o sobrepreço seria consideravelmente inferior ao calculado pela SEP; e
- (iv) ainda assim, a diferença de preço pago pelas Participações Itaú e pelas Participações Arcelor é irrelevante quando levados em consideração dois fatores chave para a negociação do preço – o ganho obtido na negociação com o Itaú decorrente da utilização do FIDC e o benefício fiscal advindo da amortização do ágio pago na Aquisição Itaú, os quais, somados, traduzem uma vantagem aproximada de R\$ 707 milhões, sendo que a Gerdau poderia, eventualmente, receber um *upside* relativo aos ajustes dos preços dos Direitos Creditórios cedidos ao FIDC.

119. Outro argumento trazido pela INDAC foi de que a Gerdau conseguiu preservar sua liquidez, negociando, como forma de pagamento, primeiramente, um desembolso de caixa de R\$ 200 milhões, considerado pequeno frente ao montante global de R\$ 1.691.165.695,30, e, posteriormente, pagamentos parcelados, que se dariam de maneira bastante diferida ao longo dos anos, sendo o último deles em 2022, também diminuindo o impacto no caixa da Companhia.

120. No que tange à Aquisição Arcelor, segunda maior acionista individual da Gerdau, a INDAC alegou que a negociação também teve como objetivo evitar o desembolso de caixa tanto quanto possível. Tendo em vista que era do interesse da Arcelor permutar as Participações Arcelor por ações GGBR4 da Gerdau, dotadas de maior liquidez, e, considerando que a Companhia não

⁵⁸ Nesse sentido, a INDAC destacou o entendimento manifestado pelo ex-Diretor Pedro Márcilio, no âmbito do julgamento do PAS CVM nº RJ2005/8542 (julgado em 29.08.2006), no sentido de que a liquidez de um papel é fator importante em uma negociação e, na sua ausência, não há subsídios para comparar uma negociação com outra.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

detinha em tesouraria a totalidade de ações GGBR4 necessárias ao pagamento integral do preço, houve a transferência de 30 milhões de ações pelo valor de R\$ 205,8 milhões e o pagamento dos R\$ 89,18 milhões restantes à vista.

121. Nesse sentido, salientou que, conforme mencionado pela Gerdau em resposta a ofício⁵⁹, caso o pagamento à Arcelor fosse feito integralmente em dinheiro, além de reduzir o caixa da Companhia, correr-se-ia o risco de a Arcelor exigir preço maior para a conclusão da Aquisição Arcelor, uma vez que, para manter o investimento em atividades relacionadas à Gerdau, aquela sociedade teria que realizar compras no mercado, sujeitas a custos adicionais, tais como taxa de corretagem, bem como aos efeitos das oscilações naturais de preço. Com isso, concluiu a INDAC que a negociação com a Arcelor ocorreu em bases consideradas vantajosas para ambas as partes.

122. Dito isso, a INDAC sustentou que, ao contrário do que afirmou a Acusação, a Aquisição Itaú não foi realizada para favorecer os controladores em detrimento da Companhia, mas, sim, concluídas no interesse e benefício da Gerdau e, consequentemente, de seu conjunto de acionistas.

123. No que se refere à acusação especificamente formulada contra a INDAC, de que a mesma teria faltado com os seus deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da Gerdau, cujos direitos e interesses deveria lealmente respeitar e atender, conforme previsto no art. 116 da LSA, a INDAC salientou, primeiramente, que a LSA impõe ao acionista controlador um dever fiduciário em relação, não apenas à companhia, mas também aos outros *stakeholders*. Ou seja, da mesma forma que os administradores, o controlador tem um dever de lealdade para com a companhia, que lhe impede de adotar comportamentos potencialmente lesivos aos legítimos interesses e expectativas de outros sócios ou da sociedade de que são membros.

124. Nesse sentido, asseverou que o controlador deve observar, em especial, a obrigação de não concorrer com a companhia, permitindo que ela persiga, com exclusividade, as oportunidades comerciais que sejam de seu interesse ou estejam compreendidas em seu objeto social. Concluiu que, se a Aquisição Itaú era do interesse da Gerdau, não lhe cabia interferir no negócio de forma a impedir sua realização, sob pena de agir contrariamente aos interesses de sua controlada.

125. Afirmou, ainda, que não faz sentido a acusação de descumprimento de seus deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da Gerdau, dado que não participou das negociações com o Itaú e tampouco deliberou a respeito, pois a aprovação das Aquisições dependia exclusivamente do CA da Gerdau.

126. Quanto ao fato de a Aquisição Itaú ser de seu conhecimento por haver administradores em comum entre a Companhia e a INDAC, defendeu que não havia interesse conflitante entre

⁵⁹ Ofício CVM nº 282/2015/CVM/SEP/GEA-2 (Doc. SEI 0125095, fls. 188 e ss.).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

controladora e controlada, mas sim interesses convergentes, e que a Operação foi aprovada pela unanimidade dos conselheiros da Gerdau, incluindo os Conselheiros Independentes. Sustentou que não caberia à INDAC imiscuir-se na condução dos negócios sociais de sua controlada.

127. Ademais, argumentou que, ainda que se pretendesse pela ocorrência da alegada irregularidade, o que admitiu apenas para argumentar, a simples análise da acusação e do tipo imputado leva à conclusão da total inadmissibilidade de aplicação do art. 116 da LSA.

128. Alegou que os processos administrativos instaurados pela CVM devem observar rigorosamente os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sob pena de serem considerados nulos por violação ao artigo 5º, LV⁶⁰, da Constituição Federal, e que a aplicação de qualquer penalidade administrativa deve necessariamente estar vinculada ao princípio da reserva legal, consubstanciado na prévia definição dos tipos ou condutas tidas como ilícitas e das cominações que lhes são correspondentes.

129. Destacou, ainda, que uma das consequências do princípio da reserva legal é a observância do princípio da tipicidade do ilícito imputado. Com efeito, destacou que, para a caracterização do ilícito administrativo, assim como ocorre no Direito Penal, é indispensável que o comportamento do agente seja definido como ilegal pela norma anterior, pois é necessário que ele tenha conhecimento da proibição de determinada conduta para que possa ser punido.

130. Segundo a INDAC, acerca dos conceitos indeterminados previstos na LSA, como é o caso do parágrafo único do art. 116, que prescreve um padrão de conduta sem esclarecer os elementos caracterizadores do suposto ilícito praticado, a sua aplicação está necessariamente vinculada à prévia definição pela instância reguladora, de maneira a dar-lhe sentido correto e evitar que seja conferida uma multiplicidade de sentidos a uma mera expressão programática. Do contrário, nenhuma penalidade pode vir a ser aplicada – sob pena de sua total nulidade.

131. Sustenta que, no caso ora em análise, não é competência do acionista controlador, mas sim do CA da Gerdau, decidir sobre aquisição de participações societárias de minoritários e reestruturação da Companhia⁶¹. Contudo, ainda que se venha a entender que pode ser imputada responsabilidade ao acionista controlador pela Aquisição Itaú, não há nos autos qualquer indicação de como deveria ter procedido para evitar que o CA da Gerdau deliberasse a respeito.

⁶⁰ Art. 5º. (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

⁶¹ O Estatuto Social da Gerdau, no artigo 6º, parágrafo 5º, determina que: “*Além das atribuições decorrentes de outros preceitos do presente Estatuto ou da Lei, incumbe ao Conselho de Administração: (...) k) aprovar alterações relevantes na estrutura organizacional da Companhia, necessárias ao suporte às estratégias definidas; (...) s) autorizar a participação em outras sociedades, bem assim, a formação de consórcios, “joint ventures” e alianças estratégicas, no País e no exterior (...)*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

132. Por fim, a INDAC resguardou-se no direito de apresentar proposta de termo de compromisso, nos termos do art. 7º da Deliberação CVM nº 390/2001, mas também não o fez.

VI.5 DEFESA DA METALÚRGICA GERDAU

133. A Metalúrgica Gerdau inicia a sua Defesa alegando que não teve influência sobre a realização da Aquisição Itaú e que não lhe cabia tomar quaisquer providências a respeito, seja porque o contrário significaria uma interferência indevida no processo decisório da administração de sua controlada, seja porque a operação era benéfica para a Gerdau, tendo sido aprovada por razões estranhas à existência da Opção de Venda.

134. Afirmou que a SEP, ao acusá-la, assim como o fez com a INDAC, destacou que as decisões sobre as Aquisições foram tomadas no âmbito do CA da Gerdau, mas, por outro lado, imputou-lhe o suposto descumprimento de deveres e responsabilidades genéricos para com os demais acionistas, em razão da não adoção de providências quanto à Aquisição Itaú, o que, para essa Acusada, é uma presunção de responsabilidade das Controladoras por omissão.

135. Argumentou que, caso houvesse a ocorrência de abuso por parte das Controladoras, a sua conduta deveria ter sido provada pela Acusação, o que não foi feito neste caso, pois a Acusação apurou que não houve nenhum ato das Controladoras aprovando ou mesmo induzindo a realização da Operação, motivo pelo qual não há que se falar em abuso de poder de controle.

136. Nesse sentido, alegou que a tese de responsabilidade que a Acusação tentou construir neste caso é contrária ao ordenamento jurídico, tendo sido repudiada pelo Colegiado da CVM, que já decidiu, no julgamento do PAS CVM nº RJ2012/11199, em 22.03.2016, ser incabível, quando se trata de um suposto negócio entre controlador e controlada, responsabilizar o controlador em razão de alegada omissão. A Acusada chamou a atenção, ainda, para o fato de que tal precedente tratava de contratação com sociedade do mesmo grupo, enquanto, neste caso, a contratação se deu entre Gerdau e Itaú, parte independente. A Metalúrgica Gerdau não poderia ser responsabilizada por uma suposta omissão em conduzir as negociações havidas entre a Gerdau e o Itaú.

137. Quanto ao fato de a administração da Gerdau ter deliberado o negócio tendo ciência da existência da Opção de Venda, no entendimento da Acusada, não altera as conclusões acima expostas, pois a contratação da Aquisição Itaú era uma faculdade da Gerdau e do Itaú. Se assim não fosse, sustentou a Metalúrgica Gerdau que se chegaria a uma situação inusitada, em que dada companhia aberta estaria impedida de consolidar a participação em suas controladas pelo simples fato de haver uma opção de venda exercível por terceiro contra o controlador.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

138. Adicionalmente, de forma a reforçar seu posicionamento, a Metalúrgica Gerdau reputou inaplicável o entendimento do Colegiado da CVM no julgamento do PAS CVM nº RJ2012/1131, em que o acionista controlador, o Estado de São Paulo, foi condenado por omissão, tendo destacado diferentes circunstâncias do caso que o afastam do presente, quais sejam: (a) o Estado de São Paulo era, ao mesmo tempo, controlador da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. – EMAE e da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo – Sabesp; (b) havia a retirada gratuita de água de reservatórios da EMAE pela Sabesp, fazendo com que a primeira deixasse de auferir receitas anuais da ordem de R\$ 120 milhões; e (c) o impasse, isto é, a retirada de água de forma gratuita pela Sabesp, de modo a prejudicar a EMAE e seus acionistas, subsistiu por décadas, sem que o Estado de São Paulo fizesse nada a respeito.

139. Neste caso, a Metalúrgica Gerdau entendeu que não deveria ter interferido na Aquisição Itaú, uma vez que a negociação seguia seu rumo natural nas instâncias internas de decisão da Gerdau, bem como, diferentemente do ocorrido em tal precedente, havia contrapartida ao valor pago na Aquisição Itaú (i.e., maior participação nas controladas).

140. Portanto, considerando esse contexto, alegou que admitir um cenário em que a Metalúrgica Gerdau interviesse na aprovação do CA – em evidente desrespeito à instância decisória interna da Gerdau –, seria o mesmo que abusar de seu poder de controle, de modo que, se tivesse intervindo, estaria respondendo por tal abuso.

141. Na visão da Metalúrgica Gerdau, não havia fundamentos para suspeitar de operação analisada e aprovada pela unanimidade dos membros do CA (inclusive pelos Conselheiros Independentes), de modo que, se não há que se falar em obrigação de intervenção nesta deliberação, tampouco seria justificável a sua penalização por omissão, que retrata justamente o seu respeito à autonomia do CA da Gerdau.

142. Por fim, requereu o reconhecimento do direito de apresentar proposta de termo de compromisso, nos termos do art. 11, §§5º a 10 da Lei nº 6.385/1976 e do art. 7º da Deliberação CVM nº 390/2001, sem, contudo, ter apresentado tal proposta, assim como protestou pela posterior produção de provas e juntada de documentos, sem, no entanto, ter efetivamente requerido qualquer produção de prova ou diligência, posteriormente ao protocolo da Defesa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

VII. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

143. O presente processo foi originalmente distribuído, em 13.12.2016, para o então Diretor Pablo Renteria. Ao final de seu mandato – e antes de minha posse – o processo foi provisoriamente redistribuído, até que, no dia 19.03.2019, fui designada sua relatora.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2019.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro
Diretora Relatora



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEI Nº 19957.004309/2016-73

Reg. Col. 0463/16

Acusados: André Pires de Oliveira Dias
Harley Lorentz Scardoelli
Claudio Gerdau Johannpeter
André Bier Gerdau Johannpeter
Richard Chagas Gerdau Johannpeter
Expedito Luz
Affonso Celso Pastore
Oscar de Paula Bernardes Neto
INDAC – Indústria Administração e Comércio Ltda.
Metalúrgica Gerdau S.A.

Assunto: Apurar eventuais irregularidades em operação de aquisição de participações minoritárias em empresas controladas pela Gerdau S.A., em suposto descumprimento ao disposto nos arts. 116, parágrafo único, 154 c/c 245, 156 e 157, §4º, todos da Lei nº 6.404/1976, art. 3º, §5º, da Instrução CVM nº 358/2002, e art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS instaurado para apurar eventuais irregularidades em operação de aquisição pela Gerdau¹ de participações minoritárias em quatro empresas por ela controladas e em que a Gerdau já detinha, antes das Aquisições, participação acionária representativa de mais de 90% do capital social, quais sejam: Gerdau Açominas, Gerdau Aços Longos, Gerdau Aços Especiais e Gerdau América Latina (em conjunto, “Controladas”)². As Aquisições foram divulgadas ao mercado por meio do Fato Relevante de 14.07.2015, seguido de esclarecimentos prestados no Comunicado ao Mercado de 17.07.2015.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, que não estiverem nele definidos, têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² No agregado, houve aquisição de ações ordinárias e preferenciais de emissão das Controladas, representativas de participação equivalente a (i) 3,50% do capital social da Gerdau Açominas; (ii) 4,77% do capital social da Gerdau Aços Longos; (iii) 2,39% do capital social da Gerdau Aços Especiais; e (iv) 4,90% da Gerdau América Latina.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2. O Fato Relevante, além de conter referências a outras ações tidas como *"necessárias para adequação da Gerdau ao cenário atual de grande competitividade, e avanço na simplificação de processos e da estrutura societária da Gerdau"*³, trouxe informações agregadas sobre as Aquisições aprovadas, por unanimidade, em reunião do CA ("RCA") da Gerdau, em 13.07.2015, *"com vistas à possível transformação dessas companhias, no futuro, em subsidiárias integrais e/ou à sua incorporação"*⁴; *a consolidar o recebimento de dividendos; e a proporcionar a maior facilidade de acesso ao mercado de capitais"*.

3. Consoante o Fato Relevante, por meio dessas *"aquisições de participações acionárias, no valor total de **R\$ 1.986 milhões**"*, o que representava, à época, o equivalente a aproximadamente 18% do valor de mercado da Gerdau, essa passaria a *"deter mais de 99% do capital total de cada uma das controladas (...) uma vez cumpridas as condições dos respectivos contratos de compra"*.

4. Embora as Aquisições tenham tido como alvo ações de emissão das mesmas companhias e mesma data de aprovação pelo CA, não resta dúvida de que resultaram de dois negócios distintos e independentes entre si: (i) a Aquisição Itaú, tendo o Itaú como vendedor das Participações Itaú; e (ii) a Aquisição Arcelor, sendo a Arcelor como vendedora das Participações Arcelor.

5. Como detalhado no Relatório, a Aquisição Itaú e a Aquisição Arcelor envolveram quantidades distintas de ações de emissão das Controladas: no total, **23.082.688**⁵ ações ordinárias foram adquiridas do Itaú e **12.902.874**⁶ ações foram adquiridas da Arcelor. As Aquisições foram significativamente díspares quanto a preço, no total, **R\$ 1.691.165.695,30**, na Aquisição Itaú, e **R\$ 294.980.000,00** na Aquisição Arcelor, e condições de pagamento, que foram as seguintes:

(i) na Aquisição Arcelor, parcela de **R\$ 89.180.000,00 à vista**, e o restante por meio da transferência de **30.000.000 ações preferenciais de emissão da Gerdau**, mantidas em tesouraria e equivalentes a 1,74% do capital social da Companhia; e

(ii) na Aquisição Itaú, parcela de **R\$ 250.000.000,00 à vista**, **permuta de cota de FIDC**, detentor de Direitos Creditórios no valor de **R\$ 802.329.988,83**, e o restante

³ v. referências feitas, no Fato Relevante, ao "Plano Gerdau 2022" e à avaliação de alternativas para incorporação pela Gerdau das empresas Selva S.A. Florestas e Indústrias, Gerdau América Latina e Itaguaí Comércio, Importação e Exportação Ltda., durante o segundo semestre de 2015 (Doc. SEI 0125083, fls. 21-22).

⁴ Note-se que duas das quatro Controladas (i.e. Gerdau Aços Especiais e Gerdau América Latina) vieram a ser efetivamente incorporadas pela Gerdau anos depois, em 29.12.2017.

⁵ A Aquisição Itaú abrangeu a compra de 5.648.201 ações de emissão da Gerdau Açominas, 5.648.201 de emissão da Gerdau Aços Especiais, 5.648.201 de emissão da Gerdau América Latina e 6.138.085 de emissão da Gerdau Aços Longos, sendo todas essas ações ordinárias.

⁶ A Aquisição Arcelor abrangeu a compra de 3.157.259 ações de emissão da Gerdau Açominas (sendo 3.153.714 ordinárias e 3.545 preferenciais), 3.157.259 da Gerdau Aços Especiais (sendo 3.153.714 ordinárias e 3.545 preferenciais), 3.157.259 da Gerdau América Latina (sendo 3.153.714 ordinárias e 3.545 preferenciais) e 3.431.097 da Gerdau Aços Longos (sendo 3.427.244 ordinárias e 3.853 preferenciais).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

em **pagamento parcelado**, com vencimentos em 2016, 2017, 2019, 2021 e 2022, no valor total de **R\$ 638.835.706,47**.

6. Tal disparidade, em larga medida, acabou jogando luz sobre o cerne da principal questão desafiada neste PAS: a racionalidade e a comutatividade da Aquisição Itaú.

7. A Acusação questionou especificamente a atuação (i) dos membros do CA da Gerdau na aprovação da Aquisição Itaú, entendendo que essa teria sido realizada em condições prejudiciais à Companhia e desviando-se do interesse social, tendo como objetivo desonerar suas Controladoras de obrigações previamente assumidas perante o Itaú, no âmbito da Opção de Venda, que assegurava ao Itaú o direito de vender as Participações Itaú à INDAC, controladora indireta da Gerdau, cuja obrigação de compra era garantida pela Metalúrgica Gerdau, controladora direta da Companhia; e (ii) dos DRIs da Gerdau em exercício quando da divulgação, respectivamente, do Fato Relevante e do Comunicado ao Mercado, por falhas no cumprimento do dever de informar.

8. Adicionalmente, por considerar que a Aquisição Itaú configurou, na verdade, uma transferência de obrigações entre a INDAC e a Gerdau, a Acusação entendeu se tratar de transação com partes relacionadas, questionando, também, a atuação das Controladoras, em abuso de poder de controle, por omissão diante da operação celebrada. A Opção de Venda tinha como objeto as Participações Itaú e era exercível pelo Itaú, consideradas todas as postergações havidas, até 07.08.2015⁷, tendo perdido seu objeto diante da aquisição de tais participações pela Gerdau.

9. Nesse contexto, a Acusação imputou responsabilidade: (i) a todos os Conselheiros, por terem atuado com desvio de finalidade ao aprovarem a operação em condições não equitativas, em detrimento da Gerdau; (ii) aos Conselheiros Com Vínculo, por terem agido, também, em conflito de interesses ao aprovarem a Aquisição Itaú, já que ocupavam, concomitantemente, cargos na administração da Gerdau e das Controladoras e eram herdeiros diretos das pessoas naturais que, em última instância, controlavam as empresas do Grupo Gerdau; (iii) às Controladoras, por terem abusado de seu poder de controle ao deixarem de adotar providências compatíveis com a relevância e gravidade dos fatos, beneficiando-se da Aquisição Itaú; e (iv) aos DRIs da Gerdau, por falhas no cumprimento do dever de informar as Aquisições ao mercado.

10. Apenas para dar maior clareza e sistematicidade a este voto, inicialmente, tecerei certas considerações gerais acerca do tipo de decisão sob análise, do padrão de revisão a ser adotado pela CVM neste processo e, ainda, sobre o preço e as condições de pagamento da Aquisição Itaú, tendo em vista a relevância desses elementos para a análise deste caso. Na sequência, passarei a examinar

⁷ O vencimento da opção de venda originalmente celebrada em 2005 seria em 31.02.2006, mas, em virtude de repactuação e sucessivos aditamentos, ao final, a PUT passou a vencer em 07.08.2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

cada uma das imputações feitas pela Acusação, divididas em seções de acordo com os dispositivos da LSA que a SEP reputou terem sido infringidos pelos respectivos Acusados.

II. DECISÃO EMINENTEMENTE NEGOCIAL

11. A aprovação da Aquisição Itaú, com a subjacente análise sobre sua adequação sob a perspectiva da Companhia, constituiu uma decisão eminentemente negocial, que envolveu a apreciação de uma série de fatores e particularidades, especialmente quanto à precificação, cujo exame de mérito, em regra, transbordaria os limites de revisão pela CVM.

12. Não obstante, à luz dos dispositivos legais supostamente infringidos, a constatação de que a Aquisição Itaú foi fruto de uma decisão negocial não exime os Conselheiros acusados de terem sua decisão analisada no mérito, com a adoção de um padrão de revisão mais rigoroso, uma vez que não se trata de acusação por falta de diligência e que está em discussão justamente o alinhamento da decisão ao melhor interesse da Companhia, especialmente tendo em vista o reflexo da Aquisição Itaú na extinção da PUT, da qual derivavam obrigações relevantes das Controladoras.

13. Imprescindível considerar o contexto em que a operação estava inserida e a complexidade relacionada ao preço e às condições de pagamento avançadas, sem o que não me parece possível examinar a Aquisição Itaú, em termos gerais, sob a ótica de sua racionalidade.

14. Como explicitado, com muita propriedade, pela ex-presidente desta Autarquia Maria Helena Santana, no julgamento do PAS CVM nº 25/03, não se pode subestimar a complexidade envolvida na avaliação de preço de aquisição de participação acionária:

“18. Assim, não penso que a CVM deva pretender, como acabou por fazer a Comissão de Inquérito, arbitrar esse conflito natural, ao afirmar, indiretamente, que a compra da Oi **teria sido feita por valor não-justo** a partir das reclamações trazidas. A tensão entre essas duas posições deve funcionar em benefício das companhias e de sua sustentabilidade no longo prazo. E **a menos que houvesse evidência muito forte de que a escolha feita foi incorreta e prejudicial** à Telemar, o que os dados não parecem sustentar, a Comissão deveria ter-se colocado de fora deste conflito, e não escolhido reconhecer a um dos lados a condição de melhor intérprete do interesse da Companhia.

19. Este é um processo complexo, pois não se trata aqui de avaliar, por exemplo, uma transação em que se emprestou caixa da companhia ao controlador, mas **de um caso que acabou por colocar a CVM na posição de avaliar uma decisão de investimento tomada, e o preço ao qual o investimento foi realizado. Não há como subestimar a complexidade de que se reveste esta situação**, como tentei demonstrar.”⁸ (Grifei)

⁸ PAS CVM nº 25/03, j. 25.03.2008.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

15. O exame de mérito de decisão negocial pela CVM é justificável, portanto, quando o processo decisório estiver eivado de irregularidade, o que importa na indisponibilidade da aplicação da chamada *business judgment rule*, ou se, ainda que regular, o seu resultado não refletir termos razoavelmente compreensíveis e racionais, permitindo concluir pela atuação com desvio de finalidade ou apontando para uma atuação desleal dos administradores.

16. É o que se desafia neste PAS: o mérito de uma decisão negocial, sob o prisma do interesse primordial que teria subsidiado a decisão da Gerda de adquirir as Participações Itaú nas condições pactuadas. Em outras palavras, julgamos se a Aquisição Itaú foi aprovada genuinamente para “lograr os fins e no interesse da Companhia”.

17. Não se trata de aferir se a Aquisição Itaú foi realizada em termos ideais para a Gerda, mas sim de julgar se foi realizada em seu interesse e não para eximir suas Controladoras das obrigações decorrentes da PUT.

18. Nesse sentido, com muito bem ponderado pelo presidente da CVM, Marcelo Barbosa:

“7. Assim redefinido o enquadramento jurídico dos fatos, o papel que se impôs ao Colegiado diante desta controvérsia passou a ser o de avaliar se os membros do conselho de administração da HRT, ao negociarem e aprovarem o Severance Package, agiram em **desvio de poder**, violando o **art. 154 da Lei nº 6.404/76**. Em essência, portanto, a questão se deslocou para a verificação de suposta violação do comando legal segundo o qual **os administradores devem exercer suas atribuições “para lograr os fins e no interesse da companhia”**.”

8. Em linha com a doutrina e com os precedentes da CVM, entendo que o exame dessa questão **envolve a análise da conduta dos administradores, inclusive do conteúdo das decisões tomadas no âmbito dos órgãos colegiados** (conselho de administração e diretoria), com o **objetivo de aferir se elas se conciliam com o objeto social e os interesses da companhia**. Trata-se, assim, de **exame de mérito**, cabendo aos administradores, quando em face da acusação por desvio de poder, lançar mão de elementos aptos a demonstrar o **alinhamento de seus atos aos interesses da companhia**.

9. No entanto, e é importante frisar, o exame de mérito que o art. 154 impõe **não envolve um juízo de adequação da conduta ou decisão do administrador no sentido de avaliar se foram ideais para a companhia**. (...)”⁹

(Grifei)

19. No presente caso, não estão em xeque os procedimentos adotados pelos Conselheiros para a tomada da referida decisão, no que tange à diligência por eles empregada. Não há imputação de descumprimento do art. 153 da LSA por qualquer dos Acusados, o que revela que a própria Acusação não reputou ter havido falta de diligência no exame das Aquisições.

⁹ Trecho da respectiva manifestação de voto no PAS CVM nº RJ2013/11703, j. em 31.07.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

20. Não obstante haver certa complementaridade entre o art. 153 e o art. 154 da LSA, o primeiro trata do “modo” e o segundo trata da “finalidade”, trazendo à baila enfoques distintos, como bem explorado pelo Diretor Gustavo Gonzalez, em manifestação de voto no processo supracitado:

“Quando se avalia apenas diligência, o foco da discussão é o procedimento. Nesse sentido, as decisões da CVM que buscaram sistematizar a *business judgment rule* brasileira indicam que o referido teste não é aplicável a decisões interessadas, nem aos casos em que existem evidências de fraude ou de má-fé. Nota-se, portanto, que prévia ou concomitantemente à análise procedimental pode-se verificar se existem indícios dos problemas que previnem a aplicação da regra da decisão negocial.

40. Já o artigo 154 exige que o administrador adote não ‘apenas uma conduta formalmente de acordo com os preceitos da LSA, mas, sim, materialmente em linha com os seus preceitos’. Por tal motivo, o exame de desvio de poder não se esgota em uma análise acerca da independência e do interesse do administrador. Com efeito, **para que o artigo 154 cumpra com a sua finalidade, a revisão em casos de suspeita de desvio requer um olhar diferente e uma consulta mais abrangente, que busque apurar se atos praticados pelos administradores, ainda que formalmente corretos, buscavam de fato atingir fins ilegais, contrários à ordem pública ou aos interesses da companhia.**

41. **Essa abrangência deve, contudo, ser delimitada com temperança, sob pena de se transformar uma obrigação de meio em uma de resultado.**¹⁰

(Grifei)

21. Por essas razões, antes de analisar cada uma das supostas infrações objeto da Acusação, entendo ser pertinente enfrentar as controvérsias suscitadas acerca da Aquisição Itaú, especialmente no que tange à sua precificação.

III. O PREÇO E AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO ITAÚ

22. De início, destaco que nem a Acusação nem os Acusados se insurgiram quanto a um ponto que, de fato, se revela um tanto óbvio diante das circunstâncias apuradas: não seria factível que o Itaú se dispusesse a alienar as Participações Itaú à Gerdau por valor inferior ao que o próprio Itaú tinha direito a receber caso optasse por exercer a PUT.

23. O preço total da Aquisição Itaú foi de **R\$ 1.691.165.695,30**, enquanto o preço de exercício da PUT, conforme decorrente da sua última renovação, era de **R\$ 1.691.141.000,45**, tendo a Acusação atribuído a pequena diferença de valores a arredondamentos¹¹.

¹⁰ Trecho da respectiva manifestação de voto no PAS CVM nº RJ2013/11703, j. em 31.07.2018.

¹¹ O valor constante do Formulário de Referência de 2015 da Metalúrgica Gerdau, acerca de sua obrigação como garantidora da INDAC na PUT era de R\$1.565.085,00, em 31.12.2014, que, conforme cálculo SEP, atualizado até a data de aprovação da Aquisição Itaú, alcançaria R\$ 1.691.145.000,00 (Termo de Acusação, item 67).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

24. Como relatado no Termo de Acusação¹², em resposta a Ofício da SEP, a própria Companhia afirmou que “a Gerdau não estava vinculada aos contratos [de opção de venda - grifo meu]. No entanto, na medida em que era uma opção que o Itaú tinha, não se pode esperar que concordasse em vender as ações para a Gerdau por valor inferior ao que poderia vender para terceiro (no caso a Indac...)” (grifei).

25. No mesmo sentido, em resposta a Ofício da SEP¹³, o conselheiro Claudio Gerdau manifestou-se a respeito dos preços praticados nas Aquisições, nos seguintes termos:

“c. informar os motivos pelos quais considera que as operações de aquisição de participações minoritárias se deram de forma equitativa com ambos os vendedores, considerando notadamente as diferenças entre os valores pagos;

Entendo que, como administrador da Companhia, cabe, prioritariamente avaliar se determinada operação atende ao **interesse social**, como julguei ser o caso da operação mencionada no Ofício.

Neste contexto, é relevante para a Companhia pagar um **preço adequado e não excessivo** para a aquisição de determinado ativo. Caso tal ativo seja adquirido de distintos vendedores, a prioridade não deve ser obter condições iguais, mas sim as mais vantajosas.

Assim, se um está disposto a vender por determinado preço, e outro por preço maior, compete à companhia tentar adquirir tudo pelo menor preço, mas isto não sendo possível (**como no presente caso, em que o Itaú não estava disposto a vender por preço menor**), é preferível pagar um preço menor a um dos vendedores do que elevar o preço para garantir um suposto tratamento equitativo que não é exigido pela legislação societária ou de mercado de capitais.”

(Grifei)

26. Em linha com essa assertiva, embora o preço total fosse dado, verifica-se que houve negociação com o Itaú quanto às condições de pagamento¹⁴, o que é também um modo de impactar o preço. Com efeito, são essencialmente distintas equações à vista (que era o caso do pagamento previsto na PUT) e a prazo (ainda que apenas em parte, como negociado pela Gerdau na Aquisição Itaú). É evidente que a forma de pagamento também tem repercussões relevantes na precificação, ainda que isso não afaste, por si só, a questão do interesse determinante para a aprovação pelo CA.

¹² Doc. SEI 0125258, fls. 3.

¹³ Ofício nº 005/2016/CVM/SEP/GEA-4, doc. SEI 0125095, fls. 754.

¹⁴ A lista de eventos relacionados às Aquisições apresentada pela Gerdau, em resposta ao Ofício nº 254/2015/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI 0125088, fls. 217-220) mostra que, dentre os assuntos das reuniões havidas com o Itaú, foi recorrente o tema “estrutura da compra dos ativos financeiros” e “ações judiciais da Gerdau contra a Eletrobrás”, embora não esteja claramente documentado o conteúdo das discussões. Também foi tema das referidas reuniões o contrato de permuta celebrado entre a Arcelor e a Gerdau. Ou seja, a cronologia apresentada indica ter havido um esforço verdadeiro de negociação a respeito dos Direitos Creditórios cedidos pela Companhia ao FIDC e da permuta de ações de emissão da Gerdau pelas Participações Arcelor, que consistiram em relevante parcela do pagamento avençado das respectivas operações.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

27. Pertinente ressaltar, desde já, outro fato incontroverso: o preço de exercício da PUT não estava correlacionado com a valorização ou desvalorização das Participações Itaú nem com o desempenho operacional ou financeiro das Controladas, mas sim obedecia a uma lógica de aplicação de renda fixa¹⁵, assegurando uma saída do investimento para o Itaú, com rentabilidade, no período, equivalente à Taxa CDI acrescida de 3% a.a., caso esse assim o desejasse, tendo em vista que o exercício da PUT era um direito e não uma obrigação.

28. Com efeito, a opção de venda original havia sido outorgada em 2005 pela INDAC ao Itaú, no contexto de uma operação estruturada de financiamento, por meio da qual o Itaú aportou R\$ 550 milhões na Gerdau Participações S.A. (à época, uma subsidiária da Gerdau). Nesse sentido, a Acusação ressaltou que a PUT seria uma “*estrutura análoga a um financiamento, com as devidas garantias comuns a esse tipo de estrutura financeira*”¹⁶.

29. É claro que a mera constatação de formação de preço com base em resultado de equação típica de renda fixa¹⁷ (e não de renda variável) não autoriza, de *per se*, conclusão no sentido da inadequação do preço da Aquisição Itaú, sob o prisma da adquirente. Ao menos não *a priori* e sem sopesar considerações e avaliações acerca do valor das ações adquiridas, bem como os demais benefícios e objetivos almejados com a operação.

30. O que se verifica no antagonismo das visões trazidas no âmbito deste PAS é a contraposição (i) da alegação dos Acusados de que o preço da Aquisição Itaú foi adequado e a estratégia da Gerdau de consolidação das participações nas Controladas justificava o preço pago, no melhor interesse da Companhia; com (ii) a assertiva da Acusação de que o sobrepreço pago na aquisição das Participações Itaú era economicamente injustificável e a operação objetivava, na verdade, beneficiar as Controladoras, eximindo-as das obrigações assumidas na PUT.

31. Tratarei mais adiante dos benefícios e objetivos da operação e dos interesses envolvidos, porém, pontuo, desde já, que não me convence o argumento apresentado pela Companhia e pelos Acusados de que a existência da relação contratual mantida entre o Itaú e as Controladoras (isso é, a PUT) não influenciou a decisão da Gerdau de adquirir as Participações Itaú ao preço dado pelo Itaú, mas apenas teve influência no balizamento do referido preço.

¹⁵ Note-se, inclusive, que, nos termos da PUT, do preço de exercício, acrescido da remuneração pactuada seria deduzido o valor correspondente a 100% do montante total pago pelas Controladas ao Itaú a título de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio até a Data de Exercício.

¹⁶ v. Item 61 do Termo de Acusação (Doc. SEI 0125258).

¹⁷ Note-se que, caso as ações subjacentes ao derivativo tivessem tido, no período, valorização superior à taxa de juros que corrigia o preço de exercício da PUT, seu exercício se tornaria desinteressante sob o prisma do titular da opção e tal valor não seria tomado como baliza para definição do preço de alienação das ações a terceiro.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

32. Embora a Gerdau não estivesse obrigada a adquirir as Participações Itaú nem estivesse juridicamente vinculada à PUT, a meu ver, a sequência de postergações do prazo de vencimento da PUT na iminência de fechamento da Aquisição Itaú e a negociação das condições de pagamento pela Companhia para tornar viável (ou, ao menos, palatável) a aquisição das Participações Itaú, pelo preço que o vendedor estava disposto a aceitar, evidenciam a influência da existência da PUT sobre a decisão da Gerdau de concretizar a Aquisição Itaú.

33. Isso não significa que tal influência seja necessariamente aspecto suficiente para autorizar a conclusão de que a Aquisição Itaú não teria sido aprovada no interesse da Companhia.

34. A Acusação chegou a tal conclusão porque considerou que o valor pago pela Gerdau na Aquisição Itaú era economicamente injustificável e que o Preço de Exercício da PUT, muito mais do que um “balizador de preço”, foi o “próprio racional” da operação.

35. A Acusação fundamentou sua análise na comparação com o preço por ação, bastante inferior, pago pela Gerdau pelas participações adquiridas da Arcelor, um dos maiores *players* internacionais do setor, nas mesmas empresas, e concomitantemente aprovada pelo CA.

36. Como dito, a Aquisição Arcelor consubstanciou negócio jurídico distinto e independente da Aquisição Itaú, tendo como ponto de contato o fato de que ambas Aquisições envolveram participações minoritárias nas mesmas companhias alvo (as Controladas) e foram aprovadas e divulgadas em conjunto, fazendo parte de um mesmo movimento da Gerdau com vistas à futura simplificação de processos e da estrutura societária da Companhia. Embora tivessem amparo numa mesma justificativa estratégica, não havia qualquer condicionante que vinculasse o fechamento de uma à conclusão da outra, consubstanciando, portanto, claramente duas operações independentes.

37. Destaque-se que o contrato celebrado com a Arcelor continha cláusula de *earnout*¹⁸ a dispor que, se a Gerdau viesse a realizar uma operação de compra e venda ou permuta com terceiro envolvendo ações das Controladas, anunciada no período de 12 meses contado do fechamento da Aquisição Arcelor, em que (i) o valor por ação convencionado fosse superior, em 10% ou mais, àquele pago pelas Participações Arcelor, e (ii) o valor agregado da operação fosse superior a US\$ 5 milhões, a Gerdau estaria obrigada a pagar à Arcelor o valor resultante da multiplicação (a) da diferença entre o valor pago por ação na referida transação e aquele pago na Aquisição Arcelor, (b) pelo número de ações anteriormente detido pela Arcelor na Controlada objeto da transação. Na mesma cláusula contratual, contudo, a Arcelor reconhecia que essa disposição não seria aplicável em caso de transação com ações das Controladas envolvendo o Itaú ou qualquer de suas afiliadas.

¹⁸ Cláusula 1.7 d do *Share Purchase Agreement* de 14.07.2015(Doc. SEI 0125088, fls. 246).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

38. Parece-me que tal disposição contratual constitui, no mínimo, evidência de que a Gerdau sinalizara para a Arcelor que a aquisição das Participações Itaú não seguiria um balizamento de preço comparável com a transação realizada com a Arcelor, mas que, para eventuais aquisições futuras (naquele período de doze meses), em havendo preço melhor para outra contraparte, haveria o referido ajuste a repercutir favoravelmente para a Arcelor.

39. Quanto à Aquisição Arcelor, não houve imputação de qualquer irregularidade pela SEP. Seus elementos de preço e condições de pagamento foram referidos no Termo de Acusação porque (i) sua divulgação foi feita em conjunto com a da Aquisição Itaú (e de forma agregada), e, principalmente, (ii) em razão da substancial discrepância dos preços por ação que a Gerdau se dispôs a pagar, respectivamente, na Aquisição Itaú e na Aquisição Arcelor.

40. Consoante os valores constantes dos Laudos Apsis 12.973/14¹⁹, de 2016, o “valor implícito” por ação (assim denominado nos referidos laudos) de cada uma das Controladas, considerando o valor total das transações, foi assim indicado:

Controlada	Valor Acordado Arcelor (R\$)	Valor implícito Ações Arcelor (R\$)	Valor Acordado Itaú (R\$)	Valor implícito Ações Itaú (R\$)
Gerdau Açominas	72.586.209	22,99	416.147.914	73,68
Gerdau Aços Especiais	23.666.396	7,50	135.683.093	24,02
Gerdau Aços Longos	156.941.083	45,74	899.767.328	146,59
Gerdau América Latina	41.786.312	13,23	239.567.361	42,41

41. Embora concorde com os Acusados quanto a que não era de se esperar que os preços praticados nas Aquisições fossem os mesmos, pois se tratavam de contrapartes distintas e negociações independentes, além de terem sido pactuadas diferentes condições de pagamento, a meu ver, isso não significa que a comparação do preço por ação praticado na Aquisição Arcelor seja irrelevante para fins de aferir a racionalidade da Aquisição Itaú.

42. Observo que constou no material submetido aos Conselheiros a informação de que as Participações Arcelor tinham sido adquiridas, em meados de 1998, numa operação estruturada de financiamento, em que também havia sido pactuada uma opção de venda a favor do banco financiador, a qual, entretanto, havia expirado em 2003, sem ter sido exercida²⁰. Da mesma forma

¹⁹ Não se trata do Laudo Apsis submetido ao CA para a deliberação de 13.07.2015. Os Laudos Apsis 12.973/14 (relativos a cada uma das Controladas) tem como data-base 14.07.2015 (data de fechamento das Aquisições) e descrevem como seu objetivo a “Elaboração de cálculos avaliatórios para determinação dos valores individualizados dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos, com os respectivos valores contábeis e valores justos da adquirida, de acordo com a Lei nº 12.973/14”.

²⁰ Do material sobre as Aquisições apresentado aos Conselheiros consta a informação de que “Em meados de 1998, ao adquirir a Siderúrgica Mendes Júnior, a Belgo Mineira (Arcelor Mittal) recebeu uma participação de 5,3% no



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

que o Itaú, a Arcelor não estava obrigada a vender as Participações Arcelor para a Gerdau, mas quis fazê-lo. Também não era de se esperar que a Arcelor alienasse as Participações Arcelor por preço inferior ao valor que reputasse adequado com relação aos ativos, ainda que sua avaliação quanto ao valor justo de tais ativos pudesse diferir da avaliação da compradora ou de terceiros.

43. Concordo com o argumento de que não há exigência de tratamento equitativo pela Companhia com relação aos preços praticados com os diferentes vendedores, não cabendo censura ao fato de se pagar um preço menor àquele que está disposto a vender por menos. Por outro lado, causa estranheza o fato de que o preço por ação de emissão das mesmas companhias, praticado, contemporaneamente, com a Arcelor, tenha sido tão significativamente inferior.

44. A meu ver, não se pode ignorar os preços praticados na Aquisição Arcelor como uma importante referência, pois, via de regra, o preço pago por uma parte independente e sofisticada reflete a melhor *proxy* do valor justo do ativo adquirido.

45. Não se pode desprezar a discrepância dos referidos valores (ainda que não seja o único elemento determinante) no exame quanto à exorbitância do preço da Aquisição Itaú, devendo-se sopesar as diferentes condições de pagamento que fazem com que tais valores não sejam automaticamente comparáveis.

46. A Acusação também reconheceu que “[e]ventuais diferenças resultantes de um processo negocial são esperadas”, contudo, ressaltou que “uma transação entre a companhia e uma parte independente, conhecedora do negócio e com o porte da ArcelorMittal, deve servir como referência de valor justo dos ativos negociados”²¹.

47. É justamente quanto à precificação das ações de emissão das Controladas que divergem diametralmente Acusação e Acusados, o que os conduz a conclusões opostas sobre ter ou não a Aquisição Itaú se voltado a atender ao interesse da Companhia e não ao das Controladoras.

48. A Acusação, ao comparar as Aquisições, concluiu que a Gerdau pagou, pelas Participações Itaú, **3,2 vezes** o preço que teria pago se tivesse negociado esses ativos ao preço por ação praticado na Aquisição Arcelor. Nessa linha, para a Acusação, a Gerdau pagou pelas Participações Itaú o valor total de **R\$ 1.691.165.695,30**, ao invés de **R\$ 527.706.554,03**. A meu juízo, entretanto, não cabe simplesmente aplicar o preço por ação pago à Arcelor como aquele que

capital da Açominas associada com uma dívida junto ao Banco Econômico; Adicionalmente, havia uma **opção de compra** de dita participação pelo Banco, vencível em nov/2003, pelo valor de R\$ 86.220 mil, a qual não foi exercida pelo interventor do Bacen; Dito valor, em 06/2015, atualizado por CDI, corresponde a **R\$ 322 MM**” (grifei). A Aquisição Arcelor foi concluída pelo valor de R\$ 295, 9 milhões.

²¹ Itens 123 e 124 do Termo de Acusação (Doc. SEI 0125258).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

deveria ter sido praticado com o Itaú, nem se pode desconsiderar o fato de que a quantidade total de ações alienadas e as condições de pagamento das Aquisições eram bastante distintas.

49. Com efeito, parcela expressiva do preço pago pelas Participações Arcelor, cerca de **69,8%**, envolveu a entrega de 30.000.000 ações preferenciais de emissão da Gerdau, o que, a meu ver, é uma das particularidades mais importantes da Aquisição Arcelor.

50. Como explorado pelas Defesas, devido ao contexto de crise do mercado de aço à época das Aquisições, a cotação das ações da Gerdau estava em patamares historicamente baixos, de modo que não refletia, na data do fechamento da operação, o real valor da Companhia. Com efeito, desde 08.07.2015, data usada como referência para a precificação das ações preferenciais da Gerdau (i.e., R\$6,86), tais ações experimentaram expressiva valorização, mas também não se pode deixar de reconhecer que a recuperação do mercado de aço e da Companhia nos anos subsequentes a 2016 não era um fator que se pudesse dar por certo ao tempo em que aprovadas as Aquisições.

51. De todo modo, a percepção de que as ações da Gerdau estavam cotadas abaixo do que deveria ser seu valor de mercado constou de relatório de análise de mercado, divulgado à época das Aquisições²², o que foi destacado pelos analistas como um ponto de crítica à operação. Assim, uma “foto” do preço praticado na data do fechamento da Aquisição Arcelor poderia não refletir perfeitamente o real valor da operação.

52. Também reconheço que as intenções dos vendedores com as Aquisições eram distintas. A lista de eventos relacionados às Aquisições apresentada pela Companhia, em resposta a Ofício da SEP, mostra que, desde o início das conversas da Arcelor com a Gerdau, em 2011, a ideia era a realização de permuta das Participações Arcelor por ações da emissão da Companhia, o que representava a troca de ações ilíquidas de emissão das Controladas por ações dotadas de maior liquidez. Já o Itaú sinalizava que desejava se desfazer do investimento, buscando uma saída que, comercial e financeiramente, melhor atendesse aos seus interesses.

53. Assim, embora as Aquisições tenham sido contemporâneas e envolvido participações minoritárias nas mesmas companhias, o contraste das Aquisições não se apresenta como uma questão trivial a ser resolvida apenas com a comparação dos preços por ação praticados, mesmo se considerado que o valor da Aquisição Itaú coincidia com o do Preço de Exercício da PUT.

54. Com relação ao preço praticado na Aquisição Itaú, ao analisar a faixa de avaliação de valor econômico das Participações Itaú apontada no Laudo Apsis, submetido à apreciação dos Conselheiros na RCA de 13.07.2015, que estava expressa em dólares norte-americanos (entre US\$

²² Doc. SEI 0125083, fls. 36.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

308.973.000,00 e US\$ 398.753.000,00)²³, a Acusação concluiu que a Gerdau teria pago um **sobrepço** em faixa situada entre **R\$ 640.000.000,00 e R\$ 870.000.000,00**, considerando, para tanto, conversão para reais pela cotação do dólar em 31.12.2014 (de R\$ 2,65), data-base referida no Laudo Apsis, e não pela cotação vigente no dia útil anterior à RCA (de R\$ 3,19).

55. Embora seja evidente que a Gerdau pagou pelas Participações Itaú um valor muito superior àquele pago pelas Participações Arcelor, cabe notar que a faixa de sobrepreço analisada pelos Conselheiros com base no Laudo Apsis foi diferente da apontada pela SEP, em razão da taxa de câmbio utilizada para converter para reais os valores denominados em dólar no Laudo Apsis.

56. Segundo as Defesas, tendo em vista o setor globalizado em que inserida a Companhia e as Controladas, cujos principais custos de produção e preços de produtos são denominados em dólares norte-americanos, o Laudo Apsis tomou por base o conjunto de premissas e valores fornecidos em dólares e chegou a uma faixa de valores também nessa moeda. Para as Defesas era apropriado utilizar, para fins de conversão para reais, a cotação do dólar do último dia útil anterior à RCA (10.07.2015) e não a taxa de câmbio do dia 31.12.2014, adotada pela SEP.

57. Nesse sentido, as Defesas apontam que, utilizando-se a taxa de câmbio de R\$ 3,1897, o valor máximo apurado em consonância com o Laudo Apsis seria de R\$ 1.271.902.444,00, ou seja, considerando o valor pago ao Itaú (R\$ 1.691.165.695,00), o sobrepreço seria, em tese, de **R\$ 419.263.251,00**. Digo “em tese”, porque concordo que a análise a ser feita neste PAS requer outras considerações para além do valor nominal do preço pago pela Gerdau.

58. Não entrarei no mérito das razões pelas quais as faixas de valor dadas no Laudo Apsis foram fixadas em dólar. Além de não constar dos autos dados relativos à denominação (ou, de alguma forma, vinculação) em moeda estrangeira dos custos, dívidas e receitas das Controladas, nem às justificativas do próprio avaliador para a adoção da moeda estrangeira na avaliação, entendo que não cabe, neste PAS, fazer uma revisão do *valuation* da Companhia, mas sim, como já dito, um exame de racionalidade da Aquisição Itaú, à luz do interesse da Gerdau.

²³ A Apsis foi contratada pela Gerdau para determinar o valor econômico da participação de acionista minoritário nas Controladas (constam do Laudo os percentuais referentes às Participações Itaú), “pela metodologia do Fluxo de Caixa Descontado e pela metodologia de múltiplos, para fins gerenciais”. O laudo destaca que para todas as Controladas utilizaram “a metodologia da rentabilidade futura para determinar os valores econômicos das Companhias, bem como seus investimentos”. Para a Gerdau Açominas, a Gerdau Aços Especiais e a Gerdau Aços Longos, utilizaram adicionalmente “a metodologia por múltiplos, para fins de suporte e validação do valor econômico”. Para a Gerdau América Latina, “em específico, por se tratar de uma Companhia que investe em diversas outras que são tanto operacionais quanto não operacionais, a APSIS apurou os valores econômicos das investidas (...) por rentabilidade futura e, posteriormente, seus respectivos patrimônios líquidos foram ajustados via equivalência patrimonial até encontrarmos o valor econômico” (Sumário Laudo Apsis, de 29.04.2015, fls. 401-404).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

59. Nesse sentido, registro que, uma vez que o laudo apontou para uma faixa de valor denominada em US\$ (e assumindo que tal abordagem faça sentido considerando as operações das Controladas), parece-me pertinente o argumento das Defesas de que a melhor referência para a conversão dos referidos valores para reais seja a taxa de câmbio da véspera da decisão que tomou os valores da avaliação por referência e não a taxa vigente na data-base de 31.12.2014.

60. Cabe reconhecer, inclusive, que a taxa de câmbio de R\$3,20 foi a adotada, em 2015, na tabela constante do slide da apresentação feita ao CA, para converter o teto da faixa do valor econômico das ações das Controladas apurado no Laudo Apsis, refletindo, portanto, a informação considerada pelos Conselheiros em sua tomada de decisão.

61. De todo modo, ainda assim, restava bastante evidente, no material apresentado ao CA, expressivo sobrepreço, que não passou despercebido. Da referida apresentação feita ao CA, destaco o seguinte alerta quanto ao sobrepreço:

“O preço de aquisição negociado respeita a **especificidade de cada acionista**, os **investimentos realizados na Companhia**, os **instrumentos de pagamento** e, no **conjunto das transações**, estão em linha com a avaliação realizada por empresa especializada independente;

Quando analisada individualmente a aquisição das participações junto ao Itaú há que se confrontar o **aparente sobre preço** (sic) em relação a avaliação realizada por empresa especializada independente, com as **condições mais competitivas** na determinação do **preço de cessão dos direitos creditórios**.” (Grifei)

62. Do racional explicitado, percebe-se que os seguintes aspectos foram tomados, à época, como justificativa (i) os investimentos realizados pelos acionistas na Companhia (o que, no caso do Itaú, remete ao aporte de 2005, que veio acompanhado da PUT); (ii) os instrumentos de pagamento utilizados em cada uma das Aquisições (com destaque, no caso do Itaú, para a cessão de quota do FIDC em condições mais vantajosas do que tinham sido aventadas em proposta de outro banco pelo referido ativo); e (iii) a análise das operações em conjunto, o que reduzia o sobrepreço apontado na comparação com a faixa máxima de valor indicada no Laudo Apsis.

63. Com relação ao FIDC, noto que a própria Acusação reconheceu que a cessão dos Direitos Creditórios da Companhia para o Fundo e a permuta da quota única em pagamento da Aquisição Itaú representou uma vantagem para a Gerdau, quando comparada com a segunda melhor proposta para a estruturação da operação de securitização recebida pela Companhia.

64. Os Acusados destacaram que a utilização do FIDC no pagamento ao Itaú revelou-se vantajosa para a Companhia em montante na ordem de R\$ 317 milhões (bruto²⁴), que deve ser

²⁴ Se consideradas as deduções de tributos incidentes (i.e., imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido – 34%, correspondendo a aproximadamente R\$108 milhões), tal valor passa a ser de **R\$209 milhões**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

considerado para fins de análise do preço. Trata-se de argumento defendido pelos Acusados e reconhecido também pela própria Acusação²⁵, que ponderou, entretanto, que tal valor não chegaria à metade do menor sobrepreço que identificou (i.e. R\$ 640 milhões). Quanto a isso, ressalto que, na apreciação quanto a essa vantagem de certo modo “embutida” no fechamento da Aquisição Itaú, não me parece fazer sentido considerar tal montante bruto, mas sim o líquido (de **R\$ 209 milhões**, segundo apontado pelas Defesas), que reflete a “vantagem” efetiva para a Companhia.

65. Além disso, chama atenção o fato de que a referida “segunda melhor proposta” recebida pela Gerdau, de outro banco, com relação à estruturação do FIDC, consta dos autos como sendo a datada de 19.12.2014, que foi encaminhada, em 25.06.2015²⁶, aos Conselheiros para auxiliá-los no processo de aprovação da operação, a qual continha ressalva expressa no sentido de que se tratava de “proposta indicativa” (não vinculante), considerando o cenário de existência das ações judiciais e que o proponente estaria disposto a negociar com base na análise da documentação pertinente²⁷.

66. Por outro lado, pelo cronograma de tratativas apresentado à SEP pela Companhia²⁸, de fevereiro 2015 em diante foram realizadas várias reuniões entre a Gerdau, o Itaú BBA e os assessores jurídicos do banco, para entendimentos acerca das referidas ações judiciais. Quando cotejadas a proposta final apresentada pelo Itaú BBA e a proposta apresentada pelo outro banco para a estruturação de cessão dos Direitos Creditórios via FIDC, observa-se um desequilíbrio do nível de informação considerado pelos respectivos proponentes, que, a meu ver, afeta o grau de comparabilidade das propostas.

67. Veja-se que, mesmo que considerada a taxa de câmbio da véspera da RCA e a vantagem decorrente das condições mais competitivas com relação ao FIDC, ainda restava aos Conselheiros a constatação de sobrepreço em montante superior a duas centenas de milhões de reais, que se dizia ser apenas “aparente” se considerada a Aquisição Itaú em conjunto com a Aquisição Arcelor.

68. Além desses aspectos, as Defesas sustentam que também devem ser computados (i) o benefício esperado com o aproveitamento fiscal do ágio nas futuras incorporações das Controladas

²⁵ “Uma avaliação mais cuidadosa mostra que, de fato, a proposta do Itaú para a constituição do Fundo foi melhor que a segunda melhor proposta em cerca de R\$ 317 milhões. Entretanto, tal valor não chega à metade do menor sobrepreço identificado nos parágrafos anteriores” (Termo de Acusação, Doc. SEI 0125258, fls. 11, item 79).

²⁶ Proposta anexa ao email enviado por André Pires, em 25.06.2015, aos membros do CA (fls. 375).

²⁷ Conforme introdução/premissas da proposta de 19.12.2014: “Buscando evitar gastos desnecessários, foi solicitado pelo Grupo Gerdau a apresentação da presente Proposta Indicativa que leva em conta apenas o cenário de existência das 7 Ações Judiciais mencionadas acima, não tendo sido analisado pelo J. Safra qualquer documentação relativa a tais ações, com exceção de alguns documentos relativos ao processo judicial nº (...). Por tal razão, a Proposta Indicativa ora apresentada serve tão somente o propósito de indicar a estrutura preliminar e condições sob as quais o J. Safra estaria disposto a negociar com o grupo Gerdau para aquisição, administração e gestão das Ações Judiciais de modo integral ou parcial, a depender da posterior análise destes e da mensuração efetiva do valor envolvido” (fls. 376).

²⁸ Resposta da Gerdau, datada de 19.11.2015, ao Ofício nº 254/2015/CVM/SEP/GEZ-4 (fls.213-223),



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

pela Gerdau, cuja reestruturação e simplificação da estrutura societária constituía um dos objetivos da Companhia com as Aquisições; e (ii) a preexistência de um planejamento estratégico da Companhia para a consolidação de sua participação nas Controladas, visando à sua incorporação.

69. No que tange ao aproveitamento fiscal do ágio pago pela Gerdau nas Participações Itaú em eventual operação de incorporação das Controladas que viesse a ocorrer no futuro como se almejava, as Defesas asseveram que esse corresponderia a aproximadamente **R\$ 390 milhões**²⁹.

70. Com efeito, se o objetivo das Aquisições era o de concentrar a participação da Gerdau nas Controladas para, no futuro, transformá-las em suas subsidiárias integrais e incorporá-las, cabia sim a análise dos impactos fiscais decorrentes da operação, inclusive quanto aos benefícios que poderiam vir a ser alcançados com o aproveitamento do ágio.

71. Observo que não há qualquer menção ao tema nem ao valor do possível benefício nos materiais enviados ao CA constantes dos autos. Isso não quer dizer que não tenham sido considerados para fins de avaliação pelos Conselheiros, como de praxe em operações da espécie, mas apenas noto que não foi destacado como justificativa do sobrepreço.

72. O Relatório Booz Allen, trazido aos autos pela defesa dos Conselheiros com Vínculo, mostra que havia um planejamento estratégico anterior envolvendo a simplificação da estrutura societária do Grupo Gerdau. Ademais, como apurado posteriormente, duas das quatro Controladas vieram a ser de fato incorporadas pela Companhia em 2017, a Gerdau Aços Especiais e a Gerdau América Latina³⁰, cumprindo, ao menos em parte, o objetivo almejado.

73. Como dito, não se trata de uma abordagem pura e simples do valor nominal do preço, portanto, considerações dessa natureza se prestam a relativizar certas ponderações quanto aos valores nominais em questão. Por outro lado, entretanto, isso também não implica uma dedução automática na equação do suposto sobrepreço, como se fosse uma parcela a ser por certo recuperada pela Companhia. Afinal, tratava-se de expectativa de aproveitamento fiscal do ágio, a depender de evento futuro, que poderia não se concretizar, de forma que sua ponderação também envolvia certa cautela, tanto que duas das incorporações sequer chegaram a se concretizar.

74. Outro argumento trazido pelos Conselheiros com relação à avaliação do preço das Participações Itaú diz respeito à previsão, no Contrato de Cessão dos Direitos Creditórios, da possibilidade de a Gerdau vir a receber o equivalente a 80% de eventual diferença positiva entre o

²⁹ “[A] diferença entre o preço pago ao Itaú (R\$ 1.691 milhões) e o valor patrimonial (R\$ 541 milhões) das participações adquiridas corresponde a R\$ 1.150 milhões. Pode-se estimar que 34% deste montante representará um benefício em termos de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, correspondendo a aproximadamente R\$ 390 milhões” (Doc. SEI 0184204, fls. 17, item 74).

³⁰ Conforme AGE de 29.12.2017, disponível na página da CVM na rede mundial de computadores.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

valor efetivamente recebido pelo FIDC pelos Direitos Creditórios e o valor pago quando da respectiva cessão, devidamente atualizados, conforme fórmula indicada no contrato (isso é, uma possibilidade de captura de “upside”), que, segundo as Defesas, poderia chegar a **R\$ 329 milhões**.

75. Embora seja natural que tal possibilidade tenha sido um dos fatores também considerados no exame da Aquisição Itaú, tratava-se de expectativa, cujo valor era de difícil aferição e não há elementos nos autos que indiquem que tal ganho era efetivamente esperado, tampouco referência ao referido valor no material apresentado ao CA por ocasião da RCA. Além do que, eventual ajuste a ser recebido pela Gerdau nesse contexto não estaria propriamente relacionado ao valor dos ativos adquiridos, mas sim ao valor dos Direitos Creditórios, que então se constataria terem sido cedidos por menos do que valiam.

76. Os Direitos Creditórios não eram ativos dotados de liquidez e havia risco de recebimento a maior ou a menor, o que justificava a previsão de ajuste do preço “em favor do Fundo ou da Cedente”, a depender da verificação das premissas fundamentais consideradas pelas partes, como previsto no contrato de cessão celebrado entre a Gerdau e o FIDC³¹. Ademais, no Q&A apresentado ao CA sobre a operação esclareceu-se que “[o]s créditos da Eletrobrás não estavam reconhecidos no Balanço da Companhia, pois se enquadravam como Ativos Contingentes (não atendem o critério de “ativo praticamente certo” de acordo com as normas do IFRS).”³²

77. Da mesma forma que a Gerdau poderia vir a receber valores por eventual diferença positiva que viesse a ser verificada, estava obrigada a restituir ao FIDC eventual diferença negativa entre o valor de investimento e o valor efetivamente recebido. Em que pese o FIDC possa ter representado, como dito, uma vantagem comparativa, o risco de não recebimento dos ativos subjacentes (i.e. dos Direitos Creditórios) no prazo em que estimado não foi transferido ao Itaú, que, caso não recebesse os valores avançados via realização pelo FIDC, os receberia da Gerdau, não tendo esse aspecto sido alterado pela estruturação da forma de pagamento. Assim, em que pese ser elemento de ponderação, a expectativa de eventual *upside* via FIDC também não se traduz em redução automática do sobrepreço apontado e eventual *downside* também deveria ser considerado.

78. De resto, em argumento trazido posteriormente pelas defesas dos Conselheiros foi traçado um paralelo entre o preço médio pago por ação de cada uma das Controladas em operações de aquisição ou permuta, ocorridas no período de **2005 a 2014** (devidamente atualizados pela Taxa DI), e o preço médio pago por ação das Controladas na Aquisição Itaú, concluindo por certa compatibilidade de valores, alegando que, embora a Gerdau tenha pago mais caro pelas

³¹ Cláusula 3.1 do Contrato de Cessão de Direitos de Crédito e Outras Avenças (fls. 538).

³² Questão número 11 do “Q&A – Fato Relevante, versão 1 – 03/07/2015” (fls. 519-520).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Participações Itaú, outras partes independentes já estiveram dispostas, no passado, a pagar preço semelhante pelos mesmos ativos.

79. Tal argumento, a meu ver, é de difícil aproveitamento na presente discussão, pois as Defesas não forneceram todos os dados necessários para a análise que se propuseram a fazer, tendo se limitado a apresentar apenas o preço médio pago naquelas operações do passado, atualizado pela Taxa DI. E mais do que isso, trata-se de referência a operações ocorridas ao longo de período muito longo (de quase dez anos), sob circunstâncias distintas, sem qualquer detalhamento e, ademais, não compunham os dados apresentados ao CA para a deliberação.

80. Note-se, ainda, que o patamar do preço total pago pela Gerdau não passou despercebido pelos analistas de mercado, que foram predominantemente críticos em relação às Aquisições, naquele momento ainda analisadas apenas no conjunto, embora tenham também reconhecido alguns de seus pontos positivos. Como exemplo, vale citar os relatórios do BTG Pactual e o do Credit Suisse, constantes dos autos. Do ponto de vista estratégico, a operação não foi questionada, mas sim o preço pago pelas participações.

81. O relatório do BTG Pactual³³ reconhece o esforço da administração da Gerdau em simplificar a estrutura societária da Companhia, reduzindo custos e aumentando a sinergia do Grupo Gerdau, mas apontou ter sido excessivo o preço pago pelas Participações – um múltiplo de preço/patrimônio líquido de 1.1 vezes, enquanto as ações de emissão da Gerdau estavam sendo negociadas a 0.4 vezes.

82. O relatório do Credit Suisse³⁴ reconhece a vantagem obtida nas Aquisições com a estruturação do FIDC, uma vez que os Direitos Creditórios não haviam sido considerados na avaliação da Companhia, mas afirma que, mesmo assim, se descontado o valor equivalente ao FIDC, a Gerdau ainda teria pago um valor alto pelas participações – segundo esse relatório, um múltiplo de preço/patrimônio líquido de 1.0 vezes, enquanto as ações de emissão da Gerdau estavam sendo negociadas a 0.4 vezes.

83. Por todo o exposto até aqui, não me parece possível ignorar que, mesmo consideradas as Aquisições em seu conjunto, como defendido pela administração da Companhia – o que levaria a uma consideração sobre o preço médio das participações adquiridas e não ao preço pago em cada uma das Aquisições –, a precificação suscitava perplexidades. É que, quando examinadas em separado, o preço da Aquisição Itaú mostra-se desarrazoado, especialmente quando comparado ao da Aquisição Arcelor, que serve como importante elemento de referência, ainda que não seja tomado como único aspecto para concluir pela ocorrência de irregularidades na aprovação da Aquisição Itaú.

³³ Doc. SEI 0125083, fls. 36.

³⁴ Doc. SEI 0125083, fls. 46-47.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

84. Além disso, o preço pago pelas Participações Itaú, mesmo tendo se revelado mais próximo da faixa de valor máximo apontada pelo Laudo Apsis do que pressupôs a Acusação inicialmente, refletiu sobrepreço bastante significativo com relação à avaliação do valor econômico das Participações Itaú. E, ainda, o preço pago à Arcelor, se considerados proporcionalmente os valores indicados no Laudo Apsis, estaria abaixo da faixa inferior apontada.

85. Tendo em vista que a Aquisição Itaú estava, no mínimo, balizada pelo Preço de Exercício da PUT oponível à INDAC e garantida pela Metalúrgica Gerdau, cabia aos Conselheiros uma análise ainda mais cautelosa e criteriosa do que se a operação não tivesse tal balizamento, a fim de perquirir seu alinhamento com o interesse da Companhia.

86. Retornarei a esse ponto mais adiante, na seção que trata da infração ao disposto no art. 154 da LSA, com relação especificamente à conduta dos Conselheiros. Antes, porém, passo ao exame das imputações de responsabilidade pelo descumprimento dos art. 245 da LSA e, na sequência, pela infração ao art. 156 da LSA.

IV. ART. 245 – OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

87. A Acusação reputou ter ocorrido infração pelos Conselheiros ao disposto no art. 245 da LSA de forma combinada com o art. 154 da mesma lei, tomando como premissa seu entendimento de que a Aquisição Itaú “foi, na verdade, uma transferência de obrigações entre a Indac e a Gerdau”³⁵ e, portanto, uma operação entre partes relacionadas.

88. A SEP atribuiu, assim, aos Conselheiros, responsabilidade por suposta infração ao art. 245 ao terem aprovado a Aquisição Itaú em condições não comutativas, ressaltando que os Conselheiros não apenas sabiam da existência da PUT, como assumiram que levaram em consideração o seu conteúdo, tendo em vista que o Preço de Exercício se refletiu no preço da Aquisição Itaú, fazendo com que a Gerdau arcasse com um ônus que não era seu, mas de suas Controladoras. Para a Acusação, a infração restou ainda mais clara pela análise do sobrepreço verificado e pelo contraste com a Aquisição Arcelor.

89. Consoante o disposto no art. 245 da LSA, “os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas” (grifei). O dispositivo legal trata de operações celebradas entre partes relacionadas.

³⁵ Item 104 do Termo de Acusação (Doc. SEI 0125258, fls. 13).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

90. Como é cediço, o conceito de “partes relacionadas” pressupõe a existência de vínculo entre as partes, do qual resulte uma relação de dependência ou de significativa influência, que abre espaço para a realização das negociações em condições não comutativas. Nesse sentido:

“Inicialmente, me parece oportuno esclarecer que, para fins contábeis, conforme pronunciamento aprovado pela Deliberação CVM nº 26/86: ‘parte relacionada são as entidades (físicas ou jurídicas) com as quais uma companhia tenha a possibilidade de contratar (no sentido lato deste termo) em condições que não sejam as de comutatividade e independência que caracterizam as transações com terceiros alheios à companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra área de influência’.

Por essa conceituação, verifica-se a importância do controle ou influência significativa da gestão operacional de uma das partes sobre a outra, **de maneira que uma delas se torne impossibilitada de decidir em favor de seus próprios interesses**. A impossibilidade resulta do controle exercido por uma das partes, a qual determina a definição de condições de negociação. O conceito de partes relacionadas abrange, assim, toda entidade (no conceito contábil, naturalmente) física ou jurídica, desde que haja qualquer vínculo entre as partes, do qual resulte uma relação de dependência ou significativa influência que permita a possibilidade das negociações não serem realizadas, como se fossem praticadas com terceiros, alheios à entidade.

Contudo, deve-se notar que o fato de duas entidades serem partes relacionadas não implica, necessariamente, que as condições entre elas provoquem qualquer condição de favorecimento. Mas o fato de serem relacionadas importa na necessidade de uma análise mais cautelosa e criteriosa das transações entre elas realizadas, notadamente à luz do artigo 245 da Lei nº 6.404/76.”³⁶ (Grifei)

91. Não resta dúvida de que a Aquisição Itaú teve repercussões diretas e imediatas para as Controladoras, uma vez que a venda das Participações Itaú para a Gerdau implicou na perda de objeto da PUT. Contudo, a meu ver, isso não insere a Aquisição Itaú no escopo do art. 245.

92. Há elementos nos autos a comprovar que a Aquisição Itaú não só foi contratada, mas também foi negociada, entre a Gerdau e o Itaú, que são partes independentes. As Controladoras, embora diretamente afetadas pelo resultado da Aquisição Itaú, não participaram das negociações nem figuraram na operação, de modo que não se trata propriamente de transação “entre” partes relacionadas, mas operação com reflexos que alcançam partes relacionadas, o que é distinto.

93. Ademais, em que pese o já referido balizamento de preço, as condições de pagamento negociadas entre a Gerdau e o Itaú foram distintas da prevista na PUT (em que o pagamento integral era exigível em dinheiro e à vista). Portanto, não estava a Gerdau negociando com uma parte relacionada e impossibilitada de decidir em favor de seu próprio interesse, embora ainda

³⁶ Trecho do voto do ex-diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, no PAS CVM nº 17/00, j. 14.04.2014.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

reste analisar se teria concordado com preço excessivamente oneroso, deixando prevalecer na decisão de aquisição interesse estranho à Companhia.

94. Concluo, portanto, que não cabe responsabilização por ofensa ao disposto no art. 245. Eventual irregularidade, a meu ver, estaria abarcada pelo art. 154 da LSA, se caracterizada a atuação dos Conselheiros com desvio de finalidade, o que será analisado mais adiante.

V. ART. 156 – CONFLITO DE INTERESSES

95. Especificamente com relação aos Conselheiros Com Vínculo, a Acusação entendeu que, por estarem em situação de conflito de interesses, ao terem deliberado sobre a aprovação da Aquisição Itaú, teriam infringido o disposto no art. 156 da LSA, que prevê impedimento de voto.

96. Em síntese, a SEP considerou que: (i) a estrutura de controle das empresas do Grupo Gerdau era familiar e membros da família dos Conselheiros Com Vínculo ocupavam os principais cargos da administração das empresas do grupo; (ii) os Conselheiros Com Vínculo atuavam também em cargos na administração das Controladoras, exceto Richard Gerdau, que, embora formalmente externo à administração da INDAC, atuou como seu procurador na celebração de aditivos à PUT; (iii) os “proprietários” da INDAC eram, em última instância, os próprios pais dos Conselheiros Com Vínculo; e (iv) os benefícios que a Aquisição Itaú traria para as Controladoras, por eximi-las do cumprimento de suas obrigações no âmbito da PUT, constituíam benefícios particulares, a colocar os Conselheiros Com Vínculo em situação de conflito de interesses.

97. A premissa que ampara esta acusação é a de que o interesse econômico que os Conselheiros Com Vínculo tinham na INDAC, por serem “herdeiros diretos” dos controladores finais, faz com que os interesses de seus pais devam ser tratados como interesses pessoais dos Conselheiros Com Vínculo. Para a SEP, diante disso, “não é possível afirmar” que os Conselheiros Com Vínculo, deliberando sobre a operação, deixariam de levar em conta tais interesses.

98. Ainda que o interesse das Controladoras em se eximir das obrigações decorrentes da PUT seja elemento fundamental para a análise da irregularidade atribuída pelo descumprimento do disposto no art. 154, entendo que, para fins do impedimento de voto de que trata o art. 156, não se pode tratá-lo como “interesse pessoal” dos referidos administradores.

99. Não se está a tratar de conflito de interesses da Metalúrgica Gerdau, como garantidora da PUT, caso a deliberação sobre a Aquisição Itaú fosse matéria de alçada da assembleia de acionistas da Companhia, nem de conflito de interesses das Controladoras que, direta e indiretamente, elegeram os Conselheiros Com Vínculo. O art. 156 trata do conflito de interesses dos próprios administradores, enquanto pessoas naturais.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

100. Consoante o disposto no art. 156 da LSA, “**é vedado** ao administrador intervir em qualquer operação social **em que tiver interesse conflitante** com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores” (grifei).

101. Para fins desse artigo, o interesse conflitante com os da companhia deve ser, necessariamente, o interesse particular do administrador. Por “interesse particular”, em linha com os precedentes da CVM, entende-se o interesse pessoal do administrador, enquanto pessoa natural, ou, por extensão, os interesses de partes a ele relacionadas, como, por exemplo, uma pessoa jurídica na qual tenha interesse, ou mesmo um parente próximo, mas isso quando esses forem contrapartes da companhia para qual o administrador atua.

102. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto da então Diretora Ana Dolores de Novaes em caso em que o alcance do art. 156 foi discutido:

“Não se está abordando **neste artigo eventual interesse do acionista que elegeu este administrador, questão endereçada no art. 154, §1º, da [Lei nº 6.404/1976]**. O administrador é obrigatoriamente pessoa física (art. 145). Portanto, **o conflito de interesses do art. 156 é em relação à pessoa física do administrador** e ocorre, por exemplo, quando há uma transação/operação social sendo negociada **com a companhia na qual o administrador:**

- i. seja parte da contrato/operação; ou
- ii. tenha consciência acerca de um interesse à época da operação; ou
- iii. **sabia que uma parte relacionada dele** (p. ex. parente próximo ou sociedade na qual ele tem interesse) **era parte do contrato/operação e tinha um interesse.**

Nesses casos, tendo em vista o **interesse peculiar do administrador** na realização do negócio, há de se pôr em dúvida a sua isenção para avaliar, à luz do interesse comum dos acionistas, se a transação, ao preço e nos demais termos submetidos à administração, deve ser aprovada.”³⁷ (Grifei)

103. Ressalte-se que, consoante entendimento reiterado do Colegiado da CVM³⁸, o art. 156 da LSA trata de conflito de interesses formal, ou seja, que deve ser verificado *a priori* (e não à luz do sentido do voto proferido), de modo que o administrador está impedido de participar da deliberação em que tenha interesse pessoal conflitante com o da sociedade para a qual atua. Talvez justamente em função da consequência prevista (impedimento) pelo conflito definido *ex ante* é que tenha se adotado nos precedentes da CVM uma abordagem mais restritiva do alcance do conflito de interesse do administrador para fins do art. 156, não abrangendo, por exemplo, qualquer

³⁷ Voto da ex-diretora Ana Dolores de Novaes, no PAS CVM nº 09/2006, j. 05.03.2013.

³⁸ Nesse sentido, ver Processo CVM nº RJ2004/5494, j. 16.12.2004; PAS CVM nº 12/2001, j. 12.01.2006; Processo CVM nº RJ2007/3453, j. 04.03.2008; PAS CVM nº RJ2013/1840, j. 15.04.2014; PAS CVM nº RJ2013/11699, j. 02.09.2014; PAS CVM nº 09/2009, j. 21.07.2015; Processo CVM nº SP2015/0339, j. 25.09.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

situação em que se verifique potencial falta de isenção, o que não corresponde à abordagem que tem prevalecido nos julgamentos do Colegiado.

104. Também em linha com os precedentes da CVM, cabe reconhecer que o art. 156 da LSA não está a tratar de situações em que o administrador simplesmente ocupe, concomitantemente, cargos na administração de companhias pertencentes ao mesmo grupo econômico, ou mesmo situações em que seu assento no CA tenha sido resultado de indicação do acionista controlador da companhia para a qual atua³⁹. Essas situações, a depender das particularidades envolvidas, podem ser elementos aptos a ser considerados na apuração de uma eventual atuação desleal ou com desvio de finalidade, mas não para configurar, de *per se*, a existência de um interesse particular do administrador para fins do art. 156 da LSA.

105. Referido dispositivo tampouco objetiva engessar a atuação de administrador pertencente à família que controla o grupo econômico do qual faz parte a companhia para a qual atua. Como bem destacado nas defesas dos Conselheiros Com Vínculo, a CVM já se manifestou diversas vezes⁴⁰ a respeito da impossibilidade de se presumir uma irregularidade apenas pela existência de relação de parentesco, sendo necessário que essa informação se some a outros indícios que, juntos, formem prova suficiente para configurar a irregularidade.

106. Assim, em que pesem os estreitos vínculos familiares dos Conselheiros Com Vínculo com os controladores finais do Grupo Gerdau e o fato de que dois deles exerciam, concomitantemente, cargos na administração das Controladoras, deve-se ter em conta também que a Aquisição Itaú não tinha como contraparte as Controladoras, não se tratando de transação entre partes relacionadas, e que, no caso de desvio para privilegiar interesses reflexos das Controladoras derivados da possível extinção da PUT, a irregularidade de que se trata seria a de desvio de finalidade, ou seja, de descumprimento ao art. 154 da LSA.

107. Por essas razões, considero que não se configurou infração ao disposto no art. 156 da LSA pelos Conselheiros Com Vínculo.

³⁹ “Vale ressaltar que não se considera que o administrador esteja necessariamente atuando em conflito de interesses em situações que envolvam o interesse do acionista que o elegeu. De fato, a regra prevista no artigo 156 da Lei das S.A. refere-se aos casos em que o administrador tenha interesse pessoal ou venha a ser diretamente beneficiado pela deliberação a ser tomada” (Grifei) (EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. In: Mercado de Capitais – Regime Jurídico. 3ª Ed. rev. e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 476)

⁴⁰ Nesse sentido, PAS CVM nº 2000/0389, j. em 07.05.2002; PAS CVM nº 06/01, j. em 09.04.2004; PAS CVM nº 13/00, j. em 17.04.2012; PAS CVM nº 25/04, j. 30.09.2008; PAS CVM nº 11/08, j. 21.08.2012; e PAS CVM nº RJ2012/11002, j. 08.12.2016.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

VI. ART. 154 – DESVIO DE PODER

108. A Acusação imputou aos Conselheiros responsabilidade pelo descumprimento do dever fiduciário de atuar “para lograr os fins e no interesse da companhia”, em infração ao art. 154.

109. Entendeu a SEP que os Conselheiros atuaram com desvio de poder por terem se desalinhado do interesse da Gerdau, ao aprovar a Aquisição Itaú por preço economicamente injustificável, operação que teria representado, na verdade, a assunção pela Companhia da obrigação decorrente da PUT, a qual essa não estava juridicamente vinculada, a fim de eximir suas Controladoras do cumprimento de obrigações decorrentes da PUT.

110. É pertinente repisar que, de fato, a Companhia não tinha obrigações com relação à PUT, seja perante suas Controladoras seja em face do Itaú. É bem verdade que tanto a Acusação quanto as Defesas reconhecem que a operação que deu origem à PUT traduziu-se, em essência, em operação estruturada que emulava uma espécie de financiamento, cujos recursos desembolsados pelo Itaú financiaram, em última análise, investimentos da Companhia.

111. Contudo, independentemente da destinação à Companhia dos recursos originalmente desembolsados pelo Itaú, é forçoso reconhecer que, sob o prisma jurídico, a “devedora do financiamento” (por assim dizer, fazendo referência à parte que tem a obrigação de “repagamento”, neste caso, de pagamento em caso de exercício da PUT) era a INDAC, pois foi ela que assumiu essa obrigação, por sua vez, garantida pela Metalúrgica Gerdau.

112. Note-se que, em contrapartida, o Itaú pagou à INDAC prêmios pela outorga da PUT, pagamentos que, inclusive, se repetiram quando das prorrogações e renovações da opção. O Instrumento da PUT celebrado em 31.05.2010⁴¹ previa o pagamento de prêmio de R\$ 10,9 milhões e Data de Exercício em 29.05.2015. Já o aditivo celebrado em 27.05.2015⁴² estipulou pagamento de prêmio de R\$ 500 mil e prorrogou a Data de Exercício para 30.06.2015. O aditamento de 29.06.2015⁴³ alterou a Data de Exercício para 10.07.2015 e foi cobrado prêmio de R\$150 mil. Por fim, o quarto e último aditamento, celebrado em 08.07.2015⁴⁴, estipulou prêmio de R\$ 500 mil e prorrogou a Data de Exercício para 07.08.2015.

113. A própria defesa dos Conselheiros com Vínculo afirmou que “a Operação, **que não envolve o controlador**, representa apenas algo equivalente ao **desfazimento de outra operação prévia**, com a mesma parte independente que é o Itaú” (grifos do original⁴⁵). Ou seja, reconhecem

⁴¹ Cláusula 4.1 (DOC SEI nº 0125088, fls. 342-349).

⁴² Cláusula 4.1 (DOC SEI nº 0125088, fls. 354-359).

⁴³ Cláusula 4.1 (DOC SEI nº 0125088, 361-364).

⁴⁴ Cláusula 4.1 (DOC SEI nº 0125088, fls. 366-370).

⁴⁵ Item 51 da defesa dos Conselheiros com Vínculo e dos DRIs (Doc. SEI 0184204).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

a estreita correlação entre a Aquisição Itaú e o “aporte” feito em 2005, que corresponderia, em essência, a um financiamento para a Companhia.

114. Claro que, tecnicamente, não se fala em “repagamento de financiamento”. Mas, do ponto de vista econômico, a PUT assegurava ao Itaú uma saída do investimento com garantia de renda fixa e, na hipótese em que, no período em questão, as ações se valorizassem mais do que a renda fixa assegurada, o exercício da Opção de Venda se tornaria desinteressante para o Itaú e, vencida a PUT e não exercida, as Controladoras estariam desoneradas de suas obrigações e o Itaú sairia do investimento (se assim o desejasse) alienando as Participações Itaú por preço superior a terceiros.

115. Por outro lado, na hipótese de a valorização das ações ser inferior à referida renda fixa no período, a saída do investimento através do exercício da PUT é que se tornava, financeiramente, mais interessante para o Itaú, salvo se pudesse obter o mesmo retorno assegurado pela PUT por meio da alienação a *outrem* das Participações Itaú, que foi, em linha gerais, o que ocorreu neste caso. É certo que as condições de pagamento da Aquisição Itaú foram diferentes do que teriam sido no caso de exercício da PUT, o que também não é de se estranhar, pois negociações da espécie, em regra, levam em conta tanto aspectos financeiros quanto comerciais.

116. É neste contexto que analisamos se houve desvio de poder por parte dos Conselheiros na aprovação da Aquisição Itaú, que, como já dito, foi aprovada por unanimidade, na RCA de 13.07.2015, da qual participaram e deliberaram tanto os Conselheiros Com Vínculo quanto os Conselheiros Sem Vínculo (incluindo os Conselheiros Independentes).

117. Conforme também já abordado, tratou-se de decisão eminentemente negocial, o que, todavia, em que pese a deferência que a CVM deve manter com relação a esse tipo de decisão, não exime os Conselheiros de terem sua decisão analisada no mérito.

118. Não se cuida aqui de exame de falha procedimental por falta de diligência (art. 153), mas sim de acusação de desvio de poder (art. 154), em operação que impactava diretamente interesse das Controladoras, impondo a todos os Conselheiros um *standard* de conduta ainda mais elevado, a evitar que interesses das Controladoras se confundissem com os da Gerdau, em detrimento dessa⁴⁶.

119. Ressalto, desde já, que, embora estejamos diante de questionamento acerca da regularidade da aprovação da Aquisição Itaú à luz da defesa do interesse da Companhia, a irregularidade ora examinada não apresenta características tão flagrantes como em outros casos em que a CVM analisou a infração ao art. 154 da LSA⁴⁷.

⁴⁶ v. PAS CVM nº RJ2005/7229, Rel. Marcelo Trindade, j. em 10.05.2006.

⁴⁷ Nesse sentido: PAS CVM nº 02/2011, j. em 08.12.2015; PAS CVM nº RJ2012/3110, j. em 14.02.2017; e PAS CVM nº 14/2009, j. em 11.08.2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

120. Pelos elementos trazidos aos autos, havia também objetivos estratégicos bem delineados, não se podendo dizer que a Aquisição Itaú tenha sido arquitetada com o único e exclusivo fim de livrar as Controladas das obrigações por essas assumidas na Opção de Venda.

121. Consoante refletido no Fato Relevante, as Aquisições tinham como justificativa estratégica o aumento da participação acionária nas Controladas⁴⁸ com vistas (i) à possível transformação dessas, no futuro, em subsidiárias integrais ou sua incorporação; (ii) a consolidar o recebimento de dividendos; e (iii) a proporcionar maior facilidade de acesso ao mercado de capitais.

122. Não deixo de reconhecer que tais motivações existiam e eram legítimas, coerentes e consistentes com o movimento estratégico da Companhia, que já havia se iniciado em períodos anteriores⁴⁹. Isso, entretanto, a meu ver, não esgota a análise acerca da infração.

123. Nesse ponto, entendo que a análise deste caso volta a se entrelaçar umbilicalmente com toda a discussão já detalhada sobre valores e condições de pagamento da Aquisição Itaú, na medida em que não é razoável considerar, mesmo à luz dos legítimos objetivos estratégicos da Companhia, que o alinhamento da aquisição das Participações Itaú com o interesse da Companhia estivesse presente a qualquer preço e sob quaisquer condições.

124. Obviamente, essa não seria sequer a linha de defesa dos Conselheiros, que alegam ter agido no melhor interesse da Companhia, por entender que o valor de R\$1,69 bilhão, pago ao Itaú, nas condições de pagamento contratadas, consubstanciava, a seu ver, preço adequado e não excessivo, razão pela qual entendem que atuaram em linha com os seus deveres fiduciários.

125. Entendo que à CVM não cabe analisar a Aquisição Itaú sob a perspectiva do que seriam condições ideais de contratação, tampouco de avaliar resultados financeiros ou verificar se foram concretizados *a posteriori* os objetivos inicialmente almejados, que poderiam até mesmo se frustrar sem que isso implicasse em qualquer irregularidade, sendo certo que o cumprimento dos deveres fiduciários não se traduz em obrigação de resultado, mas de meio.

126. Com efeito, o desvio de finalidade poderia ser afastado, independentemente dos resultados gerados pela operação para a Companhia, se as justificativas apresentadas para fundamentar o investimento fossem consideradas plausíveis e racionais no contexto da operação.

⁴⁸ Como destacado pelas Defesas, entre os anos de 2005 e 2014, a Companhia realizou uma série de permutas e aquisições de participações minoritárias nas Controladas, elevando sua participação de aproximadamente 89% para aproximadamente 94% do capital social dessas sociedades e, em 2015, após as Aquisições, essa participação passou para 99% do capital social das Controladas.

⁴⁹ Nessa linha, as Defesas tiveram êxito em demonstrar que a simplificação da estrutura societária do Grupo Gerdau não era novidade e que vinha ocorrendo desde o ano de 2005, a partir das conclusões e soluções apresentadas pela consultoria Booz Allen Hamilton, contratada, à época, para avaliar opções para gerar mais valor para os acionistas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

127. Pelos materiais constantes dos autos que foram apresentados aos Conselheiros para a tomada de decisão, reconheço que avaliaram a oportunidade e a viabilidade das Aquisições sob diversos aspectos, englobando, além dos objetivos estratégicos acima referidos, a estratégia de negócios da Gerdau e as condições de pagamento (*vis-a-vis* a situação patrimonial da Companhia).

128. Por outro lado, e não menos importante, avaliaram a Aquisição Itaú ao mesmo tempo em que deliberaram sobre a Aquisição Arcelor, portanto, com plena ciência da discrepância de preço. Além disso, entre os materiais examinados pelos Conselheiros constava o Laudo Apsis, a tratar de avaliação do valor econômico das ações das Controladas, objeto da operação, o que sem dúvida constitui um dos elementos importantes a serem considerados.

129. Independentemente de eventuais ressalvas que possam ser feitas quanto às limitações que estão presentes em avaliações da espécie ou das premissas que tenham sido adotadas (muitas vezes fornecidas pela administração das avaliadas), fato é que havia um laudo a valor econômico, por empresa especializada, que fora contratado pela própria Gerdau e apresentado como subsídio para a deliberação acerca da Aquisição Itaú pelos Conselheiros.

130. O Laudo Apsis, segundo a Acusação, apontava para uma faixa de preço cujo parâmetro **máximo** foi em muito superado pelo preço praticado na Aquisição Itaú, mesmo considerando os ajustes apontados pelas Defesas, tanto com relação à taxa de câmbio utilizada pela SEP para indicar a faixa de sobrepreço, quanto com referência à vantagem comparativa das propostas recebidas quanto ao FIDC. De todo modo, a faixa máxima de valor prevista no Laudo Apsis continuava sendo superada em mais de duas centenas de milhões de reais, só sendo diluída com o tratamento conjunto das Aquisições, na abordagem do preço médio de operações independentes.

131. Note-se que quando a Acusação apontou para a referida faixa de sobrepreço se referiu ao Laudo Apsis (ou seja, à diferença entre o preço praticado na operação e o valor apontado no laudo), não se confundindo com a questão da discrepância dos preços por ação praticados na Aquisição Arcelor, os quais a SEP reputou serem os melhores parâmetros do valor justo.

132. Nesse aspecto, ainda que concordando com as defesas no sentido de que as negociações com partes independentes estavam sujeitas a uma série de fatores e particularidades que não se comunicavam entre si e que levaram a condições distintas de negociação e contratação, não se pode ignorar, como dito, a relevante referência de valor que se extrai da Aquisição Arcelor, não havendo qualquer motivo, dentro de uma análise de racionalidade, para considerar que a Arcelor teria vendido barato suas participações a compensar, no conjunto, o alto preço fixado pelo Itaú.

133. Pelas razões já explicitadas, entendo que não cabe entrar aqui na discussão sobre as premissas e equações feitas na avaliação e precificação nem tampouco na oportunidade e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

conveniência de acoplar a estruturação do FIDC na composição das condições de pagamento, mas ressalto que não é preciso fazê-lo para analisar se, em linhas gerais, as justificativas quanto a precificação da Aquisição Itaú são plausíveis e racionais no contexto da operação.

134. Isso porque, mesmo sem refutar os referidos ajustes na aferição do sobrepreço com relação ao Laudo Apsis, não vejo como ignorar a magnitude do descolamento que restou demonstrado. Esse aspecto, em conjunto com a referência dada pela Aquisição Arcelor e com o fato de que a operação tinha como reflexo a extinção da PUT, me fazem concordar com a Acusação quando afirma que o preço de exercício da PUT não foi apenas um balizador, mas, implicitamente, é o que revela o próprio racional da operação: viabilizar a reversão do aporte do Itaú, saída a que esse tinha direito em decorrência da PUT, mas não oponível à Gerdau.

135. Em outras palavras, tais elementos me conduzem à constatação de que o preço da Aquisição Itaú não se mostrava economicamente justificável sob a perspectiva da compradora e ao reconhecimento de que prevaleceu, na aprovação pelos Conselheiros, o interesse de acomodar, em condições de pagamento viáveis para a Companhia, a operação de saída do investimento a que o Itaú tinha direito e não as justificativas estratégicas apresentadas.

136. As sucessivas postergações do vencimento da PUT na proximidade do fechamento da Aquisição Itaú reforçam e corroboram esse entendimento. Como relatado, originalmente, a PUT tinha vigência até 31.05.2006, tendo sido renovada por períodos sucessivos de um ano, até 2010, quando foi repactuada e passou a vencer em 29.05.2015. Em 27.05.2015, 29.06.2015 e 08.07.2015, a data de exercício foi sucessivamente prorrogada, tendo sido finalmente fixada em 07.08.2015.

137. Cabe lembrar que a Gerdau não estava juridicamente vinculada à PUT, não integrando, portanto, o seu interesse, evitar o exercício da PUT.

138. Em minha visão, entretanto, pelas circunstâncias que se apresentaram, os Conselheiros da Gerdau, conhecedores dos termos da PUT e do objetivo do Itaú de sair do investimento, aprovaram a Aquisição Itaú mesmo a preço economicamente desarrazoado. Ainda que tenham buscado acomodar o excessivo sobrepreço dentro do que entenderam ser as melhores condições de pagamento possíveis. Em última análise, deixaram prevalecer o propósito de exoneração das obrigações das Controladoras, em detrimento da própria Companhia. Assim, o conjunto de todos os acionistas da Gerdau, incluindo os minoritários, acabou arcando com o ônus de um preço excessivamente alto que era oponível à INDAC e não à Companhia.

139. Ainda que esse não tenha sido o único propósito da Companhia com a operação, estou convencida de que foi o determinante para a aprovação da Aquisição Itaú.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

140. Não se trata aqui de responsabilizá-los por erro de julgamento nem por não ter a Companhia alcançado condições ideais para a aquisição das Participações Itaú. Tampouco está a infração relacionada a aferição de benefício particular, o que certamente sequer poderia ser alegado (e de fato, não foi) com relação aos Conselheiros Sem Vínculo.

141. A ofensa ao art. 154 verificou-se, a meu juízo, porque restou demonstrado que os Conselheiros dispunham de todas as informações acerca do preço exorbitante, o qual, por sua vez, compromete a racionalidade da operação, sob a ótica do interesse da Companhia, e conscientemente se pautaram pela premência de viabilizar a saída do Itaú ao preço pactuado na PUT. Não obstante a excessiva onerosidade da Aquisição Itaú, os Conselheiros optaram por validá-la, apenas mitigando-a por meio da aprovação de condições de pagamento que tornassem factível sua implementação pela Gerdau.

142. Tendo em vista que a atuação, a meu ver, foi intencional, cabe reconhecer que também estavam presentes e restaram demonstradas justificativas estratégicas a demonstrar a utilidade e a relevância dos ativos para a Companhia, o que levarei em consideração na dosimetria da pena.

143. Os Conselheiros, entretanto, têm deveres para com a Companhia e cabia-lhes assegurar que as repercussões da obrigação que não era da Gerdau não fossem arcadas, em última análise, por todos os acionistas, inclusive os minoritários, quando tal preço era oponível à Controladora.

144. Ainda que a Companhia tenha sido, no passado, a destinatária do "financiamento" que deu origem à PUT, não restaram para a Gerdau obrigações de "repagamento" de tal "financiamento" e eventual argumentação no sentido de que deveria arcar com o ônus da PUT estaria desalinhada com o interesse social, tendo em vista tal compromisso constituía obrigação das Controladoras.

145. De todo modo, cabe também considerar para fins de fixação da penalidade que este caso, diferentemente de diversos outros precedentes que ensejaram a análise de desvio de finalidade, não envolveu fraude nem operação realizada com o único propósito de lesar a companhia.

146. Por fim, releva destacar que o fato de a Aquisição Itaú ter sido aprovada pela unanimidade do CA, incluindo os Conselhos Sem Vínculo, com relação aos quais sequer se cogitou de conflito de interesses, não afasta nem reduz a responsabilidade de todos os Conselheiros. A infração pelo art. 154 não se deu (nem requer) pela aferição de benefício ou vantagem, seja direta ou indireta, por isso não se distinguindo, nesse aspecto, a situação dos Conselheiros pelo fato de pertencerem ou não à família dos controladores finais da Companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

147. A aprovação da Aquisição Itaú consubstanciou deliberação do órgão colegiado, sem que tenha havido qualquer ressalva por nenhum de seus membros e, assim, todos concorreram para a formação da vontade coletiva e devem responder pela referida irregularidade⁵⁰.

148. Por essas razões, voto pela responsabilização de todos os Conselheiros pela infração ao disposto no art. 154, por terem aprovado a Aquisição Itaú em desvio de finalidade.

VII. ART. 116, P.U. – EXERCÍCIO ABUSIVO DO PODER DE CONTROLE

149. A Acusação imputou às Controladoras responsabilidade por conduta omissiva em suposto exercício abusivo do poder de controle, em descumprimento do art. 116, p.u., da LSA.

150. A SEP considerou que, embora as decisões tenham se dado no âmbito do CA da Gerdau, as Controladoras, por terem deveres e responsabilidades perante os demais acionistas da Companhia, não poderiam ter deixado “de adotar providências compatíveis com a relevância e a gravidade dos fatos” relacionados à realização da Aquisição Itaú, ao terem “tomado conhecimento da proposta e da aprovação de realização de operação que iria beneficiá-las em detrimento da Gerdau S.A. e de seus acionistas”.

151. Em síntese, a Acusação imputou responsabilidade às Controladoras por terem se omitido com relação à contratação da operação realizada entre a Gerdau e o Itaú.

152. Em que pese tudo que já foi dito sobre os reflexos da Aquisição Itaú na extinção da PUT, por perda de objeto, concordo com as defesas no sentido de que não cabia à Metalúrgica Gerdau ou à INDAC - na qualidade de controladoras direta e indireta, respectivamente - interferir no processo decisório que era de alçada do CA da Companhia (e não uma operação sujeita à deliberação da assembleia). Tampouco deveria a INDAC tomar medidas para interferir na deliberação da Gerdau, por meio do controle que exercia sobre a Metalúrgica Gerdau.

153. Pelo contrário, parece-me que caso a Acusação tivesse reunido elementos a demonstrar que as Controladoras atuaram nas discussões havidas entre a Companhia e o Itaú, seja na discussão do preço ou das condições de pagamento, com vistas a de algum modo pressionar a Companhia a

⁵⁰ Tal tratamento encontra amparo na jurisprudência da CVM, a exemplo do PAS CVM nº 18/2008, j. 14.12.2010: “(...) Mas, desde já, devo lembrar que os conselheiros têm responsabilidade colegiada, salvo quando consignarem discordância sobre os atos praticados. Essa responsabilidade geral afeta, portanto, a todos os membros do Conselho, indistintamente”. E na doutrina: “[o] conselho de administração constitui órgão de deliberação colegiada (artigo 138); assim, a eficácia de sua manifestação de vontade depende de um ato coletivo, a deliberação, que vincula os seus membros. Não há, em princípio, manifestação individual de vontade de cada conselheiro, senão para formar a vontade coletiva. Da prática de atos irregulares por parte do órgão decorre a responsabilidade solidária de todos os seus membros. Para desonerar-se da responsabilidade o conselheiro deve consignar em ata sua discordância ou dar ciência por escrito ao órgão, ao conselho fiscal ou à assembleia geral” (EIZIRIK, Nelson. In A Lei das S/A Comentada. Volume II – Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011, pp. 405-406).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

aprovar a Aquisição Itaú apenas para lhes eximir de cumprir a PUT, tal atuação configuraria uma interferência indevida no processo decisório da administração da Gerdau.

154. Ainda que eu discorde do argumento das Controladoras de que a operação teria sido aprovada por razões estranhas à existência da PUT e reconheça que as Controladoras e a Gerdau tinham administradores em comum (e que, portanto, a Aquisição Itaú era também de conhecimento de administradores das Controladoras), não restou demonstrada a atuação das Controladoras com vistas a intervir nas discussões e avaliações realizadas (atribuições que, repise-se, não lhes cabia exercer), tanto que a própria SEP as acusou por omissão.

155. A Acusação parece ter partido da presunção de que a Gerdau celebrou a Aquisição Itaú a mando das Controladoras. Contudo, se deparou com o seguinte: (i) o CA era composto por três Conselheiros Com Vínculo e os outros três Conselheiros Sem Vínculo, entre esses, dois Conselheiros Independentes, ainda que todos eleitos com o voto da controladora, e (ii) a operação foi aprovada por unanimidade. A competência era do CA e sequer havia maioria formada por conselheiros com vínculo com as Controladoras.

156. Não tendo reunido elementos probatórios (ainda que em prova indiciária) aptos a demonstrar a influência direta das Controladoras, a Acusação recorreu à imputação de responsabilidade por conduta omissiva.

157. Em que pese o Colegiado da CVM já tenha decidido no sentido de que é possível responsabilizar o acionista controlador por condutas omissivas⁵¹, em função dos deveres estabelecidos no art. 116, parágrafo único, da LSA, as situações devem ser analisadas caso a caso, em razão das particularidades que precisam ser consideradas a fim de definir precisamente em que circunstâncias a omissão do controlador é repreensível, o que, a meu ver, deve pressupor uma atuação exigível.

158. A despeito da conclusão já esposada de que os Conselheiros agiram com desvio de finalidade ao terem aprovado a Aquisição Itaú por preço excessivo, deixando prevalecer a necessidade de viabilizar a saída ao Itaú, tal infração ao art. 154 da LSA não pressupõe, automaticamente, abuso de poder pelas Controladoras, em descumprimento ao disposto no art. 116, ainda que seja de esperar que haja uma correlação.

159. Muito embora a prova de interferência ou influência concreta do controlador possa ser de difícil produção (e daí a importância de reunir indícios), não se pode simplesmente presumir que, se os Conselheiros agiram com desvio de finalidade para viabilizar a saída do Itaú, sem que

⁵¹ v. PAS CVM nº 18/2010, j. 26.11.2013; e PAS CVM nº RJ2015/10677, j. 07.02.2017.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

a PUT fosse exercida (e, portanto, em benefício das Controladoras), necessariamente assim agiram a mando das Controladoras.

160. Pode ter sido assim, mas essa não foi sequer a tese acusatória, o que explica a ausência de elementos ou a reunião de indícios no sentido de que as Controladoras interferiram nas negociações.

161. Ao contrário, as Controladoras foram acusadas por não terem exercido seu poder de controle para interferir na decisão do CA da Gerdau e, em última análise, evitar o fechamento da Aquisição Itaú, mas quanto a isso entendo que não cabe responsabilização das Controladoras.

162. Entendo que o juízo de conveniência e oportunidade da realização da Aquisição Itaú cabia à administração da Companhia. Às Controladoras cabia respeitar a autonomia do CA da Gerdau, na medida em que o respectivo estatuto social atribuía ao CA (e não à assembleia geral) competência para aprovar investimentos de tal natureza. Assim, não lhes seria exigível atuação no sentido de incentivar ou de impedir a contratação da Aquisição Itaú, ainda que a referida operação lhes impactasse positivamente.

163. Mesmo reconhecendo que o controlador, usualmente, tem o poder de exercer influência sobre as atividades da controlada e orientar o funcionamento dos respectivos órgãos sociais por meios que transcendem as deliberações assembleares e, portanto, de que sua atuação não se limita às assembleias gerais⁵², a SEP, como visto, não optou por seguir essa linha de acusação, não tendo as Controladoras sido acusadas por qualquer influência que tenham exercido, mas justamente por não ter exercido tal influência, que no caso, à luz da alçada devida, era incabível.

164. Dito isso, concluo pela improcedência da acusação formulada contra as Controladoras, de exercício abusivo do poder de controle.

VIII. ART. 157, §4º – DEVER DE INFORMAR

165. Por fim, passo a enfrentar a imputação de responsabilidade aos DRIs por violação ao dever de informar.

⁵² v. PAS CVM nº RJ2012/1131, j. 26.05.2015; e PAS CVM nº 13/2014, j. 05.11.2019. Neste último, o Diretor Henrique Machado destacou, em linha com precedentes da CVM, que o exercício do poder de controle pode ocorrer, também, mediante mecanismos informais de comunicação mantidos entre o controlador e os administradores, por meio dos quais são transmitidas orientações que, por vezes, podem não coincidir com os interesses da companhia controlada, hipótese na qual resta caracterizado o abuso. No referido caso, embora o controlador não tivesse praticado qualquer ato formal, decidiu-se no sentido de que as circunstâncias em que foram realizadas as operações questionadas – consideradas prejudiciais à companhia controlada – foram suficientes para comprovar a sua influência, pois as operações foram realizadas tão somente para beneficiá-lo de modo particular.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

166. Como relatado, as Aquisições foram informadas ao mercado por meio do Fato Relevante, divulgado em 14.07.2015, seguido dos esclarecimentos prestados por meio do Comunicado ao Mercado, divulgado em 17.07.2015. Cabe destacar que, no dia seguinte à divulgação do Fato Relevante, houve a substituição do DRI da Companhia. André Pires foi o responsável pela divulgação do Fato Relevante, enquanto Harley Scardoelli foi o responsável pelo Comunicado ao Mercado. O primeiro foi acusado por descumprimento ao art. 157, §4º, da LSA c/c art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009 e ao art. 3º, §5º, da Instrução CVM nº 358/2002, e o segundo apenas pelo descumprimento ao referido art. 14.

167. O Fato Relevante divulgou a realização das Aquisições, “*como parte das ações necessárias para adequação da Gerdau ao cenário de grande competitividade, e avanço na simplificação de processos e da estrutura societária da Gerdau*”, visando à “*possível transformação [das Controladas], no futuro, em subsidiárias integrais e/ou à sua incorporação; a consolidar o recebimento de dividendos; e a proporcionar a maior facilidade de acesso ao mercado de capitais*”⁵³. Contudo, reportou as Aquisições de uma maneira global, sem individualizar as condições negociais avençadas e as partes envolvidas, e também omitiu o fato de que o valor pago na Aquisição Itaú foi afetado pela PUT.

168. Já o Comunicado ao Mercado foi divulgado com o propósito de modo a esclarecer questionamentos de agentes do mercado recebidos pela Gerdau, especialmente acerca da identidade das contrapartes da Gerdau nas Aquisições, e se reportava também a veiculações na mídia relativas às Aquisições.

169. No Comunicado ao Mercado, a Companhia reiterou que “sempre teve interesse em concentrar a participação em suas controladas operativas” (e cita nominalmente as Controladas), “embora não houvesse qualquer obrigação contratual de efetivar essas aquisições”. Nesse sentido, reconhecendo seu “objetivo de evitar interpretações indevidas” (e note-se que, não à toa, o mercado já estava especulando acerca de operações com partes relacionadas), informou que os acionistas vendedores das participações foram o Itaú e a Arcelor e que, por isso, as Aquisições não consistiram em operações com acionista controlador ou com partes relacionadas. Por fim, no que se referiu “ao momento e ao valor de negócio”, asseverou que:

“[D]ecorreram de oportunidades de mercado e, na percepção da administração, foram realizadas com preços adequados, levando-se em consideração: as avaliações econômicas, os instrumentos financeiros utilizados, os prazos de pagamento, a captura de valor através de um fluxo de caixa mais concentrado e a visão de longo prazo da Companhia.”⁵⁴

⁵³ Doc. SEI 0125083, fls. 21.

⁵⁴ Doc. SEI 0125083, fls. 26.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

170. Para a Acusação, o Comunicado ao Mercado apresentou informações inconsistentes e incompletas, pois afirmou que não se trataram de operações com partes relacionadas, omitindo qualquer informação sobre a PUT e induzindo o mercado a erro.

171. Exceto pelo argumento de que a Aquisição Itaú consistiu numa transação com partes relacionadas (o que já foi afastado neste Voto), concordo com a Acusação quando afirma que o Fato Relevante e o Comunicado ao Mercado revelaram informações insuficientes ao mercado, tendo intencionalmente omitido informações relevantes e úteis para os investidores.

172. Não me convence o argumento apresentado pela Defesa de que a relevância da informação repousava tão somente sobre o fato de que, mediante o pagamento do preço global informado, a Gerdau passaria a deter mais de 99% do capital social das Controladas, com possíveis alterações da estrutura societária da Companhia, impactos na forma de recebimento de dividendos e na facilidade de acesso ao mercado de capitais. Igualmente, não me convence o argumento de que era “absolutamente indiferente” a divulgação da identidade dos vendedores das Participações ou da discrepância entre os preços praticados para que os investidores avaliassem o impacto global das Aquisições para a Companhia.

173. Embora as Aquisições fizessem parte de uma estratégia comercial da Companhia, entendo que não foi dada a adequada transparência ao mercado a respeito, especialmente pela expressividade dos valores envolvidos nas referidas operações, frente à aquisição de participações minoritárias nas Controladas. Como já dito, o valor total pago nas Aquisições foi de aproximadamente R\$ 2 bilhões, o que representava, à época, o equivalente a aproximadamente 18% do valor de mercado da Companhia, por um aumento da participação da Companhia nas Controladas de 94% para 99%.

174. Dessa forma, para informar o mercado sobre as Aquisições, entendo que eram necessárias e relevantes informações adicionais, contendo um maior detalhamento das operações no Fato Relevante – ao menos contrapartes envolvidas e as condições de pagamento negociadas com cada uma delas, até porque o mercado de aço estava passando por uma crise naquela época, de modo que a preservação do caixa e a diminuição da alavancagem da Companhia eram elementos sensíveis para o mercado.

175. Note-se que na Proposta da Administração⁵⁵ para a AGO de 2016 da Companhia, foi informado que, embora a negociação com o Itaú e com a Arcelor tivessem apresentado discrepâncias relevantes, a avaliação e aprovação das Aquisições foi realizada pela administração sob uma perspectiva global, considerando como “justo” o preço pago pelo somatório dos valores

⁵⁵ Em atendimento ao Ofício nº 084/2016-CVM/SEP/GEA-4, a Companhia apresentou detalhamento das informações relativas às Aquisições.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

pagos pelas Participações e, ainda, levando em conta o momento oportuno para efetivar essas operações e as condições de pagamento avençadas.

176. Ainda que, para a Companhia, as Aquisições devessem ser analisadas em conjunto, não é razoável que essa seja justificativa para proceder à divulgação ao mercado como se fosse absolutamente irrelevante para os investidores compreender o racional econômico e estratégico existente por trás do dispêndio de tal magnitude em aquisições de participações minoritárias nas Controladas, quando a própria Gerdau já detinha 94% do capital social daquelas sociedades.

177. Como preceitua o art. 3º, §5º, da Instrução CVM nº 358/2002, a divulgação e a comunicação do fato que se reputa relevante deve ser feita de modo claro e preciso, o que entendo não foi observado por André Pires quando da elaboração do Fato Relevante, pois foram omitidas informações relevantes para que o público investidor pudesse assimilar e compreender as Aquisições e o contexto em que foram negociadas, sem que houvesse indução a erro, especialmente quanto ao preço das Aquisições.

178. Apesar de o Comunicado ao Mercado ter tido a pretensão de esclarecer questionamentos recebidos pela área de RI da Companhia, tal ato também não se prestou a suprir as falhas do Fato Relevante e munir o mercado das informações úteis à sua tomada de decisão de investimento, desinvestimento ou manutenção de sua participação. O referido comunicado foi, a meu ver, muito sucinto em seu conteúdo, tendo sido divulgado apenas com a finalidade de tentar afastar as especulações já então existentes quanto ao envolvimento de partes relacionadas ou do acionista controlador nas Aquisições e novamente foi enganoso, ao não mencionar a PUT.

179. Relevante esclarecer que, embora a troca de DRIs tenha ocorrido em 15.07.2015, Harley Scardoelli já trabalhava na Gerdau desde 1988 e que antes de assumir, cumulativamente, o cargo de DRI da Companhia atuava como seu “Diretor Corporativo, sendo responsável pelas áreas de Tesouraria, Financeiro e Planejamento”, conforme referido em Comunicado divulgado pela Companhia em 17.06.2015⁵⁶, o qual também já informava que, em razão da renúncia do DRI André Pires, a partir de 15.07.2015, Harley Scardorelli assumiria o cargo de DRI e que o processo de transição dos executivos ocorreria até lá.

180. Ainda que Harley Scardorelli tenha assumido o cargo de DRI apenas dois dias antes da divulgação do Comunicado ao Mercado, restou demonstrado que isso não o eximia de compreender a sensibilidade da informação transmitida ao mercado acerca das Aquisições e o que

⁵⁶ Conforme Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia em 17.06.2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

era necessário para assegurar a disseminação de informações claras, precisas, verdadeiras, completas e consistentes, conforme exigido pela regulamentação aplicável⁵⁷.

181. A propósito, ressalte-se que, em 10.07.2015, o próprio Harley Scardoelli já é quem envia informações aos Conselheiros a respeito das Aquisições, como consta de e-mail acostado aos autos do PAS, com o seguinte teor:

“De: Harley Lorentz Scardoelli
Enviada em: Friday, 10 de July de 2015 00:50
Para: Andre Bier Gerdau Johannpeter; Claudio Johannpeter; Richard Chagas Gerdau Johannpeter, Affonso Celso Pastore; Oscar de Paula Bernardes Neto; Expedito Luz
Assunto: Aquisição participações minoritárias nas empresas operativas
Caros Conselheiros,
Estamos próximos de concluir a operação de aquisição de participação de minoritários nas empresas operativas. Anexo envio material de apoio e informações relevantes sobre a operação, que servem de subsídio à tomada de decisão deste Conselho. A intenção é finalizar a operação nos primeiros dias da próxima semana, quando o departamento jurídico deverá ultimar a minuta da Ata do CA e enviá-la diretamente aos Conselheiros.
Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários.
Atenciosamente,
Harley Scardoelli
Diretor Corporativo Financeiro e de Planejamento Gerdau S.A.”⁵⁸

182. Diante dos questionamentos do mercado acerca do conteúdo do Fato Relevante, era de se esperar que Harley Scardoelli estivesse em plenas condições de avaliar o que deveria ter sido divulgado ao mercado para, então, prestar esclarecimentos adicionais. E mais, ainda que não tivesse tido qualquer envolvimento nas Aquisições, compõe o escopo das funções do DRI perquirir a respeito de informações que mereçam, à luz da regulamentação aplicável, ser divulgadas.

183. É de se questionar, inclusive, dada a relevância das informações prestadas no Comunicado ao Mercado, se não deveriam ter sido, também, objeto de fato relevante, mas isso não foi objeto da acusação, o que se refletirá na penalidade.

184. Por fim, resta enfrentar o argumento de defesa de André Pires, no sentido de que houve excesso acusatório. Sustentou que o art. 157, §4º, da LSA não se aplicaria a este caso, pois em nenhum momento se alegou que o Acusado teria deixado de comunicar o Fato Relevante em

⁵⁷ Destaco, nesse sentido, o papel fundamental do DRI no desenvolvimento e funcionamento do mercado: “o diretor de relações com investidores desempenha função crucial para o eficiente funcionamento do mercado, porque, além dos deveres impostos aos administradores em geral, cumpre-lhe, nos termos da legislação vigente, o cumprimento de deveres específicos, que, em última análise, procuram assegurar a ampla e tempestiva disseminação, junto ao público investidor, de informações verdadeiras, completas e consistentes sobre os negócios da companhia aberta”. (trecho do voto do ex-Diretor Pablo Renteria, no PAS CVM nº08/2009, j. 28.04.2015)

⁵⁸ Doc. SEI nº 0125090, fls. 516.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

questão ou que o teria feito intempestivamente, tendo a Acusação sustentado apenas que foram omitidas outras informações que, a seu ver, deveriam ter sido prestadas. Ou seja, para o acusado, o art. 14 da ICVM nº 480/2009 já seria suficiente para embasar a sua eventual responsabilidade, uma vez que exige a divulgação de informações verdadeiras, completas e consistentes.

185. Contudo, tal interpretação literal do art. 157, §4º, não merece prosperar, sob pena de esvaziar seu conteúdo de sentido. Quando se questiona divulgação incompleta ou omissão de informação, claramente se está indicando que não foi divulgada informação que se reputa relevante.

186. Entendo, portanto, ter restado caracterizada a responsabilidade dos DRIs por infração aos respectivos dispositivos indicados pela SEP, em descumprimento do dever de informar.

IX. CONCLUSÃO E PENALIDADES

187. Por todo o exposto, entendo que restou comprovada a responsabilidade de todos os Conselheiros da Companhia, por terem atuado com desvio de finalidade, em infração ao art. 154 da LSA, bem como dos DRIs, por falha no dever de informar.

188. Os descumprimentos do disposto no art. 154 da LSA, no art. 3º, §5º, da Instrução CVM nº 358/2002 e no art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009 configuram infrações de natureza grave, nos termos da então vigente Instrução CVM nº 491, de 22.02.2011, o que foi mantido pela Instrução que a revogou (Instrução CVM nº 607, de 17.06.2019, Anexo 64). Por outro lado, para fins de dosimetria, levo em consideração, como circunstância atenuante, os bons antecedentes de todos dos referidos acusados e o fato de que, não obstante a excessiva onerosidade, havia também legítimos interesses estratégicos da Companhia na aquisição das Participações Itaú.

189. Dito isto, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385, de 07.12.1976 (com redação anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13.11.2017), voto:

- i. pela condenação de **André Pires**, na qualidade de DRI da Gerdau, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por infração ao disposto no art. 157, §4º, da LSA, c/c o art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009 e no art. 3º, §5º, da Instrução CVM nº 358/2002;
- ii. pela condenação de **Harley Scardoelli**, na qualidade de DRI da Gerdau, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração ao disposto no art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- iii. pela condenação de **Claudio Gerdau, André Gerdau, Richard Gerdau, Oscar Bernardes, Affonso Pastore e Expedito Luz**, na qualidade de membros do CA da Gerdau, à penalidade de multa pecuniária individual, no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) cada um, por infração ao art. 154 da LSA;
- iv. pela absolvição de **Claudio Gerdau, André Gerdau e Richard Gerdau**, na qualidade de membros do CA da Gerdau, pela alegada infração ao art. 156 da LSA;
- v. pela absolvição de **Claudio Gerdau, André Gerdau, Richard Gerdau, Oscar Bernardes, Affonso Pastore e Expedito Luz**, na qualidade de membros do CA da Gerdau, pela alegada infração ao disposto no art. 245 da LSA; e
- vi. pela absolvição da **INDAC e da Metalúrgica Gerdau**, na qualidade de acionistas controladoras da Gerdau, pela alegada infração ao art. 116, parágrafo único, da LSA.

É como voto.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2019.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEI Nº 19957.004309/2016-73

Reg. Col. nº 0463/2016

Acusados: André Pires de Oliveira Dias
Harley Lorentz Scardoelli
Claudio Gerdau Johannpeter
André Bier Gerdau Johannpeter
Richard Chagas Gerdau Johannpeter
Expedito Luz
Affonso Celso Pastore
Oscar de Paula Bernardes Neto
INDAC – Indústria Administração e Comércio Ltda.
Metalúrgica Gerdau S.A.

Assunto: Apurar eventuais irregularidades em operação de aquisição de participações minoritárias em empresas controladas pela Gerdau S.A., em suposto descumprimento dos arts. 116, parágrafo único, 154 c/c 245, 156 e 157, §4º, todos da Lei nº 6.404/1976, e arts. 3º e 5º da Instrução CVM nº 358/2002.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente e demais Diretores,

1. Em que se pese o profundo trabalho de análise do conjunto fático-probatório e as razões lançadas no voto¹ da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, acompanho a divergência instaurada na manifestação de voto do Diretor Carlos Rebello.

2. No presente caso, segundo a Acusação, ao aprovarem a aquisição das Participações Itaú por valor muito superior àquele pago pelas Participações Arcelor, os membros do conselho de administração não teriam atuado buscando o melhor interesse da Companhia, mas pautados pela existência de obrigação prévia entre o Itaú e a INDAC, garantida, ainda, pela Metalúrgica Gerdau, a qual envolvia justamente o exercício de Opção de Venda das referidas participações.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula referenciados na presente manifestação de voto e que não estiverem nele definidos têm a significação que lhes foi atribuído no voto da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Assim, sustenta a área técnica que a aprovação da Aquisição Itaú teria por objetivo desonerar as suas Controladoras da obrigação assumida perante o Itaú. A Acusação propõe, portanto, a revisão do mérito da decisão negocial tomada pelo conselho de administração da Gerdau por entender que aquela teria sido adotada em contrariedade a diversos dispositivos da lei societária.

3. Ocorre que, após terem sido afastadas as acusações de favorecimento indevido à sociedade controladora (art. 245²), atuação em conflito de interesses (art. 156³) e exercício abusivo do poder de controle (art. 116, p.u.⁴), entendo ter remanescido controvérsia exclusivamente quanto ao erro ou ao acerto da decisão negocial. Tal controvérsia, entretanto, é estranha à verificação do desvio de finalidade de que trata o art. 154 da Lei nº 6.404/76, sendo necessário receber com distanciamento o longo escrutínio realizado sobre a correção do preço praticado na operação.

4. Com efeito, o mencionado art. 154, ao estabelecer que os administradores devem exercer suas atribuições para lograr os fins e no interesse da companhia, explícita de forma aparentemente singela um dos princípios fundamentais da lei societária, a prevalência do interesse da companhia. Em relação à atuação dos administradores, o dispositivo consagra, nesses termos, o interesse da companhia como pressuposto e, concomitantemente, um orientador de suas atividades⁵.

5. Tal princípio fundamental evidentemente não poderia passar ao largo das atividades de supervisão desta Comissão de Valores Mobiliários. Ao contrário, nos termos do artigo 11⁶ da

² Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo.

³ Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.

⁴ Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: (...)

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.

⁵ “O interesse social e o cumprimento do objeto social limitam a liberdade e a discricionariedade do administrador, à medida que todos os atos, decisões e escolhas do administrador devem estar voltados primordialmente para o atendimento do objeto e do interesse social, embora deva ainda observar a função social da empresa e as exigências do bem público” (CAMPOS, Luiz Antonio Sampaio. Deveres e Responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. *Direito das Companhias*. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 1111-1112).

⁶ Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (Redação dada pela Lei nº 13.506, de 2017) Manifestação de Voto DHM (0894367) SEI 19957.004309/2016-73 / pg. 76



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Lei nº 6.385/76 e do art. 1º, I, “c”, da Instrução CVM nº 491/2011⁷, compete-lhe a fiscalização dos atos dos administradores, caracterizando o desvio de conduta como infração de natureza grave.

6. Nesse mister, é necessário ter presente que a revisão do mérito de decisões negociais é tarefa especialmente árdua para o regulador do mercado de capitais, seja pela dificuldade de obter e avaliar todas as informações e circunstâncias presentes à época da decisão, seja pela absoluta subjetividade de que se reveste o juízo, em cada caso, quanto à aderência de determinada decisão ao interesse da companhia. Mais do que isso, deve o regulador conter-se e abster-se da tentativa de substituir os administradores e realizar, *a posteriori*, julgamento de mérito sobre qual teria sido a melhor decisão para a companhia.

7. Em outras palavras, como sustenta o Diretor Carlos Rebello, “*a avaliação deve ser pautada por um juízo de racionalidade – e não de razoabilidade –, de modo a verificar se os fundamentos expostos pelos administradores para a decisão tomada conseguem justificar, racionalmente, as condições pactuadas. Nesse sentido, o juízo de racionalidade acerca das condições contratadas no âmbito das Aquisições não deve ser conduzido abstratamente, mas sim a partir das circunstâncias concretas e das particularidades relacionadas à negociação em análise*”.

8. Entendo, conforme jurisprudência desta Comissão⁸, que ao avaliar decisões negociais tomadas por administradores de companhias abertas, deve ser adotado o padrão de revisão da *business judgment rule* segundo a qual, ante a inexistência de pressupostos que demonstrem má-fé, fraude, interesse ou conflito do administrador, e ante a inexistência de qualquer falha procedimental no respectivo processo decisório, as decisões de um administrador devem, em princípio, ser consideradas regulares⁹

9. Isto é, tais decisões gozam da presunção de que foram tomadas buscando o melhor interesse social.

⁷ Art. 1º Consideram-se infração grave, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos incisos III a VIII do art. 11 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, as seguintes hipóteses:

I – descumprimento dos seguintes comandos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: (...)

c) art. 154, caput e §§ 1º e 2º;

⁸ PAS CVM nº 03/02, Rel. Norma Jonssen Parente, j. em 12.02.2004; PAS CVM nº RJ2008/9574, Rel. Ana Novaes, j. em 27.11.2012; e PAS CVM nº RJ2005/1443, Rel. Pedro Oliva Marcilio, j. em 10.05.2006.

⁹ Na mesma linha, é o voto do Diretor Gustavo Gonzalez no PAS CVM nº RJ2013/11703, de 05 de setembro de 2017, segundo o qual: “*Ao se aplicar a business judgment rule, restringe-se a esfera de atuação do julgador, a quem caberá analisar tão somente se o comportamento do administrador ao longo do processo decisório demonstra que ele atuou de maneira informada, refletida e desinteressada, ainda que, posteriormente, considerando os resultados obtidos, venha a se verificar que a decisão tomada não foi a mais benéfica para a companhia.*”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

10. Sobre o tema, assim me manifestei no julgamento do PAS CVM nº RJ2014/6517, de 25 de junho de 2019:

Tipicamente, a diligência de determinada conduta é examinada sob o aspecto negocial ou fiscalizatório. O primeiro refere-se às decisões tipicamente negociais em face das quais impõe-se o teste da *business judgment rule*. O segundo abarca dimensão voltada à supervisão das mais variadas atividades da companhia, no âmbito da qual a diligência é aferida a partir da verificação da razoabilidade e adequação dos esforços despendidos pelo administrador no desempenho de sua função.

11. No caso dos autos, tenho que a defesa logrou demonstrar a regularidade do comportamento dos administradores no processo decisório, que atuaram de forma desinteressada, refletida e informada. A operação em questão foi aprovada por unanimidade, com o voto afirmativo de 3 membros formalmente independentes, sem relação com os acionistas controladores da Gerdau S.A. Aliás, não foram apontadas razões para concluir que teriam incentivos para agir em benefício das Controladoras e em detrimento da Companhia¹⁰. Ao contrário, como assevera a defesa, além de sua independência, eles possuíam participações acionárias na Gerdau, a demonstrar sua exposição aos resultados da Companhia e, em consequência, o alinhamento de seus interesses econômicos.

12. Também o procedimento de deliberação e análise das Aquisições demonstra o cuidado com que o tema foi tratado pelo conselho de administração e, portanto, sugere que seus membros atuaram buscando o melhor interesse da Companhia. Nesse sentido, restou demonstrado que a aprovação da operação demandou inúmeras reuniões e discussões sobre suas alternativas e implicações.

13. A esse respeito, a defesa se reporta i) à cronologia dos eventos que culminaram na aprovação¹¹ da Aquisição Itaú, com referência a pelo menos 3 ocasiões de discussão com o conselho (25/06, 29/06 e na própria RCA de 13/07) e ii) às evidências de que o assunto vinha sendo periodicamente reportado e acompanhado pelos membros do conselho. Ainda mais

¹⁰ “É perfeitamente possível e, mesmo recomendável, que ele [juiz] exija mais provas para se convencer de que os administradores quebraram seus deveres fiduciários em determinadas hipóteses em que a presunção de que eles não o fariam é mais forte” (BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. A administração de Companhias e a Business Judgment Rule. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 188). Também nesse sentido convém destacar manifestação de voto apresentada pelo então Diretor Marcos Pinto no julgamento do PAS RJ2007/4476, realizado em 12.3.2008. Naquela oportunidade, ao avaliar a acusação de infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/76, o Diretor destacou que os elementos constantes dos autos não seriam suficientes para levantar dúvida acerca da intenção da administradora acusada e acrescentou que “a *business judgement rule* (...) também vale para os administradores independentes ou eleitos pelos acionistas minoritários. Digo mais: ela vale com mais força para eles”.

¹¹ Fls. 217/220.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

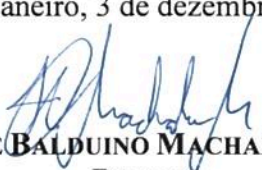
importante, é o fato de que o aspecto controvertido da operação, a aquisição das Participações Itaú por valor muito superior àquele pago pelas Participações Arcelor, foi especificamente referido em apresentações realizadas ao conselho de administração¹².

14. Por essas razões, que adiciono ao voto do Diretor Carlos Rebello, divirjo da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro e também **voto** pela **absolvição** de Claudio Gerdau, André Gerdau, Richard Gerdau, Oscar Bernardes, Affonso Pastore e Expedito Luz da acusação de infração ao disposto no art. 154 da Lei nº 6.404/76.

15. Quanto às demais acusações, acompanho as conclusões expostas pela Relatora, bem como as penalidades por ela sugeridas em relação a André Pires e Harley Scardoelli.

É como voto.

Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 2019.


HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEI Nº 19957.004309/2016-73

Reg. Col. nº 0463/2016

Acusados: André Pires de Oliveira Dias
Harley Lorentz Scardoelli
Claudio Gerdau Johannpeter
André Bier Gerdau Johannpeter
Richard Chagas Gerdau Johannpeter
Expedito Luz
Affonso Celso Pastore
Oscar de Paula Bernardes Neto
INDAC – Indústria Administração e Comércio Ltda.
Metalúrgica Gerdau S.A.

Assunto: Apurar eventuais irregularidades em operação de aquisição de participações minoritárias em empresas controladas pela Gerdau S.A., em suposto descumprimento dos arts. 116, parágrafo único, 154 c/c 245, 156 e 157, §4º, todos da Lei nº 6.404/1976, e arts. 3º e 5º da Instrução CVM nº 358/2002.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Gostaria de tecer breves considerações a respeito de alguns pontos tratados ao longo do bem fundamentado voto da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro^[1].
2. Nada obstante, esclareço, desde logo, que a minha divergência diz respeito tão somente às conclusões da Diretora Relatora no tocante à acusação de desvio de poder formulada em face dos membros do conselho de administração da Gerdau que tomaram parte na decisão de aprovação das Aquisições.
3. A esses acusados imputou-se o descumprimento ao disposto no art. 154 da Lei nº 6.404/76, segundo o qual *“o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da*

empresa”.

4. Na visão da SEP, ao aprovarem a aquisição das Participações Itaú por valor muito superior àquele pago pelas Participações Arcelor, os membros do conselho de administração não teriam atuado buscando o melhor interesse da Companhia, mas pautados pela existência de obrigação prévia entre o Itaú e a INDAC, garantida, ainda, pela Metalúrgica Gerdau, a qual envolvia justamente o exercício de Opção de Venda das referidas participações. Assim, sustenta a área técnica que a aprovação da Aquisição Itaú teria por objetivo desonerar as suas Controladoras da obrigação assumida perante o Itaú.
5. Estamos, portanto, diante da avaliação de decisão negocial tomada, em votação unânime, pelo conselho de administração da Gerdau, composto em parte por administradores reconhecidamente independentes e cujo procedimento de deliberação não foi objeto de contestação pela SEP.
6. Tampouco restou demonstrada qualquer influência das Controladoras no processo decisório do conselho de administração em relação às Aquisições. Pelo contrário, a conduta irregular atribuída às Controladoras é justamente de terem se omitido diante da aprovação de negócio que lhes beneficiava especificamente, acusação essa expressamente afastada pela Diretora Relatora por entender que não haveria, neste caso, qualquer dever de agir da acionista controladora a exigir a sua interferência na contratação.
7. Assim, ainda que não haja vinculação necessária entre as infrações aos arts. 116 e 154 da Lei nº 6.404/76, convém ter em mente que estamos examinando a conduta de membros do conselho de administração, entre os quais Conselheiros Sem Vínculo, por terem aprovado as Aquisições buscando, supostamente, não o melhor interesse da Companhia, mas sim o favorecimento das Controladoras, sem que, no entanto, essas últimas tenham exercido influência para que os administradores assim agissem.
8. Dito de outro modo, a decisão ora em análise foi tomada em parte por conselheiros em relação aos quais não restou configurado o conflito de interesses previsto no art. 156 da Lei nº 6.404/76, haja vista a ausência de benefício direto com a operação, e em parte por conselheiros sem qualquer vínculo com os acionistas controladores e, por conseguinte, sem qualquer interesse aparente em favorece-los em detrimento do interesse social^[2].
9. À luz dessas circunstâncias, impõe-se a reunião de conjunto probatório ainda mais robusto para afastar a presunção de que tais administradores agiram de boa fé e no interesse da Companhia. Há, portanto, certas cautelas a serem observadas no exame da decisão tomada pelos Conselheiros, de modo a evitar a intervenção indesejada na gestão dos negócios sociais.
10. Observadas essas considerações e tomando por base a acusação formulada pela área técnica, entendo que a primeira avaliação a ser conduzida diz respeito à aderência das Aquisições ao interesse da Companhia – e neste primeiro momento, refiro-me tanto à Aquisição Arcelor quanto à Aquisição Itaú.
11. A esse respeito, restou perfeitamente delineado, a partir dos elementos levantados no curso do processo, o objetivo de longo prazo da Gerdau de consolidar as suas participações em sociedades controladas, no contexto de reestruturação societária e organizacional idealizada muito antes da celebração da operação ora em análise.
12. Nesse sentido, há que se destacar apresentação realizada por consultoria

contratada pela Companhia ainda em julho de 2005, a ilustrar a estratégia de longo prazo traçada pela Gerdau, que envolvia a consolidação de sua posição nas Américas, seja aumentando a sua exposição em países em que já mantinha posição relevante, seja iniciando atividades em novos países, objetivo para o qual se vislumbrou um horizonte de dez anos (2015).

13. Para assegurar o atingimento de tal objetivo, a visão estratégica da Companhia deveria vir acompanhada de alterações, a médio e longo prazo, em seu modelo de governança, buscando a centralização do processo decisório, o que deveria refletir igualmente na estrutura societária da Gerdau a partir da consolidação de participações em controladas para, eventualmente, sua posterior incorporação e transformação em subsidiárias integrais. Foi justamente esse o racional divulgado como justificativa para as Aquisições.
14. O plano estratégico da Companhia se confirma não somente pelo histórico de aquisições e permutas de participações minoritárias celebradas ao longo dos anos (2005 a 2015)[\[3\]](#), como também pela constatação de que ao menos parte das participações adquiridas – Gerdau Aço Especiais e Gerdau América Latina – resultou na posterior incorporação das sociedades em 2017, circunstância que deverá ser levada em consideração, inclusive, quando da avaliação do racional econômico da operação.
15. Assim, em 2015, em momento anterior à celebração da operação, a Gerdau mantinha participação de 95,15% no capital social de suas Controladas. Razoável que, no curso de seu processo de reorganização, a Companhia voltasse seus esforços de negociação à Arcelor e ao Itaú que, em conjunto, mantinham 85% das posições minoritárias dessas sociedades e, por conseguinte, assegurariam à Gerdau a consolidação de sua participação em 99,25%.
16. Nota-se, portanto, que o objetivo de longo prazo da Companhia envolvendo a reestruturação das sociedades operacionais sob o seu controle pressuporia, de uma forma ou de outra, a aquisição das participações detidas tanto pelo Itaú quanto pela Arcelor. Não à toa, verificou-se que a Gerdau já vinha negociando com a Arcelor muito antes da aprovação das Aquisições[\[4\]](#).
17. Não resta dúvida, portanto, quanto à aderência das Aquisições à estratégia de longo prazo da Companhia. Na realidade, me parece que, em seu voto, a própria Relatora reconheceu que a operação estava em consonância com os interesses da Gerdau, não sendo essa, portanto, a minha divergência em relação ao bem lançado voto da Diretora.
18. Superada esta questão, entendo que há uma segunda avaliação a ser conduzida, a qual diz respeito às condições de contratação. Ao contrário do exame anterior, neste ponto, cumpre avaliar especificamente as condições pactuadas no âmbito da Aquisição Itaú, as quais foram objeto de questionamento pela SEP.
19. A meu ver, essa segunda avaliação se justifica, pois, o simples fato de determinada operação ser do interesse da companhia não significa, ressalvadas situações excepcionais, que ela deverá ser celebrada a qualquer custo. Pelo contrário, o que se espera do administrador é a maximização dos lucros da companhia, de modo que, em eventual contratação, ele deverá envidar esforços para assegurar as melhores condições de pagamento.
20. Entendo, no entanto, que tal avaliação deve ser pautada por um juízo de racionalidade – e não de razoabilidade –, de modo a verificar se os

fundamentos expostos pelos administradores para a decisão tomada conseguem justificar, racionalmente, as condições pactuadas[5]. Nesse sentido, o juízo de racionalidade acerca das condições contratadas no âmbito das Aquisições não deve ser conduzido abstratamente, mas sim a partir das circunstâncias concretas e das particularidades relacionadas à negociação em análise.

21. Especialmente quando estamos avaliando as condições de uma contratação, notadamente o seu preço, o juízo de razoabilidade é especialmente preocupante, haja vista as inúmeras circunstâncias a serem consideradas em uma negociação, a saber, a premência de qualquer das partes em contratar, a forma de pagamento do valor ajustado, a disponibilidade de caixa do comprador, eventuais impactos fiscais da operação, a possibilidade de negociar com outra contraparte e etc.
22. No presente caso, havia circunstância relevante a ser considerada nas negociações conduzidas entre Itaú e Gerdau: a existência de Opção de Venda em favor daquele, que lhe assegurava o direito de exigir da INDAC a aquisição das participações por ele detidas nas Controladas pelo preço de exercício, equivalente a R\$ 1.691.141.000,45 ao tempo da aprovação da operação.
23. Destaco, desde logo, que, naquele momento, qualquer que fosse a contraparte da Opção de Venda, ainda assim, o preço de exercício representaria o principal parâmetro para a negociação de eventual aquisição das Participações Itaú. O fato de a contraparte ser a INDAC não pode ser considerado, portanto, como fator determinante da referência de preço da negociação.
24. Reconheço, então, que a existência da Opção de Venda influenciou as condições pactuadas na Aquisição Itaú. Discordo, no entanto, da conclusão da Diretora quando afirma que *“o preço de exercício da PUT não foi apenas um balizador, mas, implicitamente, é o que revela o próprio racional da operação: viabilizar a reversão do aporte do Itaú, saída a que esse tinha direito em decorrência da PUT, mas não oponível à Gerdau”*.
25. Não consigo, a partir do reconhecimento da influência da Opção de Venda na negociação da Aquisição Itaú, concluir, automaticamente, que o pagamento de sobrepreço ao Itaú teria sido aprovado pelo conselho de administração com o objetivo de, ao proporcionar-lhe o mesmo retorno assegurado pela PUT, evitar que a opção fosse exercida em face de suas Controladoras.
26. Em outras palavras, os elementos constantes dos autos não me permitem concluir que os Conselheiros teriam atuado para favorecer as Controladoras em detrimento do interesse da Companhia, se deixando influenciar pela suposta iminência do exercício da PUT em desfavor de suas Controladoras e, por essa razão, buscado deliberadamente acomodar a *“operação de saída do investimento”* que o Itaú tinha assegurada em razão da Opção de Venda, conforme sustentado pela Relatora.
27. A meu ver, os acusados conseguiram demonstrar ao longo de suas razões de defesa e a partir dos elementos de prova acostados aos autos que as condições pactuadas naquela contratação seguiram um racional econômico.
28. Como visto, em 2015, na esteira do plano estratégico de consolidação das participações detidas pela Gerdau nas controladas operacionais, a administração concentrou esforços em adquirir as posições detidas pela Arcelor e pelo Itaú, que totalizavam, à época, 85% das participações

minoritárias nas Controladas.

29. Inclusive, por ocasião da aprovação das Aquisições, foi apresentada ao conselho de administração uma única operação voltada à aquisição de participação equivalente a 4,09% do capital social das Controladas, a qual envolvia, no entanto, a negociação com dois acionistas distintos, com interesses também diversos.
30. De um lado, temos a Arcelor que negociou a alienação de sua participação nas Controladas pelo montante de R\$ 294.980 milhões, sendo a maior parte desse valor liquidada mediante a transferência de 30.000.000 ações preferenciais de emissão da Gerdau mantidas em tesouraria – somente 30,23% do preço foi pago à vista. Nota-se, portanto, que a Arcelor trocou sua posição nas Controladas por participações mais líquidas.
31. Por sua vez, ao negociar a aquisição das Participações Itaú, a Gerdau levou em consideração o preço de exercício da Opção de Venda contratado com a INDAC, tal como o faria qualquer outra contraparte que viesse a contratar com o Itaú. Como já exposto, não há dúvida de que, naquele momento, essa era a principal baliza de preço em qualquer negociação envolvendo as Aquisições Itaú. E, como dito, sob a ótica da Companhia, a circunstância negocial relativa à aquisição das Participações Itaú seria exatamente a mesma ainda que a Opção de Venda tivesse sido contratada com outra pessoa que não a INDAC.
32. A partir disso, foram ajustadas as condições do negócio.
33. Em contraposição ao “aparente sobrepreço” pago pelas Participações Itaú, a Gerdau conseguiu negociar com o Itaú instrumento de pagamento alternativo: a estruturação de FIDC ao qual seriam cedidos direitos creditórios decorrentes de ações judiciais movidas pela Companhia em face da Eletrobrás e da União. Além de conferir liquidez a ativo contingente e representar alternativa ao desembolso de caixa pela Gerdau, verificou-se que o valor ajustado com o Itaú foi muito superior àquele da segunda melhor proposta formulada para esse ativo – uma diferença de R\$ 317 milhões.
34. Essa seria a parcela mais relevante do preço a ser pago pela Companhia, representativa de, aproximadamente, 47,42% do valor ajustado para a Aquisição Itaú. Negociou-se, ainda, que parcela relevante do valor (R\$ 638 milhões), equivalente à 37,72%, seria liquidada a prazo, mediante amortizações anuais^[6]. Somente uma pequena parte do montante ajustado com o Itaú envolveria uma saída de caixa para a Companhia (R\$ 250 milhões – 14,78%).
35. Para além dessas condições de pagamento, havia, ainda, outro ganho importante, decorrente do aproveitamento fiscal do ágio pago pela Companhia na Aquisição Itaú em futuras incorporações das Controladas pela Gerdau, o qual estaria estimado, segundo informações prestadas pelos acusados, em R\$ 390 milhões. Tal vantagem se materializou ao menos em relação a duas das Controladas, as quais, ao final de 2017, foram incorporadas pela Companhia, com aproveitamento fiscal das parcelas de ágio associadas a tais sociedades.
36. Ressalte-se que a existência de ágio por rentabilidade futura foi atestada em laudos de avaliação elaborados para cada uma das Controladas, com data base de 14.7.2015, em cumprimento à exigência da Lei nº 12.973/14^[7].
37. Ainda que, em um exercício teórico, se admitisse cenário totalmente distinto, em que a Gerdau decidisse não negociar as Participações Itaú naquele

momento, a PUT fosse exercida em desfavor da INDAC e essa última tivesse interesse em aliená-las diretamente à Companhia, inclusive pelas mesmas condições de pagamento – o que já pressupõe a superação de uma série de premissas –, ainda assim, a Gerdau deixaria de aproveitar importante vantagem decorrente da operação: justamente o ágio a ser reconhecido futuramente em eventual incorporação das Controladas.

38. Isso porque, segundo as disposições da Lei nº 12.973/2014^[8], notadamente os seus arts. 22 e 25, somente poderá ser excluído para fins de apuração do lucro real o ágio decorrente da aquisição de participação societária celebrada entre partes não dependentes, o que não abarcaria a hipótese em que exista relação de controle entre o adquirente e o alienante (inciso II, art. 25).
39. Frente a todas essas considerações, entendo ter restado demonstrada a racionalidade da decisão do conselho de administração de aprovar as Aquisições, inclusive no que concerne à aceitação do “sobreprego” pago pelas Participações Itaú.
40. Por fim, reitero o cuidado que se impõe na revisão de decisões negociais, não somente em reconhecimento às limitações do julgador em matéria de gestão social, como também em razão dos efeitos negativos que podem decorrer da imposição de um regime de responsabilização especialmente gravoso ao administrador que, de boa fé e agindo no interesse social, comete erros^[9].
41. Toda a lógica que orientou a jurisprudência norte americana a respeito dos padrões de revisão a serem adotados no exame da conduta dos administradores – fonte importante de orientação em discussões sobre o tema – busca prestigiar a discricionariedade dos administradores que, atuando nos limites da lei e do estatuto social, assumem riscos em busca do melhor interesse social e, ao fazê-lo, estão, inclusive, sujeitos às incertezas do negócio.
42. Isso não significa que decisões equivocadas permaneçam imunes a consequências. A bem verdade, as decisões tomadas no curso da gestão social são avaliadas pelo mercado e repercutem tanto na esfera do administrador, que carrega, profissionalmente, os êxitos e insucessos de sua atuação, quanto na esfera da companhia, cujas ações são cotadas em reflexo à avaliação dos investidores acerca de sua perspectiva de rentabilidade.
43. Por todo o exposto, divirjo da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro e **voto** pela **absolvição** de Claudio Gerdau, André Gerdau, Richard Gerdau, Oscar Bernardes, Affonso Pastore e Expedito Luz da acusação de infração ao disposto no art. 154 da Lei nº 6.404/76.
44. Quanto às demais acusações, acompanho integralmente as conclusões expostas pela Relatora, bem como as penalidades por ela sugeridas em relação a André Pires e Harley Scardoelli.

É como voto.

Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Diretor

[1] Os termos iniciados em letra maiúscula referenciados na presente manifestação de voto e que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no voto da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro.

[2] Pelo contrário, segundo informações disponibilizadas pela defesa dos Conselheiros Sem Vínculo em sede de memoriais, à época dos fatos, os acusados possuíam participações acionárias na Gerdau, o que reforçaria o seu alinhamento com os interesses da Companhia. Nesse sentido, os referidos conselheiros detinham as seguintes participações por ocasião da aprovação das Aquisições (13.7.2015): (i) Affonso Pastore: 20.948 PN (GGBR4), equivalente a R\$ 147.000,00; (ii) Expedito Luz: 18.783 PN (GGBR4), equivalente a R\$ 132.000,00; e (iii) Oscar Bernardes: 91.146 PN (GGBR4), equivalente a R\$ 614.000,00; e 426 ON (GGBR3), equivalente a R\$ 2.000,00. O valor das participações foi informado aproximadamente e considera a cotação das ações em 13.7.2015.

[3] Segundo informações constantes do Anexo II da defesa apresentada por Affonso Pastore, Expedito Luz e Oscar de Paula, de 2005 a 2009, a Companhia realizou permutas que lhe asseguraram um acréscimo de participação de 0,72% nas sociedades operacionais (no valor total de R\$ 269.999 mil), bem como aquisições de participações minoritárias no período de 2005 a 2008 equivalentes a 3,96% do capital social (no valor de R\$ 1.738.736 mil). Também foram realizados aumentos de capital nestas sociedades representativos de 1,44% de seu capital social (no valor de R\$ 324.105 mil).

[4] Conforme narrado pelos acusados, as negociações com a Arcelor a respeito da aquisição de suas participações nas sociedades sob o controle da Gerdau se iniciaram ainda em 2011, tendo sido interrompidas em 2012 e retomadas em dezembro de 2014, quando a Companhia passou a negociar também com o Itaú.

[5] *"The business judgment rule consists of four conditions, and a special standard of review that is applicable, if the four conditions are satisfied (...) then the substance or quality of the director's or officer's decision will be reviewed, not under the basic standard of conduct to determine whether the decision was prudent or reasonable, but only under a much limited standard. (...) A few courts have stated that the standard is whether the director or officer acted in good faith.(...) Even courts that seem to use the term 'good faith' in a relatively subjective way nevertheless almost always review the quality of decisions under the guise of a rule that the irrationality of a decision shows bad faith. (...) Accordingly, the prevalent formulation of the standard of review under the business judgment rule, if the four conditions to that rule have been satisfied, is that the decision must be rational. (...) An obvious example of a decision that fails to satisfy the rationality standard is a decision that cannot be coherently explained. (...) Under this standard, a director or officer will not be liable for a decision that resulted in a loss to the corporation, even if the decision is unreasonable, as long as the conditions of the business-judgment rule have been met and the decision is rational"* (EISENBERG, Melvin Aron. The divergence of Standards of Conduct and Standards of Review in Corporate Law. Fordham Law Review, vol. 62, 1993, pp. 441-443)

[6] Segundo condições apresentadas ao conselho de administração, foram ajustadas as seguintes amortizações: (i) 2016 – R\$ 90 milhões; (ii) 2017 – R\$ 170 milhões; (iii) 2019 – R\$ 110 milhões; (iv) 2021 – R\$ 110 milhões; e (vi) 2022 – R\$ 120 milhões.

[7] Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido

deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em: I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os incisos I e II do caput. § 3º O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13º (décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação.

[8] A Lei nº 12.973/2014 equiparou o conceito fiscal de ágio ao conceito contábil e criou novas regras para a sua amortização da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

[9] Nesse sentido, convém destacar o seguinte trecho dos comentários de Luiz Antonio de Sampaio na obra *"Direito das Companhias"*, coordenada pelos autores do anteprojeto de lei que resultou na edição da Lei nº 6.404/76, Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira: *"A companhia e seus acionistas necessitam dos administradores e não podem operar em um sistema em que pessoas sérias, capazes e responsáveis não tenham incentivos a ingressar como administradores, deixando o espaço para aventureiros. É que se o sistema for excessivamente rígido, ou bem essas pessoas não estarão dispostas a correr o risco de serem administradores, receosos em razão das regras de responsabilização à luz da realidade empresarial, ou bem atuarão visando essencialmente ressaltar-se de responsabilidades, comprometendo, assim o desempenho eficiente da companhia"* (CAMPOS, Luiz Antonio Sampaio. Deveres e Responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. *Direito das Companhias*. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 1092).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 05/12/2019, às 10:30, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0894664** e o código CRC **5B7FFC81**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0894664** and the "Código CRC" **5B7FFC81**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEI Nº 19957.004309/2016-73

Reg. Col. nº 0463/2016

Acusados: André Pires de Oliveira Dias
Harley Lorentz Scardoelli
Claudio Gerdau Johannpeter
André Bier Gerdau Johannpeter
Richard Chagas Gerdau Johannpeter
Expedito Luz
Affonso Celso Pastore
Oscar de Paula Bernardes Neto
INDAC – Indústria Administração e Comércio Ltda.
Metalúrgica Gerdau S.A.

Assunto: Apurar eventuais irregularidades em operação de aquisição de participações minoritárias em empresas controladas pela Gerdau S.A., em suposto descumprimento dos arts. 116, parágrafo único, 154 c/c 245, 156 e 157, §4º, todos da Lei nº 6.404/1976, e arts. 3º e 5º da Instrução CVM nº 358/2002.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Apresento esta manifestação de voto porque, embora concorde integralmente com a fundamentação e as conclusões da Diretora Relatora, parece-me que, aqui, temos um caso que exige esforço singular de julgamento, uma vez que põe à prova entendimentos deste Colegiado sobre temas complexos que há muito vêm sendo objeto de debates aqui e na doutrina e, em tais debates, o que mais aproxima as opiniões nos mais diversos sentidos é o reconhecimento da dificuldade de se estabelecer algumas linhas demarcatórias que são fundamentais.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

2. A primeira delas está relacionada aos limites de atuação da CVM na revisão de decisões negociais. Afinal, embora, como regra, tais decisões mereçam ser preservadas, em algumas situações, a própria Lei nº 6.404/76 exige que, no âmbito de análise revisional, sejam submetidas a exame de mérito, de modo a avaliar se atendem aos requisitos legais. É este o caso do art. 154, que requer referido exame, a fim de verificar se a decisão em questão foi tomada para *“lograr os fins e no interesse da companhia”*.

3. Este exame envolve a análise da conduta dos administradores, inclusive do conteúdo das decisões tomadas no âmbito dos órgãos colegiados (conselho de administração e diretoria), com o objetivo de aferir se se conciliam com o objeto social e os interesses da companhia. Trata-se, assim, de exame de mérito, cabendo aos administradores, quando em face de acusação por desvio de poder, lançar mão de elementos aptos a demonstrar que seus atos são tendentes ao atingimento de interesses da companhia¹.

4. A segunda linha demarcatória a que me refiro diz respeito à diferenciação entre, de um lado, a análise de aderência da conduta dos administradores à luz dos interesses sociais e, de outro, ao padrão de diligência requerido pelo art. 153. Mais precisamente, aos limites das implicações do atendimento ao dever de diligência para a análise se determinada conduta ou decisão cumpriu o disposto no art. 154².

5. E isso porque, no caso concreto, como exposto pela Diretora Relatora em seu voto, os acusados lograram demonstrar que, no curso do processo decisório que resultou na aprovação da decisão que é questionada (a Aquisição Itaú³), adotaram o cuidado e a diligência necessários, amparando-se em informações suficientes para a tomada de decisão informada, refletida e, como demonstrado pela Diretora Relatora, desinteressada.

¹ Conforme a manifestação de voto que apresentei no âmbito do PAS nº RJ2013/11703, j. em 31.07.2018, oportunidade em que também esclareci que o exame de mérito que o art. 154 impõe não envolve um juízo de adequação da conduta ou decisão do administrador no sentido de avaliar se foram ideais para a companhia, mas sim se, em alguma medida, foram contrárias ao interesse social.

² Na realidade, a mesma problemática existe quando se coteja o dever de diligência com os demais deveres fiduciários. Entretanto, para os fins limitados deste voto, me atenho à discussão que cuida dos deveres previstos nos artigos 153 e 154.

³ Os termos iniciados em letra maiúscula referenciados na presente manifestação de voto e que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no voto da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Não há, assim, dúvida com relação à regularidade, sob o aspecto procedimental de tomada de decisão, da conduta dos acusados.

6. Apesar disso, e é aqui que reside o principal aspecto que entendo importante esclarecer, a incontroversa diligência dos acusados ao aprovar a Aquisição Itaú não significa, necessariamente – ou, dito de outro modo, por si só não atesta – que a decisão esteja aderente ao que prescreve o art. 154.

7. Reconheço que a higidez do processo decisório é um elemento relevante a indicar, ao menos formalmente, a correspondência entre a decisão tomada pelos administradores e os interesses sociais. Por outro lado, não acredito que, simplesmente por ter resultado de processo decisório hígido, seja possível dispensá-la da revisão de mérito quando se questiona justamente os interesses envolvidos em determinada decisão. Tal entendimento conduziria à conclusão de que uma decisão diligente não poderia ser considerada contrária ao interesse social, o que não corresponde à realidade e nem reflete o sistema da lei societária, sobretudo ao conceber os deveres fiduciários dos administradores.

8. Dessa forma, a despeito da regularidade formal do processo decisório, que permite a presunção de que, a princípio, não estavam imbuídos de interesses outros que não os da Companhia quando negociaram e aprovaram a Aquisição Itaú, entendo que o presente caso apresenta circunstâncias específicas – notadamente o significativo descolamento do preço da operação constatado pela Acusação e seu reflexo para as Controladoras – a demandar do Colegiado a avaliação sobre o mérito da decisão tomada pelos acusados, à luz do interesse da Companhia⁴.

9. Destaco, uma vez mais, que o presente caso distancia-se de outros já examinados por este Colegiado em que a atuação dos administradores era visivelmente irreconciliável

⁴ Essas circunstâncias são, aliás, o que, a meu ver, diferencia substancialmente o presente caso do já mencionado PAS nº RJ2013/11703, no qual este Colegiado foi instado a analisar a conduta de administradores à luz do art. 154. Naquela ocasião, apresentei manifestação de voto pela absolvição dos acusados, pois, a meu ver, existiam elementos robustos que autorizavam a conclusão de que os administradores atuaram pautados pelos interesses da companhia, que decorriam tanto da regularidade do processo decisório, mas, principalmente, da ausência de indícios de que a decisão, de alguma forma, contrariava o interesse social. No presente caso, a expressiva diferença entre o preço da Aquisição Itaú e o da Aquisição Arcelor, bem como o reflexo que referida aquisição apresentava para as Controladoras, justificam a análise de mérito da decisão tomada, como fez a Diretora Relatora em seu voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

com o interesse social⁵. As defesas demonstraram, aliás, que a Aquisição Itaú se destinava a atender interesses próprios da Gerdau.

10. Por outro lado, e sem deixar de lado a complexidade inerente à análise que aqui se faz – a respeito do preço e as condições de pagamento de aquisição de participação societária –, levando em consideração a substancial diferença entre os preços pagos na Aquisição Itaú e na Aquisição Arcelor, os termos da PUT e os interesses que estavam em jogo, não vejo como considerar que o fator preponderante na decisão dos membros do conselho de administração da Gerdau tenha sido o interesse social, como apontado no voto da Diretora Relatora.

11. Não pretendo, em momento algum, questionar a adequação do plano de aquisições que vinha sendo executado antes das Aquisições, nem da inserção destas ao plano de negócios da Gerdau. Por outro lado, quando se coteja o expressivo valor, seja em termos absolutos, seja relativamente àquele praticado na Aquisição Arcelor, e mesmo considerando as condições de pagamento, o que sobressai é que outros interesses, que não aqueles exclusivamente da Companhia, a meu ver, prevaleceram no processo decisório observado pelos membros do conselho de administração. E isso não se coaduna com o comando do art. 154 da lei societária.

12. De resto, reporto-me às razões constantes do voto da Diretora Relatora para acompanhá-las integralmente, assim como suas conclusões.

É como voto.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2019

Marcelo Barbosa

Presidente

⁵ Como, por exemplo, aqueles envolvendo atos de liberalidade praticado por administradores (PAS CVM nº 14/2009, diretora relatora Luciana Dias, j. em 11.08.2015; PAS CVM nº 02/2011, diretor relator Gustavo Borba, j. em 08.12.2015; e PAS CVM nº RJ 2012/3110, relator diretor Pablo Renteria, j. em 14.02.2017).